الروض المربع شرح زاد المستقنع

البهوتي (ت ١٠٥١هـ)

الجزء ٢

نص المؤلف كما في طبعة: الرياض ، 1390 ، مكتبة الرياض الحديثة
المصدر: مجموعة OpenITI (KITAB)، برخصة المشاع الإبداعي CC BY-NC-SA 4.0، للاستخدام غير التجاري.
نص المؤلف دون تغيير، لا تشمل هذه النسخة حواشي المحققين.
Romanov, M. & Seydi, M. OpenITI. doi:10.5281/zenodo.3082463

كتاب الجهاد

+ مصدر جاهد أي بالغ في قتل عدوه وشرعا قتال الكفار (وهو فرض كفاية) إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس وإلا أثم الكل ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به وهو أفضل متطوع به ثم النفقة فيه (ويجب الجهاد (إذا حضره) أي حضر صف القتال (أو حصر بلده عدو) أو احتيج

إليه (أو استنفره الإمام) حيث لا عذر له لقوله تعالى ﴿ إذا لقيتم فئة فاثبتوا ﴾ وقوله ﴿ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ﴾ وإذا نودي الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر (وتمام الرباط أربعون يوما) لقولة صلى الله عليه وسلم تمام الرباط أربعون يوما رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب والرباط لزوم ثغر لجهاد تقوية للمسلمين وأقله ساعة وأفضله بأشد الثغور خوفا وكره نقل أهله إلى مخوف (وإذا كان أبواه مسلمين) حرين أو أحدهما كذلك (لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما) لقوله صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد صححه الترمذي ولا يعتبر إذنهما لواجب ولا إذن جد وجدة وكذا لايتطوع به مدين آدمي لا وفاء له إلا مع إذن أو رهن محرز

أو كفيل مليء (ويتفقد الإمام) وجوبا (جيشه عند المسير ويمنع) من لايصلح لحرب من رجال وخيل ك (المخذل) الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه (والمرجف) كالذي يقول هلكت سريه المسلمين وما لهم مدد أو طاقة وكذا من يكاتب بأخبارنا أو يرمي بيننا بفتن ويعرف الأمير عليهم العرفاء ويعقد لهم الألوية والرايات ويتخير لهم المنازل ويحفظ مكامنها ويبعث العيون ليتعرف حال العدو (وله أن ينفل) أي يعطي زيادة على السهم (في بدايته) أي عند دخوله أرض

العدو ويبعث سرية تغير ويجعل لها (الربع) فأقل (بعد الخمس وفي الرجعة) أي إذا رجع من أرض العدو أو بعث سرية ويجعل لها (الثلث) فأقل (بعده) أي بعد الخمس ويقسم الباقي في الجيش كله لحديث حبيب بن مسلمة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة رواه أبو داود (ويلزم الجيش طاعته) والنصح (والصبر معه) لقوله تعالى ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ ولا يجوز التعلف والاحتطاب و (الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه) بفتح اللام أي شره وأذاه لأن المصلحة تتعين في قتله إذا ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة ولا خنثى وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا

ويكونون أرقاء بسبي والمسبي غير بالغ منفردا أو مع أحد أبويه مسلم وإن أسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم وكغير البالغ من بلغ مجنونا (وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب) وتجوز قسمتها فيها لثبوت أيدينا

عليها وزوال ملك الكفار عنها والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال أو ما ألحق به مشتقة من الغنم وهو الربح (وهي لمن شهد الوقعة) أي الحرب (من أهل القتال) بقصده قاتل أو لم يقاتل حتى تجار العسكر وأجرائهم المستعدين للقتال لقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة (فيخرج) الإمام أو نائبه (الخمس) بعد دفع سلب لقاتل وأجرة جمع وحفظ وحمل وجعل من دل على مصلحة

ويجعله خمسة أسهم منها سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مصرفه كفيء وسهم لبني هاشم وبني المطلب وحيث كانوا غنيهم وفقيرهم وسهم لفقراء اليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل يعم من بجميع البلاد حسب

الطاقه (ثم يقسم باقي الغنيمة) وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء النفل والرضخ لنحو قن ويميز على ما يراه (للراجل سهم) ولو كافرا (وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه) إن كان عربيا لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له متفق عليه عن ابن عمر وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط ولا يسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خيل ولا شيء لغيرها من البهائم لعدم وروده عنه صلى الله عليه وسلم (ويشارك الجيش سراياه) التي بعثت منه في دار الحرب (فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم) قال ابن المنذر روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وترد سراياهم على قعدهم وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت (والغال من الغنيمة) وهو من كتم ما غنمه أو بعضه لا يحرم سهمه و (يحرق) وجوبا (رحله كله) مالم يخرج عن ملكه (إلا السلاح

والمصحف وما فيه روح) وآلته ونفقته وكتب علم وثيابه التي عليه وما لا تأكله النار فله قال يزيد بن يزيد بن جابر السنة في الذي يغل أن يحرق رحله رواه سعيد في سننه (وإذا غنموا) أي المسلمون (أرضا) بأن (فتحوها) عنوة (بالسيف) فأجلوا عنها أهلها (خير الإمام بين قسمها) بين الغانمين (ووقفها على المسلمين) بلفظ من ألفاظ الوقف (ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده) من مسلم وذمي ويكون أجرة لها في كل عام كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفا منا أو صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج بخلاف ما صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهي كجزية تسقط بإسلامهم (والمرجع في) مقدار (الخراج والجزية)

حين وضعهما (إلى اجتهاد الإمام) الواضع لهما فيضعه بحسب اجتهاده لأنه أجرة يختلف باختلاف الأزمنة فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه وما وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره مالم يتغير السبب كما في الأحكام السلطانية لأن تقديره ذلك حكم والخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع لاعلى مساكن (ومن عجز عن عمارة أرضه) الخراجية (أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها) بإجارة أو غيرها لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم (ويجرى فيها الميراث) فتنقل إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه فإن آثر بها أحدا صار الثاني أحق بها كالمستأجرة ولا خراج على مزارع مكة والحرم (وما أخذ) بحق بغير قتال (من مال مشرك) أي كافر (كجزية وخراج وعشر) تجارة من حربي أو نصفه من ذمي اتجر إلينا (وما تركوه فزعا)

منا أو تخلف عن ميت لا وارث له (وخمس خمس الغنيمة ف) هو (فيء) سمي بذلك لأنه رجع من المشتركين إلى المسلمين وأصل الفيء الرجوع (يصرف في مصالح المسلمين) ولا يختص بالمقاتلة ويبدأ بالأهم فالأهم من سد بثق وتعزيل نهر وعمل قنطرة ورزق نحو قضاة ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم %

فصل الأمان والهدنة

+ ويصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قنا أو أنثى بلا ضرر في عشر سنين فأقل

منجزا ومعلقا من إمام لجميع المشركين ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا ويحرم به قتل ورق وأسر ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم برد إلى مأمنه والهدنة عقد الإمام أ و نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة وهي لازمة يجوز عقدها لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين ولو بمال منا ضرورة ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم ولو هرب قن فأسلم لم يرد وهو حر ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم

باب عقد الذمة وأحكامها

+ الذمة لغة العهد والضمان والأمان ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة والأصل

فيه قوله تعالى ﴿ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ لايعقد أي لايصح عقد الذمة (لغير المجوس) لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع فصارت لهم بذلك شبهة ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف (وأهل الكتابين) اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم (ومن تبعهم) فتدين لهم بأحد الدينين كالسامرة والفرنج والصابئين لعموم قوله تعالى ﴿ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ ولا يعقدها أي لا يصح عقد الذمة (إلا) من (إمام أو نائبه) لأنه عقد مؤبد فلا يفتأت على الإمام فيه ويجب إذا اجتمعت شروطه (ولاجزية) وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار

كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا (على صبي ولا امرأة) ومجنون وزمن وأعمى وشيخ فان وخنثى مشكل (ولا عبد ولا فقير يعجز عنها) وتجب على عتيق ولو مسلم (ومن صار أهلا لها) أي للجزية (أخذت منه في آخر الحول) بالحساب (ومتى بذلوا الواجب عليهم) من الجزية (وجب قبوله) منهم (وحرم قتالهم) وأخذ ما لهم ووجب دفع من قصدهم بأذى مالم يكونوا بدار حرب ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه (ويمتهنون عند أخذها) أي أخذ الجزية (ويطال وقوفهم وتجر أيديهم) وجوبا لقوله تعالى ﴿ وهم صاغرون ﴾ ولا يقبل إرسالها %

فصل في أحكام أهل الذمة

+ (ويلزم الإمام أخذ أهل الذمة (بحكم الإسلام في) ضمان (النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه) كالزنا

(دون ما يعتقدون حله) كالخمر لأن عقد الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام كما تقدم وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجهما (ويلزمهم التميز عن المسلمين) بالقبور بأن لايدفنوا في مقابرنا والحلي بحذف مقدم رؤوسهم لا كعادة الأشراف ونحو شد زنار ولدخول حمامنا بجلجل أو نحو خاتم رصاص برقابهم (ولهم ركوب غير الخيل) كالحمير (بغير سرج) فيركبون (بإكاف) وهو البرذعة لما روى الخلال أن عمر أمر بجز نواصي أهل الجزيرة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأ كف بالعرض (ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بدأتهم بالسلام) أو ب كيف أصبحت أو أمسيت أو حالك ولا تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة أعيادهم لحديث أبى هريرة مرفوعا لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها قال الترمذي حديث حسن صحيح (ويمنعون من إحداث كنائس وبيع) ومجتمع لصلاة في دارنا (و) من

(بناء ما انهدم منها ولو ظلما) لما روى كثير بن مرة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها (و) يمنعون أيضا (من تعلية بنيان على مسلم) ولو رضي لقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وسواء لاصقة أو لا إذا كان يعد جارا له فإن علاه وجب نقضه و (لا) يمنعون من (مساواته) أي البنيان (له) أي لبناء المسلم لأن ذلك لا يفضي إلى العلو وما ملكوه عاليا من مسلم لا ينقص ولا يعاد عاليا لو انهدم (و) يمنعون أيضا (من إظهار خمر وخنزير) فإن فعلوا أتلفناهما (و) من إظهار (ناقوس وجهر بكتابهم) ورفع صوت على ميت ومن قراءة قرآن ومن إظهار أكل أوشرب بنهار رمضان وإن صولحوا في بلادهم على جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك وليس لكافر دخول مسجد ولو إذن له مسلم وإن تحاكموا إلينا فلنا الحكم والترك لقوله تعالى ﴿ فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ﴾ وإن اتجر إلينا حربي أخذ من العشر وذمي

نصف العشر لفعل عمر رضي الله عنه مرة في السنة فقط ولا تعشر أموال المسلمين (وإن تهود نصراني أو عكسه) بأن تنصر يهودي (لم يقر) لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه أشبه المرتد (ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه) الأول فإن أباهما هدد وحبس وضرب وقيل للإمام أنقتله قال لا %

فصل فيما ينقض العهد

+ (فإن أبي الذمي بذل الجزية) أو الصغار (أو التزام حكم الإسلام) أو قاتلنا (أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا) بمسلمة وقياسه اللواط (أو) تعدى ب (قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه) أو دينه

(بسوء انتقض عهده) لأن هذا ضرر يعم المسلمين وكذا لو لحق بدار حرب لا إن أظهر منكرا أو قذف مسلما وينقض بما تقدم عهده (دون) عهد (نسائه وأولاده) فلا ينتقض عهدهم تبعا له لأن النقض وجد منه فاختص به (وحل دمه) ولو قال تبت فيخير فيه الإمام كأسير حربي بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو أسير مسلم (و) حل (ماله) لأنه لا حرمة له في نفسه بل هو تابع لمالكه فيكون فيئا وإن أسلم حرم قتله

8

كتاب البيع

+ جائز بالإجماع لقوله تعالى ﴿ وأحل الله البيع ﴾ وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء قاله ابن هبيرة مأخوذ من الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء وشرعا (مبادلة مال ولو في الذمة) بقول أو معاطاة والمال عين مباحة النفع بلا حاجة (أو منفعة مباحة) مطلقا (كمر) في دار أو غيرها (بمثل عين بعين أو دين أو منفعة دين بعين أو دين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق أو بمنفعة منفعة بعين أو دين أو منفعة وقوله (على التأبيد) يخرج الإجارة (غير ربا وقرض) فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة لقوله تعالى ﴿ وأحل الله البيع وحرم الربا ﴾ والمقصود أحدهما) متعلق بمبادلة أي بمال أو منفعة مباحة فتناول تسع

صور الأعظم في القرض الإرفاق وإن قصد فيه التملك أيضا (وينعقد) البيع (بإيجاب وقبول) بفتح القاف وحكي ضمها (بعده) أي بعد الإيجاب فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا ويقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحوه (و) يصح القبول أيضا (قبله) أي قبل الإيجاب بلفظ أمر أو ماض مجرد

عن استفهام ونحوه لأن المعنى حاصل به ويصح القبول (متراخيا عنه) أي عن الإيجاب ما داما (في مجلسه) لأن حالة المجلس كحالة العقد (فإن تشاغلا بما يقطعه) عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول (بطل) لأنهما صارا معرضين عن البيع وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد (وهي) أي الصورة المذكورة أي الإيجاب والقبول (الصيغة القولية) للبيع (و) ينعقد أيضا (بمعاطاة وهي) الصيغة (الفعلية) مثل أن يقول أعطني بدرهم خبزا فيعطيه ما يرضيه أو يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري أو وضع ثمنه عادة

وأخذه عقبه فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول للدلالة على الرضى لعدم التعبد فيه وكذا حكم الهبة والهدية والصدقة

ج ٢ - ص ٢٥

ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء (ويشترط) للبيع سبعة شروط أحدها (التراضي منهما) أي من المتعاقدين (فلا يصح) البيع (من مكره بلا حق) لقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض رواه ابن حبان فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح لأنه حمل عليه بحق وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح

(و) الشرط الثاني (أن يكون العاقد) وهو البائع والمشتري (جائز التصرف) أي حرا مكلفا رشيدا (فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي) فإن أذن صح لقوله تعالى ﴿ وابتلوا اليتامى ﴾ أي اختبروهم وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه ويحرم الإذن بلا مصلحة وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن وتصرف العبد بإذن سيده (و) الشرط الثالث (أن تكون العين) المعقود عليها أو على منفعتها (مباحة النفع من غير حاجة) بخلاف الكلب لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغا لأنه إنما يباح في يابس والعين هنا مقابل المنفعة

فتتناول ما في الذمة (كالبغل والحمار) لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير (و) ك (دود القز) لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه (و) ك (بزرة) لأنه ينتفع به في المآل (و) ك (الفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد) كالفهد والصقر لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا (إلا الكلب) فلا يصح بيعه لقول ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب متفق عليه ولا بيع آلة لهو وخمر ولو كانا ذميين (والحشرات) لايصح بيعها لأنه لانفع فيها إلا علقا لمص الدم وديدانا لصيد السمك وما يصاد عليه كبومة تجعل شباشا (والمصحف) لايصح بيعه ذكر في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه قال أحمد لا نعلم في بيع

المصحف رخصة قال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له ولا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا وفي كلام بعضهم يعني من كافر ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم دعاء الحاجة إليه بخلاف الكافر ومفهوم التنقيح و المنتهى يصح بيعه لمسلم (والميتة) لا يصح بيعها لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام متفق عليه ويستثنى منها السمك والجراد (و) لا (السرجين النجس) لأنه كالميتة وظاهره أنه يصح

بيع الطاهر منه قاله في المبدع (و) لا (الأدهان النجسة ولا المتنجسة) لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وللأمر بإراقته (ويجوز الاستصباح بها) أي بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته كالانتفاع بجلد الميتة المدبوغ (في غير مسجد) لأنه يؤدي إلى تنجيسه ولا يجوز الاستصباح بنجس العين ولا يجوز بيع سم قاتل (و) الشرط الرابع (أن يكون) العقد (من مالك) للمعقود عليه (أو من يقوم مقامه) كالوكيل والوالي لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك رواه ابن ماجه والترمذي وصححه وخص منه المأذون فيه لقيامه مقام المالك (فإن باع ملك غيره) بغير إذنه لم يصح ولو مع حضوره

وسكوته ولو أجازه المالك مالم يحكم به من يراه (أو اشترى بعين ماله) أي مال غيره (بلا إذنه لم يصح) ولو أجيز لفوات شرطه (وإن اشترى له) أي لغيره (في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح) العقد لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف ويصير ملكا لمن اشترى (له) من حين العقد (بالإجازة) لأنه اشترى لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل فملكه من

اشترى له كما لو أذن (ولزم) العقد (المشتري بعدمها) أي عدم الإجازة لأنه لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري (ملكا) كما لو لم ينوه غيره وإن سمى في العقد من اشترى له لم يصح وإن باع مايظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح (ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق) وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين وأما المساكن فيصح بيعها لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير ولو كانت آلتها من أرض العنوة أو كانت موجودة حال الفتح وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعا منا وما صولحوا على أنه لنا ونقره معهم بالخراج بخلاف ماصولحوا على أنها لهم كالحيرة وأليس وبانقياء وأرض بني صلوبا من أراضي العراق فيصح بيعها كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة (بل) يصح أن (تؤجر) أرض العنوة ونحوها لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها

في كل عام وإجارة المؤجرة جائزة ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مكة لاتباع رباعها ولا تكرى بيوتها رواه الأثرم فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها جزم به في المغني وغيره (ولا يصح بيع نقع البئر) وماء العيون لأن ماءها لايملك لحديث المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار رواه أبو داود وابن ماجه بل رب الأرض أحق به من غيره لأنه صار في ملكه (ولا) يصح بيع ماينبت

في أرضه من كلأ وشوك لما تقدم وكذا معادن جارية كنفط وملح وكذا

لو عشش في أرضه طير لأنه لايملكه به فلم يجز بيعه (ويملكه آخذه) لأنه من المباح لكن لايجوز دخول ملك غيره بغير إذنه وحرم منع مستأذن بلا ضرر (و) الشرط الخامس (أن يكون) المعقود عليه (مقدورا على تسليمه) لأن مالا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه (فلا يصح بيع آبق) علم خبره

أو لا لما رواه أحمد عن أبى سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق (و) لابيع (شارد و) لا (طير في هواء) ولو ألف الرجوع إلا أن يكون بمغلق ولو طال زمن أخذه (و) لابيع (سمك في ماء) لأنه غرر ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه لأنه معلوم يمكن تسليمه (ولا) يصح بيع (مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه) من غاصبه لأنه لايقدر على تسليمه فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح لعدم الغرر فإن عجز بعد فله الفسخ

(و) الشرط السادس (أن يكون) المبيع معلوما عند المتعاقدين لأن جهالة المبيع غرر ومعرفة المبيع إما (برؤية) له أو لبعضه الدال عليه مقارنة أو متقدمة بزمن لايتغير فيه المبيع ظاهرا ويلحق بذلك ماعرف بلمسه أو شمه

أو ذوقه (أو صفة) تكفي في السلم فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة ولا يصح بيع الأنموذج بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها

من جنسه ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيله (فإن اشترى ما لم يره) بلا وصف (أو رآه وجهله) بأن لم يعلم ما هو (أو وصف له بما لايكفي سلما لم يصح) البيع لعدم العلم بالمبيع (ولا يباع حمل في بطن ولا لبن في ضرع منفردين) للجهالة فإن باع ذات لبن أو حمل دخلا تبعا (ولا) يباع (مسك في فأرته) أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة (ولانوى

في تمر) للجهالة (و) لا (صوف على ظهر) لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه في حديث ابن عباس ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه (و) لايصح بيع (فجل ونحوه) مما المقصود منه مستتر بالأرض (قبل قلعه) للجهالة (ولا يصح بيع الملامسة) بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا (أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا (و) لا (المنابذة) كأن يقول أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فعليك بكذا لقول أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة متفق عليه وكذا بيع الحصاة كارمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا ونحوه (ولا) بيع (عبد) غير معين (من عبيده ونحوه) كشاة من قطيع وشجرة من بستان للجهالة ولو تساوت القيم (ولا) يصح (استثناؤه إلا معينا) فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا

للجهالة ويصح إلا هذا ونحوه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم قال الترمذي حديث صحيح (وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح) لفعله صلى الله عليه وسلم في خروجه من مكة إلى المدينة رواه أبو الخطاب فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبره بلا شرط ولزمته قيمته

على التقريب وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى (وعكسه) أي عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء (الشحم والحمل) ونحوه مما لايصح إفراده بالبيع فيبطل باستثنائه وكذا لو استثنى منه رطلا من لحم أو نحوه (ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ) وبيض لدعاء الحاجة لذلك ولكونه مصلحة لفساده بإزالته (و) يصح بيع (الباقلاء ونحوه) كالحمص والجوز واللوز (في قشره) يعني ولو تعدد قشره لأنه مضاف فيعم وعبارة الأصحاب في قشريه لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان (و) يصح بيع (الحب المشتد في سنبله) لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الاشتداد غاية للبيع وما بعد الغاية يخالف ماقبلها

فوجب زوال المنع (و) الشرط السابع (أن يكون الثمن معلوما) للمتعاقدين أيضا كما تقدم لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع (فإن باعه برقمه) أي ثمنه المكتوب عليه وهما يجهلانه أو أحدهما لم يصح للجهالة (أو) باعه (بألف درهم ذهبا وفضة) لم

يصح لأن مقدار كل جنس منهما مجهول (أو) باعه (بما ينقطع به السعر) أي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة (أو) باعه (بما باع) به (زيد وجهلاه أو) جهله (أحدهما لم يصح البيع للجهل بالثمن) وكذا لو باعه كما يبيع الناس أو بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجا وإن لم يكن إلا واحدا أو غلب صح وصرف إليه ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصرة من دراهم أو فلوس ووزن صنجة وملء كيل مجهولين (وإن باع ثوبا أو صبرة) وهي الكومة المجموعة من الطعام (أو) باع (قطيعا كل ذراع) من الثوب بكذا (أو) كل (قفيز) من الصبرة بكذا (أو) كل (شاة) من القطيع (بدرهم صح) البيع ولو لم يعلما قدر الثوب والصبرة والقطيع لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته إلى مايعرف مبلغه من جهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهي الكيل والعد والذرع تفريق الصفقة (وإن

باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح لأن من للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا بخلاف ما سبق لأن المبيع الكل لا البعض فانتفت الجهالة وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا أو من القطيع كل شاة بكذا لم يصح لما ذكر (أو) باعه (بمائة درهم إلا دينارا) لم يصح (وعكسه) بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما لم يصح لأن قيمة المستثنى مجهولة فيلزم الجهل بالثمن إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا (أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه) كهذه الفرس وما في بطن

أخرى (ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح) البيع لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة والمجهول لايمكن تقويمه فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم وكذا لو باعه بمائة ورطل خمر وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به (فإن لم يتعذر) علم مجهول بيع مع معلوم (صح في المعلوم بقسطه) من الثمن لعدم الجهالة وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث والثانية أشير إليها بقوله (ولو مشاعا بينه وبين غيره كعبد) مشترك بينهما (أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء) كقفيزين متساويين لهما (صح) البيع (في نصيب بقسطه) من الثمن لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجزاء ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه والثالثة ذكرها بقوله (وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو) باع (عبدا وحرا أو) باع (خلا وخمرا صفقة واحدة) بثمن واحد (صح) البيع (في عبده)

بقسطه (وفي الخل بقسطه من الثمن لأن كل واحد منهما له حكم يخصه فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما ويقدر خمر خلا وحر عبدا ليتقسط الثمن (ولمشتر الخيار إن جهل الحال) بين إمساك مايصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد المبيع لتبعيض الصفقة عليه وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه أو باع عبديه الاثنين أو اشترى عبدين من اثنين أو وكليهما بثمن واحد صح وقسط الثمن على قيمتهما وكبيع إجارة ورهن وصلح ونحوها %

فصل

+ (ولا يصح البيع) ولا الشراء (ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني) أي الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم لقوله تعالى ﴿ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ﴾ والنهي يقتضي الفساد وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه وتحرم المساومة والمناداة إذن لأنهما وسيلة للبيع المحرم وكذا لو تضايق وقت مكتوبة (ويصح) بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما إذا والضمان والإجارة وإمضاء بيع خيار لأن ذلك يقل وقوعه فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع (ولا يصح بيع عصير) ونحوه (ممن يتخذه خمرا) لقوله تعالى ﴿ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ وجد ذلك يباع ويصح أيضا (النكاح

وسائر العقود) كالقرض والرهن ﴿ ولا ﴾ بيع (سلاح في فتنة) بين المسلمين لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه قاله أحمد قال وقد يقتل به وكذا بيعه لأهل حرب أو قطاع طريق لأنه إعانة على معصية ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر ولا قدح لمن يشرب به خمرا ولا جوز وبيض لقمار ويحرم أكله من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار فمنع من ابتدائه فإن كان يعتق عليه بالشراء صح لأنه وسيلة إلى حريته (وإن أسلم) قن (في يده) أي يد كافر أو عند مشتريه منه ثم رده لنحو عيب (أجبر على إزالة ملكه) عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق لقوله تعالى ﴿ ولن يجعل الله ﴾ ونحو ذلك (ولا) بيع (عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق

عليه) لأنه ممنوع ﴿ للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴾ ولا تكفي مكاتبته لأنها لاتزيل ملك سيده عنه ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع علقه عنه (وإن جمع) في عقد (بين بيع وكتابة) بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة (أو) جمع بين (بيع

وصرف) أو إجارة أو خلع أو نكاح بعوض واحد (صح) البيع وما جمع إليه (في غير الكتابة) فيبطل البيع لأنه باع ماله لماله وتصح هي لأن البطلان وجد في البيع فاختص به (ويقسط العوض عليهما) أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم (ويحرم بيعه على بيع أخيه) المسلم (كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتعسة) لقوله صلى الله عليه وسلم لايبع بعضكم على بيع بعض (و) يحرم أيضا (شراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة

عندي فيها عشرة) لأنه في معنى البيع عليه المنهي عنه ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين (ليفسخ) المقول له العقد (ويعقد معه) وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحا لا بعد رد (ويبطل العقد فيهما) أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه ويصح في السوم على سومه والإجارة كالبيع في ذلك ويحرم بيع حاضر لباد ويبطل إن قدم ليبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها

وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها (ومن باع ربويا بنسيئة) أي مؤجل وكذا حال لم يقبض (واعتاض عن ثمن ما لا يباع به نسيئة) كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجز لأنه ذريعة لبيع الربوي بالربوي نسيئة وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلمها إليه لكن تقاصا جاز (أو اشترى شيئا) ولو غير ربوي (نقدا بدون ما باع به نسيئة) أو حالا لم يقبض (لا بالعكس لم يجز) لأنه ذريعة إلى الربا ليبيع ألفا بخمسمائة وتسمى

مسألة العينة وقوله بالعكس يعني لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه

جائز كما لو اشتراه بمثله وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة وجزم به المصنف في الإقناع وصاحب المنتهى وقدمه في المبدع وغيره قال في شرح المنتهى وهو المذهب لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ولايصح (وإن اشتراه) أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها (بغير جنسه) بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس (أو) اشتراه (بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته) بأن هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب (أو) اشتراه (من غير مشتريه) بأن باعه

مشتريه أو وهبه ونحوه ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه جاز (أو اشتراه أبوه) أي أبو بائعه (أو ابنه) أو مكاتبه أو زوجته (جاز) الشراء مالم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة ومن احتاج إلى نقد فاشترى مايساوي مائة بمائتين وأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق ويحرم التسعير

والاحتكار في قوت آدمي ويجبر على بيعه كما يبيع الناس ولا يكره إدخار

قوت أهله ودوابه ويسن الإشهاد على البيع

1 باب الشروط في البيع

والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه منفعة ومحل المعتبر منها صلب العقد وهي ضربان ذكر الأول منهما بقوله (منها صحيح) وهو ماوافق مقتضى العقد وهو ثلاثة أنواع أحدها شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن فلا يؤثر فيه لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد فلذلك اختصه المصنف

الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد (كالرهن المعين) أو الضامن المعين (و) ك (تأجيل ثمن) أو بعضه إلى مدة معلومة (و) كشرط صفة في المبيع ك (كون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما) أو خياطا مثلا (والأمة بكرا) أو تحيض والدابة هملاجة والفهد أو نحوه صيودا فيصح فإن وفي بالشرط وإلا فلصاحبه

الفسخ أو أرش فقد الصفة وإن تعذر رد تعين أرش وإن شرط صفة فبان أعلا منها فلا خيار (و) الثالث شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطء ودواعيه (نحو أن

بشترط البائع سكنى الدار) أو نحوها (شهرا وحملان البعير) أو نحوه المبيع (إلى موضع معين) لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة متفق عليه واحتج في التعليق والانتصار وغيرها بشراء عثمان من صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه ذكره في المبدع ومقتضاه صحة الشرط المذكور ولبائع إجارة وإعارة مااستثنى وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر

فعليه أجرة المثل له (أو شرط المشتري على البائع) نفعا معلوما في مبيع (كحمل الحطب) المبيع إلى موضع معلوم (أو تكسيره أو خياطة الثوب) المبيع (أو تفصيله) إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل واحتج أحمد لذلك بما روي أن محمدا بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب وشارطه على حملها ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز (وإن جمع بين شرطين) من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله

(بطل البيع) لما روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لايحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ماليس عندك قال الترمذي حديث حسن صحيح والضرب الثاني من الشروط أشار إليه بقوله (ومنها فاسد) وهو ماينافي مقتضى العقد وهو ثلاثة أنواع أحدها (يبطل العقد) من أصله (كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا

آخر كسلف) أي سلم (وقرض وبيع وإجارة وصرف) للثمن أو غيره وشركة وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه قاله أحمد الثاني مايصح معه البيع وقد ذكره بقوله (وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو) شرط أن (لا يبيع) المبيع (ولا يهبه ولا يعتقه أو) شرط (إن عتق فالولاء له) أي للبائع (أو) شرط البائع على المشتري (أن يفعل ذلك) أي أن يبيع المبيع أو يهبه ونحوه (بطل الشرط وحده) لقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط متفق عليه والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد (إلا إذا شرط) البائع (العتق) على المشتري فيصح الشرط أيضا ويجبر المشتري على العتق إن أباه والولاء له فإن أصر أعتقه حاكم وكذا شرط رهن فاسد نكمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين ونحو ذلك فيصح البيع ويفسد الشرط (و) إن قال البائع (بعتك) كذا بكذا (على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث) ليال مثلا أو على أن ترهنه بثمنه

(وإلا) تفعل ذلك (فلا بيع بيننا) وقبل المشتري (صح) البيع والتعليق كما لو شرط الخيار وينفسخ إن لم يفعل (و) الثالث ما لا ينعقد معه بيع نحو (بعتك إن جئتني بكذا أو) إن (رضي زيد) بكذا وكذا تعليق القبول (أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك) في محله (وإلا فالرهن لك لايصح البيع) لقوله صلى الله عليه وسلم لايغلق الرهن من صاحبه رواه الأثرم وفسره أحمد بذلك وكذا

كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله وغير بيع العربون بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك فيصح لفعل عمر رضي الله عنه والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع والإجارة مثله (وإن باعه) شيئا (وشرط) في البيع (البراءة من كل عيب مجهول) أو من عيب كذا إن كان (لم يبرأ) البائع فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار لأنه إنما يثبت

بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله وإن سمى البائع العيب أو أبرأه المشتري بعد

العقد برئ (أو إن باعه دارا) أو نحوها مما يذرع (على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر) من عشرة (أو أقل) منها (صح) البيع والزيادة للبائع والنقص عليه (ولمن جهله) أي الحال من زيادة أو نقصان (وفات غرضه الخيار) فلكل منهما الفسخ ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى أو يرضى المشتري بالنقص بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز ولايجبر أحدهما على ذلك وإن كان البيع نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار والزيادة للبائع والنقص عليه

باب الخيار وقبض المبيع والإقالة

+ الخيار اسم مصدر اختار أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ (وهو) ثمانية (أقسام الأول خيار المجلس) بكسر اللام موضع الجلوس والمراد هنا مكان التبايع (يثبت) خيار المجلس (في البيع) لحديث ابن عمر يرفعه إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع

متفق عليه لكن يستثنى من البيع الكتابة وتولي طرفي العقد وشراء من يعتق عليه أو اعترف بحريته قبل الشراء (و) كالبيع (الصلح بمعناه) كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض وقسمة التراضي والهبة على عوض لأنها نوع من البيع (و) كبيع أيضا (إجارة) لأنها عقد معاوضه أشبهت البيع (و) كذا (الصرف والسلم) لتناول البيع لهما (دون سائر العقود) كالمساقاة والحوالة والوقف والرهن والضمان (ولكل من المتبايعين) ومن في معناهما ممن تقدم (الخيار مالم يتفرقا عرفا بأبدانهما) من

مكان التبايع فإن كانا في مكان واسع كصحراء فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات (وإن كانا في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت إلى بيت) أو إلى نحو صفة وإن كانا في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح أو خرج منها فقد افترقا وإن كانا في سفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها إن كانا أسفل أو بالعكس وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها ولو حجز بينهما بحاجز كحائط أو ناما لم يعد تفرقا لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد ولو طالت المدة (وإن نفياه) أي الخيار بأن تبايعا على أن لاخيار بينهما لزم بمجرد العقد (أو أسقطاه) أي الخيار بعد العقد (سقط) لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه (وإن أسقطه أحدهما) أي أحد المتبايعين أو قال لصاحبه اختر سقط خياره و (بقى خيار الآخر) لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره بخلاف صاحبه وتحرم الفرقة خشية الفسخ وينقطع الخيار بموت أحدهما

لابجنونه (وإذا مضت مدته) بأن تفرقا كما تقدم (لزم البيع) بلا خلاف القسم (الثاني) من أقسام الخيار خيار الشرط ب (أن يشترطاه) أي يشترط المتعاقدان الخيار (في) صلب (العقد) أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط (مدة معلومة ولو طويلة) لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عل شروطهم ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد ولا إلى أجل مجهول ولا في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع (وابتداؤها) أي ابتداء مدة الخيار (من العقد)

إن شرط في العقد وإلا فمن حين اشترط (وإذا مضت مدته) أي مدة الخيار ولم يفسخ لزم البيع (أو قطعاه) أي قطع المتعاقدان الخيار (بطل) ولزم البيع كما لو لم يشترطاه (ويثبت) خيارالشرط (في البيع والصلح) والقسمة والهبة (وما بمعناه) أي بمعنى البيع كالصلح بعوض عن عين أو دين مقر به وقسمة التراضي وهبة الثواب لأنها أنواع من البيع (و) في (الإجارة في الذمة) نحياطة ثوب (أو) في إجارة (على مدة لاتلي العقد) كسنة ثلاث في سنة اثنين إذا شرط مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث فإن وليت مدة العقد كشهر من الآن لم يصح شرط الخيار لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار وكلاهما غير جائز ولا يثبت خيار الشرط في غير ماذكر كصرف وسلم

وضمان وكفالة ويصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلين (وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح) الشرط وثبت له الخيار وحده لأن الحق لهما فكيفما تراضيا به جاز (و) إن شرطاه (إلى الغد أو الليل) صح و (يسقط بأوله) أي أول الغد أو الليل لأن إلى لانتهاء الغاية فلا يدخل مابعدها فيما قبلها وإلى الصلاة يسقط بدخول وقتها (و) يجوز (لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة) صاحبه (الآخر و) مع (سخطه) كالطلاق (والملك) في المبيع (مدة الخيارين)

أي خيار الشرط وخيار المجلس (للمشتري) سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فما له للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواه مسلم فجعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع فشمل بيع الخيار (وله) أي للمشتري (نماؤه) أي نماء المبيع (المنفصل) كالثمرة (وكسبه) في مدة الخيارين ولو فسخاه بعد لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه لحديث الخراج بالضمان صححه الترمذي وأما النماء المتصل كالسمن فإنه يتبع العين

مع الفسخ لتعذر انفصاله (ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع و) لا في (عوضه المعين فيها) أي في مدة الخيارين (بغير إذن الآخر) فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إلا معه كأن آجره له ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه كأن استأجر منه به عينا هذا إن كان التصرف (بغير تجربة المبيع) فإن تصرف بها لتجربته كركوب دابة

لينظر سيرها وحلب دابة ليعلم قدر لبنها لم يبطل خياره لأن ذلك هو المقصود من الخيار كاستخدام الرقيق (إلا عتق المشتري) لمبيع زمن الخيار فينفذ مع الحرمة ويسقط خيار البائع حينئذ (وتصرف المشتري) في المبيع بشرط الخيار له زمنه بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس (لأمة مبتاعة) لشهوة (فسخ لخياره) وإمضاء للبيع لأنه دليل الرضى به بخلاف تجربة المبيع واستخدامه وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض وبإتلاف مشتراه إياه مطلقا سواء قبضه أو لم يقبضه (ومن

مات منهما) أي من البائع أو المشتري في زمن الخيار (بطل خياره) فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحد القذف (الثالث) من أقسام الخيار خيار الغبن (إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة) لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف وله ثلاث صور إحداها تلقي الركبان لقوله

عليه الصلاة والسلام لاتلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى ال فهو بالخيار رواه مسلم (و) الثانية المشار إليها بقوله (بزيادة الناجش) الذي لايريد شراء ولو بلا مواطأة ومنه أعطيت كذا وهو كاذب لتغريره المشتري الثالثة ذكرها بقوله (والمسترسل) وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس

من استرسل إذا اطمأن واستأنس فإذا غبن ثبت له الخيار ولا أرش مع إمساك والغبن محرم وخياره على التراخي (الرابع) من أقسام الخيار (خيار

التدليس) من الدلسة وهي الظلمة فيثبت بما يزيد به الثمن (كتسويد شعر الجارية وتجعيده) أي جعله جعدا وهو ضد السبط (وجمع ماء الرحى) أي الماء الذي تدور به الرحى (وإرساله عند عرضها) للبيع لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حين ذلك فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في الثمن فإذا تبين له التدليس ثبت له الخيار وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام لحديث أبي هريرة يرفعه لاتصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر متفق عيه وخيار التدليس على التراخي إلا المصراة فيخير ثلاثة أيام منذ علم بين إمساك بلا أرش ورد مع صاع تمر سليم إن حلبها فإن عدم التمر فقيمته ويقبل رد اللبن بحاله (الخامس) من أقسام الخيار (خيار العيب) وما بمعناه

(وهو) أي العيب (قيمة المبيع) عادة فما عده التجار في عرفهم منقصا أنيط الحكم به وما لا فلا والعيب (كمرضه) على جميع حالاته في جميع الحيوانات (وفقد عضوا) كإصبع (وسن أو زيادتهما وزنا الرقيق) إذا بلغ عشرا من عبد أو أمة (وسرقته) وشربه مسكرا (وإباقه وبوله في الفراش) وكونه أعسر لايعمل بيمينه عملها المعتاد وعدم ختان ذكر كبير وعثرة مركوب وحرنه نحوه وبخر وحول وخرس وطرش وكلف وقرع

وحمل أمة وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفا وكونها ينزلها الجند لاسقوط آيات يسيرة بمصحف ونحوه ولا حمى ولا صداع يسيرين ولا ثيوبة أو كفر أو عدم حيض

ج ٢ - ص ٨٣

ولا معرفة غناء (فإذا علم المشتري العيب بعد العقد أمسكه بأرشه) إن شاء لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن ومع العيب فات جزء من المبيع فله الرجوع ببدله (وهو)

أي الأرش (قسط ما بين قيمة الصحة والعيب) فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن فإن قوم صحيحا بعشرة ومعيبا بثمانية رجع بخمس الثمن قليلا كان أو كثيرا وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلي فضة بزنته دراهم أمسك مجانا إن شاء (أو رده وأخذ الثمن) المدفوع

للبائع وكذا لو أبرأ المشتري من الثمن أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن علي البائع وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له إلا في مكيل ونحوه تعيب قبل قبضه (وإن تلف المبيع) المعيب (أو عتق العبد) أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسج أو وهب المبيع أو باعه أو بعضه (تعين الأرش) لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه عن المشتري فمات المبيع أو أبق ذهب على

ب البائع لأنه غره ورد للمشتري ماأخذه (وإن اشترى مالم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه وإن رده رد أرش كسره) الذي تبقى له معه قيمة وأخذ ثمنه لأن عقد البيع يقتضي السلامة ويتعين أرش مع كسر لاتبقى معه قيمة (وإن كان) المبيع (كبيض دجاج) فكسره فوجده فاسدا (رجع بكل الثمن) لأنا تبينا فساد العقد من أصله لكونه وقع على مالا نفع فيه وليس عليه رد فاسد إلى بائعه لعدم الفائدة فيه (وخيار عيب متراخ) لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير (مالم يوجد دليل الرضى) كتصرف فيه بإجارة أو إعارة أو نحوهما عالما بعيبه واستعماله لغير تجربة (ولا يفتقر) الفسخ للعيب (إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه)

أي البائع كالطلاق ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر (وإن اختلفا) أي البائع والمشتري في معيب (عند من حدث العيب) مع الاحتمال (فقول مشتر مع يمينه)

إن لم يخرج عن يده لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت فكان القول قول من ينفيه فيحلف أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ماحدث عنده ويرده (وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما) كالأصبع الزائدة والجرح الطري الذي لايحتمل أن يكون قبل العقد (قبل قول المشتري) في المثال الأول والبائع في المثال الثاني

(بلا يمين) لعدم الحاجة إليه ويقبل قول البائع أن المبيع المعيب ليس المردود إلا في خيار شرط فقول مشتر وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده وقول مشتر في عيب ثمن معين بعقد

ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه (السادس) من أقسام الخيار (خيار في البيع بتخيير الثمن متى بان) الثمن (أقل أو أكثر) مما أخبره به (ويثبت) في أنواعه الأربعة (في التولية) وهو بيع برأس المال (و) في (الشركة) وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن وأشركتك ينصرف إلى نصفه (و) في (المرابحة) وهي بيعه بثمنه وربح معلوم وإن قال على أن أربح في كل عشرة درهما كره (و) في (المواضعة) وهي بيعه برأس ماله

وخسران معلوم (ولابد في جميعها) أي الصور الأربعة (من معرفه المشتري) والبائع (رأس المال) لأن ذلك شرط لصحة البيع فإن فات لم يصح وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع فيه المقنع وهو رواية والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة وينقصه

في مواضعه ولا خيار للمشتري ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة (وإن اشترى) السلعة (بثمن مؤجل أو) اشترى (ممن لاتقبل شهادته له) كأبيه وابنه وزوجته (أو) اشترى شيئا (بأكثر من ثمنه حيلة) أو محاباة

لرغبة تخصه أو موسم فات (أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن) الذي اشتراها به (ولم يبين ذلك) للمشتري (في تخييره بالثمن فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد) كالتدليس والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار لزوال الضرر كما في الإقناع و المنتهى (وما يزاد في ثمن أو يحط منه) أي من الثمن (في مدة خيار) مجلس أو شرط (أو يؤخذ أرش العيب أو الجناية عليه) أي على المبيع ولو بعد لزوم البيع (يلحق برأس ماله و) يجب أن (يخبر به) كأصله وكذا مايزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص

منه في مدة خيار فيلحق بعقد (وإن كان ذلك) أي ماذكر من زيادة أو حط (بعد لزوم البيع) بفوات الخيارين (لم يلحق به) أي بالعقد فلا يلزم أن يخبر به ويخبر بأرش العيب والجناية عليه مطلقا لأنه بدل جزء من المبيع لا إن جنى المبيع ففداه المشتري لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة (وإن أخبر بالحال) بأن يقول اشتريته بكذا أو زدته أو نقصته كذا ونحوه (فحسن) لأنه أبلغ في الصدق ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء واستخدام ووطء إن لم ينقصه وإن اشترى شيئا بعشرة مثلا وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيله أو مخزنه أخبر بالحال ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل علي بكذا وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لاعلى رأس ماليهما (السابع) من أقسام الخيار (خيار) يثبت (لاختلاف المتبايعين) في الجملة (فإذا اختلفا) هما أو ورثتهما أو أحدهما أو ورثة الآخر (في قدر الثمن) بأن قال

بائع بعتكه بمائة وقال مشتر بثمانين ولا بينة لهما أو تعارضت بينتاهما (تحالفا) ولو كانت السلعة تالفة (فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا) وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين (ولكل) من المتبايعين بعد التحالف (الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر) وكذا إجارة وإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما ونكل الآخر أقر العقد (فإن كانت السلعة) التي فسخ البيع فيها بعد التحالف (تالفة رجعا إلى قيمة مثلها) ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم وفي قدر المبيع (فإن اختلفا في صفتها) أي صفة السلعة التالفة بأن قال البائع كان العبد كاتبا وأنكره المشتري (فقول مشتر) لأنه غارم وإذا تحالفا في الإجارة وفسخت بعد

فراغ المدة فأجرة المثل وفي أثنائها بالقسط (وإذا فسخ العقد) بعد التحالف (انفسخ ظاهرا وباطنا) في حق كل منهما كالرد بالعيب (وإن اختلفا في أجل) بأن يقول المشتري اشتريته بكذا مؤجلا وأنكره البائع (أو) اختلفا في (شرط) صحيح أو فاسد كرهن أو ضمين أو قدرهما (فقول من ينفيه) بيمينه لأن الأصل عدمه (وإن اختلفا في عين المبيع) كبعتني هذا العبد قال بل هذه الجارية تحالفا وبطل أي فسخ (البيع) كما لو اختلفا في الثمن وعنه القول قول بائع بيمينه لأنه كالغارم وهو المذهب وجزم به في الإقناع و المنتهى وغيرهما وكذا

لو اختلفا في قدر المبيع وإن سميا نقدا واختلفا في صفته أخذ نقد البلد ثم غالبه رواجا ثم الوسط إن استوت (وإن أبى كل منهما تسليم مابيده) من المبيع

والثمن (حتى قبض العوض) بأن قال البائع لاأسلم المبيع حتى أقبض الثمن وقال المشتري لاأسلم الثمن حتى أستلم المبيع (والثمن عين) أي معين (نصب عدل) أي نصبه الحاكم (يقبض منهما) المبيع والثمن (ويسلم المبيع) للمشتري (ثم الثمن) للبائع بجريان عادة الناس بذلك (وإن كان) الثمن (دينا حالا أجبر بائع) على تسليم المبيع لتعلق حق المشتري بعينه (ثم) أجبر (مشتر إن كان الثمن في المجلس) لوجوب دفعه عليه فورا لتمكينه منه (وإن كان) دينا (غائبا في البلد) أو فيما دون مسافة القصر (حجر عليه) أي على المشتري (في المبيع وبقية ماله حتى يحضره) خوفا من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع (وإن كان) المال (غائبا بعيدا) مسافة القصر أو غيبة بمسافة القصر (عنها) أي عن البلد (والمشتري معسر) يعني وظهر أن المشتري معسر (فللبائع الفسخ) لتعذر الثمن عليه كما لو كان المشتري مفلسا وكذا مؤجر بنقد حال (ويثبت الخيار للخلف في الصفة) إذا باعه شيئا موصوفا (ولتغير ما تقدمت رؤيته) العقد وبذلك تمت أقسام الخيار ثمانية %

فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه ومايحصل به قبضه

+ (ومن اشترى مكيلا ونحوه) وهو الموزون والمعدود والمذروع (صح) البيع (ولزم بالعقد) حيث لا خيار (ولم يصح تصرفه فيه) ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة (حتى يقبضه) لقوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه متف عليه ويصح عتقه وجعله مهرا أوعوض خلع

ووصيته به وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح التصرف فيه قبل قبضه لقول ابن عمر رضي الله عنهما مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المشتري (وإن تلف) المبيع بكيل ونحوه أو بعضه (قبل قبضه فمن ضمان البائع) وكذا لو تعيب قبل قبضه (وإن تلف) المبيع المذكور (بآفة سماوية) لا صنع لآدمي فيها (بطل) أي انفسخ (البيع) وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن (وإن أتلفه) أي المبيع بكيل أو نحوه (آدمي) سواء كان هو البائع أو أجنبيا (خير مشتر بين فسخ) البيع ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه (و) بين (إمضاء ومطالبة متلفه ببدله) أي بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما وإن تلف بفعل مشتر فلا خيار له لأن إتلافه

كقبضه (وما عداه) أي عدا ما اشترى بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالعبد والدار (يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه) لقول ابن عمر كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم

فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يفترقا وبينهما شيء رواه الخمسة إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه (وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه) أي ضمان المشتري لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه وهذا (مالم يمنعه بائع من قبضه) فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب والثمر على الشجر والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع ومن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه (ويحصل قبض ما بيع بكيل) بالكيل (أو) بيع ب (وزن) بالوزن (أو) بيع ب (عد) بالعد (أو) بيع ب (ذرع ذلك) الذرع لحديث عثمان يرفعه إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل رواه الإمام وشرطه

حضور مستحق أو نائبه ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق ومؤنة كيال ووزان وعداد ونحوه على باذل ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ (و) يحصل (القبض في صبرة وما ينقل) كثياب وحيوان (بنقله و) يحصل القبض

في (ما يتناول) كالجواهر والأثمان (بتناوله) إذ العرف فيه ذلك (وغيره) أي غير ما ذكر كالعقار والثمرة على الشجر قبضه (بتخليته) بلا حائل بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه وإن كان فيها متاع للبائع قاله الزركشي ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه (والإقالة) مستحبة لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا من أقال مسلما أقال الله عز وجل عثرته يوم القيامة وهي (فسخ) لأنها عبارة عن الرفع والإزالة يقال أقالك الله عثرتك أي أزالها فكانت فسخا للبيع لا بيعا (فتجوز قبل قبض المبيع) ولو نحو مكيل

ولا تجوز إلا (بمثل الثمن) الأول قدرا ونوعا لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له وتجوز بعد نداء الجمعة ولا يلزم إعادة كيل أو وزن وتصح من مضارب وشريك وبلفظ صلح وبيع ومعاطاة ولا يحنث بها من حلف لا يبيع (ولا خيار فيها) أي لا يثبت في الإقالة خيار مجلس ولا خيار شرط أو نحوه (ولا شفعة) فيها لأنها ليست بيعا ولا تصح مع تلف مثمن أو موت عاقد ولا بزيادة على ثمن أو نقصه أو غير جنسه ومؤونة رد مبيع تقايلاه على بائع

3 باب الربا والصرف

+ الربا مقصور وهو لغة الزيادة لقوله تعالى ﴿ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ﴾ أي علت وشرعا زيادة في شيء مخصوص والإجماع على تحريمه لقوله تعالى ﴿ وحرم الربا ﴾

والصرف بيع نقد بنقد قيل سمي به لصريفهما وهو تصويتهما في الميزان وقيل لانصرافهما عن مقتضى البيعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه والربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة ربا الفضل (ويحرم ربا الفضل في) كل (مكيل)

بيع بجنسه مطعوما كان كالبر أو غيره كالأشنان (و) في كل (موزون بيع بجنسه) مطعوما كان كالسكر أو لا كالكتان لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالعشير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد رواه أحمد ومسلم ولا ربا في ماء ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعة

كفلوس غير ذهب وفضة ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كبيض وجوز (ويجب فيه) أي يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل (الحلول والقبض) من الجانبين بالمجلس لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق يدا بيد (ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا) فلا يباع بجنسه وزنا ولو تمرة بتمرة (ولا) يباع (موزون بجنسه إلا وزنا) فلا يصح كيلا لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل رواه الأثرم من حديث عبادة بن الصامت ولأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل والجهل به كالعلم بالتفاضل ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكانا سواء صح (ولا) يباع (بعضه) أي بعض المكيل والموزون (ببعض) من جنسه) (جزافا) لما تقدم ما لم يعلما تساويهما في المعيار الشرعي فلو باعه صبرة بأخرى وعلما كيلهما وتساويهما أو تبايعاهما مثلا بمثل وكيلتا فكانتا سواء صح وكذا زبرة حديد بأخرى من جنسها (فإن اختلف الجنس) كبر بشعير وحديد

بنحاس (جازت الثلاثة) أي الكيل والوزن والجزاف لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم وأبو داود (والجنس ماله اسم خاص يشمل أنواعا) فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها وقد يكون النوع جنسا وبالعكس والمراد هنا الجنس الأخص والنوع الأخص وكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس وقد مثله بقوله (كبر ونحوه) من شعير وتمر وملح (وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس) لأن الفرع يتبع الأصل فلما كانت أصول هذه أجناسا وجب أن تكون هذه أجناساً فدقيق الحنطة جنس ودقيق الذرة جنس وكذا البواقي (واللحم أجناس باختلاف أصوله) لأنه فرع

أصول هي أجناس فكان أجناسا كالأخباز والضأن والمعز جنس واحد ولحم البقر والجواميس جنس ولحم الإبل جنس وهكذا (وكذا اللبن) أجناس باختلاف أصوله لما تقدم (واللحم والشحم والكبد) والقلب والألية والطحال والرئة والكارع (أجناس) لأنها مختلفة في الاسم والخلقة فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلا (ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه) لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان (ويصح) بيع اللحم بحيوان من (غير جنسه) كلحم ضأن ببقرة لأنه ليس أصله ولا جنسه فجاز كما لو بيع بغير مأكول (ولا يجوز بيع حب) كبر (بدقيقه ولا سويقه) لتعذر التساوي لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن واالنار قد أخذت من السويق وإن بيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسه صح لعدم اعتبار التساوي إذا (و) لا بيع (نيئه بمطبوخه) كالحنطة بالهريسة أو الخبز بالنشاء لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ فلا يحصل التساوي (و) لا بيع (أصله بعصيره) كزيتون بزيت وسمسم بشيرج وعنب بعصيره (و) لا بيع (خالصه بمشوبه) كحنطة فيها شعير بخالصة ولبن مشوب بخالص لانتفاء التساوي المشترط إلا

أن يكون الخلط يسيرا وكذا بيع اللبن بالكشك ولا بيع الهريسة والحريرة والفالوذج والسنبوسك بعضه ببعض ولا بيع نوع منها بنوع آخر (و) ولا بيع (رطبه بيابسه) كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب لما روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك (ويجوز بيع دقيقه) أي دقيق الربوي (بدقيقه إذا استويا في النعومة) لأنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان (و) يجوز بيع (مطبوخه بمطبوخه) كسمن بقري بسمن بقري مثلا بمثل (و) يجوز بيع (خبزه بخبزه إذا استويا في النشاف) فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر لم يحصل التساوي المشترط ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن كالنشاف لأنه يقدر به عادة ولا يمكن كيله لكن إن يبس ودق وصار فتيتا بيع بمثله كيلا (و) يباع) عصيره بعصيره) كماء عنب بماء عنب (ورطبه برطبه) كالرطب والعنب بمثله لتساويهما ولا يصح بيع المحاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير جنسه ولا بيع المزابنة وهي بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العرايا بأن يبيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا فيما دون خمسة أو سق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه بشرط

الحلول والتقابض قبل التفرق ففي نخل بتخليته وفي تمر بكيل ولايصح في بقية الثمار (ولا يباع ربوي بجنسه ومعه) أي مع أحد العوضين (أو معهما من غير جنسه) كمد عجوة ودرهم بدرهمين أو بمدي عجوة أو بمد ودرهم لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم

لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله فوجوده كعدمه (ولا) يباع (تمر بلا نوى بما) أي بتمر (فيه نوى) لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه وكذا لو نزع النوى

ثم باع التمر والنوى بتمر ونوى (ويباع النوى بتمر فيه نوى و) يباع (لبن و) يباع (صوف بشاة ذات لبن وصوف) لأن النوى في التمر واللبن والصوف في الشاة غير مقصود كدار مموه سقفها بذهب صح وكذا درهم فيه نحاس بمثله أو بنحاس ونخلة عليها تمر بمثلها أو بتمر ويصح بيع نوعي جنس بنوعيه أو نوعه كحنطة حمراء وسوداء ببيضاء وتمر معقلي وبرني بإبراهيمي وصيحاني (ومرد) أي مرجع (الكيل لعرف المدينة) على عهد رسول الله

صلى الله عليه وسلم (و) مرجع (الوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم) لما روى عبد الملك بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة (وما لا عرف له هناك) أي بالمدينة ومكة (اعتبر عرفه في موضعه) لأن ما لا عرف له في الشرع برجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب فإن لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز وكل مائع مكيل ويجوز التعامل بكيل لم يعهد %

فصل في ربا النسيئة

+ (ويحرم ربا النسيئة) من النساء بالمد وهو التأخير (في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل) وهي الكيل والوزن (ليس أحدهما) أي أحد الجنسين (نقدا) فإن كان أحدهما نقدا كحديد بذهب أو فضة جاز النساء وإلا لا نسد باب السلم في الموزونات غالبا إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض واختار ابن عقيل وغيره لا وتبعه في الإقناع (كالمكيلين والموزونين) ولو من جنسين فإذا بيع بر بشعير أو حديد بنحاس اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق (وإن تفرقا قبل القبض بطل) العقد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد والمراد به القبض

(وإن باع مكيلا بموزون) أو عكسه (جاز التفرق قبل القبض) وجاز (النساء) لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل أشبه الثياب بالحيوان (وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء) لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة رواه أحمد والدار قطني وصححه

وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى (ولا يجوز بيع الدين بالدين) حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالىء بالكاليء وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق وجعله رأس مال سلم %

فصل

+ (ومتى افترق المتصارفان) بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس (قبل قبض الكل) أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين (أو) قبل قبض (البعض) منه (بطل العقد فيما لم يقبض) سواء كان الكل أو البعض لأن القبض شرط لصحة العقد لقوله صلى الله عليه وسلم وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما ولو مشيا إلى منزل أحدهما

مصطحبين صح وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس كقبض موكله ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد (والدراهم والدنانير تتعين بالتتعين في العقد) لأنها عوض مشار إليه في العقد فوجب أن تتعين كسائر الأعواض (فلا تتبدل) بل يلزمه تسليمها إذا طولب بها لوقوع العقد على عينها (فإن وجدها مغصوبة

بطل) العقد كالمبيع إذا ظهر مستحقا وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد (و) إن وجدها (معيبة من جنسها) كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة (أمسك) بلا أرش إن تعاقدا على مثلين كدرهم فضة بمثله وإلا فله أخذه في المجلس وكذا بعده من غير مجلس (أورد) العقد للعيب وإن وجدها معيبة من غير جنسها كما لو وجد الدراهم نحاسا بطل العقد لأنه باعه غير ما سمى له (ويحرم الربا بين المسلم والحربي) بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم ما تقدم من الأدلة (و) يحرم الربا (بين المسلمين مطلقا بدار إسلام أو حرب) لما تقدم إلا بين سيد ورقيقه وإذا كان له على آخر

دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز لأنه بيع دين بدين وإن قبض أحدهما من الآخر ماله عليه ثم صارفه بعين وذمة صح

4 باب بيع الأصول والثمار

+ الأصول جمع أصل وهو ما يتفرع عنه غيره والمراد هنا الدور والأرض والشجر والثمار جمع ثمر كجبل وجبال وواحد الثمر ثمرة (إذا باع دارا) أو وهبها

أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها (شمل) العقد (أرضها) أي إذا كانت الأرض يصح بيعها فإن لم يجز كسواد العراق فلا (و) شمل (بناءها وسقفها) لأنهما داخلان في مسمى الدار (و) شمل (الباب المنصوب) وحلقته (والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة) والرحى المنصوبة لأنه متصل بها لمصلحتها

أشبه الحيطان وكذا المعدن الجامد وما فيها من شجر وعرش (دون ما هو مودع فيها من كنز) وهو المال المدفون (وحجر) مدفون (ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح) ومعدن جار وماء نبع وحجر رحى فوقاني لأنه غير متصل بها واللفظ لا يتناوله ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة أو المعصرة دخل الفوقاني كالتحتاني (وإن باع أرضا) أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر أو أوصى بها (ولو لم يقل بحقوقها شمل) العقد (غرسها وبناءها) لأنهما من حقوقها وكذا أن باع ونحوه بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط (وإن كان فيها زرع) لا يحصد إلا مرة (كبر وشعير فلبائع) ونحوه (مبقى) إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه مشتر (وإن كان) الزرع (يجز) مرارا كرطبة

وبقول (أو يلتقط مرارا) كقثاء وباذنجان وكذا نحو ورد (فأصوله للمشتري) لأنها تراد للبقاء فهي كالشجرة (والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع) وكذا زهر تفتح لأنه كالثمر المؤبر وعلى البائع قطعها في الحال (وإن اشترط المشتري ذلك صح) الشرط وكان له كالثمر المؤبر إذا اشترطه مشتري الشجر ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وتمر كما لو جهل وجودهما ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة %

فصل في بيع الفاكهة والثمرالثمرة

+ (ومن باع) أو وهب أو رهن (نخلا تشقق طلعه) ولو لم يؤبر (ف) الثمر (لبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر) ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع متفق عليه والتأبير التلقيح وإنما نص عليه والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا وكذا لو صالح بالنخل أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خلع بخلاف وقف

ووصية فإن الثمرة تدخل فيهما أبرت أو لم تؤبر كفسخ لعيب ونحوه (وكذلك) أي كالنخل (شجر العنب والتوت والرمان وغيره) كجميز من كل شجر لا قشر على ثمرته فإذا بيع ونحوه بعد ظهور الثمرة كانت للبائع ونحوه (و) كذا (ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه) جمع كم وهو الغلاف (كالورد) والبنفسج (والقطن) الذي يحمل في كل سنة لأن ذلك كله بمثابة

تشقق الطلع (وما قبل ذلك) أي قبل التشقق في الطلع والظهور في نحو العنب والتوت والمشمش والخروج من الأكمام في نحو الورد والقطن (والورق فلمشتر) ونحوه لمفهوم الحديث السابق في النخل وما عداه بالقياس عليه وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع وغيره لمشتر إلا في شجرة فالكل لبائع ونحوه ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر

(ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه) لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع متفق عليه والنهي يقتضي الفساد (ولا يباع (زرع قبل اشتداد حبه) لما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري (ولا) تباع (رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل) أي منفردة عن أصولها لأن ما في الأرض مستور مغيب وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة فإن بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله أو الزرع الأخضر بأرضه أو بيعا لمالك أصلهما أو بيع قثاء ونحوه مع أصله صح البيع لأن الثمر إذا بيع مع الشجر والزرع إذا بيع مع الأرض دخلا تبعا في البيع فلم يضر احتمال الغرر

وإذا بيعا لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال (إلا) إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه (بشرط القطع في الحال) فيصح إن انتفع بهما لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة وهذا مأمون فيما يقطع (أو) إلا إذا باع الرطبة والبقول (جزة) موجودة ف (جزة) فيصح لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر (أو) إلا إذا باع القثاء ونحوها (لقطة) موجودة لما تقدم وما لم يخلق لم يجز بيعه (والحصاد) لزرع والجذاذ لثمر (واللقاط) لقثاء ونحوها (على المشتري) لأنه نقل لملكه وتفريغ لملك البائع عنه فهو كنقل الطعام (وإن باعه) أي الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع قبل اشتداد حبه أو القثاء ونحوه (مطلقا) أي من غير ذكر قطع ولا تبقية لم يصح

البيع لما تقدم (أو) باعه ذلك (بشرط البقاء) لم يصح البيع لما تقدم (أو اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا) صلاحه بطل البيع بزيادته لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع ثم ترك حتى اشتد حبه (أو) اشترى (جزة) ظاهرة من بقل أو رطبة (أو) اشترى (لقطة) ظاهرة من قثاء ونحوها ثم تركهما (فنمتا) بطل البيع لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها والقثاء بغير شروط القطع (أو اشترى ما بدا صلاحه) من ثمر (وحصل) معه (آخر واشتبها) بطل البيع قدمه في المقنع وغيره والصحيح أن البيع صحيح وأن علم قدر الثمرة الحادثة دفع البائع والباقي للمشتري وإلا اصطلحا ولا يبطل البيع لأن المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه والفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم (أو) اشترى رطبا (عرية) وتقدمت صورتها في الربا فتركها (فأتمرت) أي صارت تمرا (بطل) البيع لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب فإذا أتمر تبينا عدم الحاجة سواء كانت الترك لعذر أو لا (والكل) أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق (للبائع) لفساد) البيع (وإذا بدا) أي ظهر (ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه) أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب (مطلقا) أي من غير شرط (و) جاز بيعه (بشرط التبقية) أي تبقية الثمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد لأمن العاهة ببدو الصلاح (

وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ) وله قطعه في الحال وله بيعه قبل جذه (ويلزم البائع سقيه)

بسقي الشجر الذي هو عليها (إن احتاج إلى ذلك) أي إلى السقي وكذا لو لم يحتاج إليه لأنه يجب عليه تسليمه كاملا فلزمه سقيه (وإن تضرر الأصل) بالسقي ويجبر عليه إن أبى بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع فإنه لا يلزم المشتري سقيها لأن البائع لم يملكها من جهته (وإن تلفت) ثمرة بيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها (بآفة سماوية) وهي ما لا صنع لآدمي فيها كالريح والحر والعطش (رجع) ولو بعد القبض (على البائع) لحديث جابر

إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح رواه مسلم ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط فات على المشتري (وإن أتلفه) أي الثمر المبيع على ما تقدم (آدمي) ولو البائع (خير مشتر بين الفسخ) ومطالبة البائع بما دفع من الثمن (والإمضاء) أي البقاء على البيع (ومطالبة المتلف) بالبدل (وصلاح بعض) ثمرة (الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان) لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق (وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر) لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو قيل لأنس وما زهوها قال تحمار أو تصفار (وفي العنب أن يتموه حلوا) لقول أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود رواه أحمد ورواته ثقاه قاله في المبدع (وفي بقية الثمرات) كالتفاح والبطيخ (أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله) لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب متفق عليه والصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة وفي حب أن يشتد أو يبيض (ومن باع عبدا) أو أمة (له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري) لحديث

ابن عمر مرفوعا من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع) رواه مسلم (فإن كان قصده) أي المشتري (المال) الذي مع العبد (اشترط علمه) أي العلم بالمال (وسائر شروط البيع) لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إليه عينا أخرى (وإلا) يكن قصده المال (فلا) يشترط له شروط البيع وصح شرطه ولو كان مجهولا لأنه دخل تبعا أشبه أساسات الحيطان وسواء كان مثل الثمن أو فوقه أو دونه وإذا اشترط مال العبد ثم رده بإقالة أو غيرها رده معه (وثياب الجمال) التي على العبد المبيع (للبائع) لأنها زيادة على العادة ولا يتعلق بها حاجة العبد (و) ثياب لبس (العادة للمشتري) لجريان العادة ببيعها معه ويشمل بيع دابة كفرس لجاما ومقودا ونعلا

باب السلم

+ هو لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه (وهو) شرعا (عقد على موصوف) ينضبط

بالصفة (في الذمة) فلا يصح في عين كهذه الدار (مؤجل) بأجل معلوم (بثمن مقبوض بمجلس العقد) وهو جائز بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه (ويصح) السلم (بألفاظ البيع) لأنه بيع حقيقة (و) بلفظ (السلم والسلف) لأنهما حقيقة فيه إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه و أجل مثمنه (بشروط سبعة) زائدة على شروط البيع والجار متعلق ب يصح (أحدها انضباط صفاته) التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشاقة (بمكيل) أي كمكيل من حبوب وثمار وخل ودهن ولبن ونحوها (وموزون) من قطن وحرير وصوف ونحاس وزئبق وشب وكبريت وشحم ولحم نيء ولو مع عظمه إن عين موضع قطعه (ومذروع) من ثياب وخيوط

(فأما المعدود المختلف كالفواكه) المعدودة كرمان فلا يصح السلم فيه لاختلافه بالصغر والكبر (و) ك (البقول) لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم (و) ك (الجلود) لأنها تختلف ولا يمكن ذرعها لاختلاف الأطراف (و) ك (الرؤوس) والأكارع لأن أكثر ذلك ل العظام والمشافر (و) ك (الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس) لاختلافها (و) ك (الجواهر) واللؤلؤ والعقيق ونحوه لأنها تختلف اختلافا متباينا بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء والصفاء (و) ك (الحامل من الحيوان) كأمة حامل لأن الصفة لا تأتي على ذلك والولد مجهول غير محقق وكذا لو أسلم في أمة وولدها لندرة جمعهما الصفة (وكل مغشوش) لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه فإن كانت الأثمان خالصة صح

السلم فيها ويكون رأس المال غيرها ويصح السلم في فلوس ويكون رأس المال عرضا (وما يجمع أخلاطا) مقصودة (غير متميزة كالغالية) والند (والمعاجين) التي يتداوى بها (فلا يصح السلم فيه) لعدم انضباطه (ويصح) السلم (في الحيوان) ولو آدميا لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا رواه مسلم (و) يصح أيضا في (الثياب المنسوجة من نوعين) كالكتان والقطن ونحوهما لأن ضبطها ممكن وكذا نشاب ونبل مريشان وخفاف ورماح

(و) يصح أيضا في (ما خلطه) بكسر الخاء (غير مقصود كالجبن) فيه المنفخة (وخل التمر) فيه الماء (والسكنجبين) فيه الخل (ونحوها) كالشيرج والخبز والعجين الشرط (الثاني ذكر الجنس والنوع) أي جنس المسلم فيه ونوعه (وكل وصف يختلف به) أي بسببه (الثمن) اختلافا (ظاهرا) كلونه وقدره وبلده (وحداثته وقدمه) ولا يجب استقصاء كل الصفات لأنه قد يتعذر ولا ما لا يختلف

به الثمن لعدم الاحتياج إليه (ولا يصح شرط) المتعاقدين (الأردأ أو الأجود) لأنه لا ينحصر إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أردأ أو أجود منه (بل) يصح شرط (جيد ورديء) ويجزئ ما صدق عليه أنه جيد أو رديء فينزل الوصف على أقل درجة (فإن جاء) المسلم إليه (بما شرط) للمسلم لزمه أخذه (أو) جاءه ب (أجود منه) أي من المسلم فيه (من نوعه ولو قبل محله) أي حلوله (ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه) إلا أنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه وإن جاءه بدون ما وصف أو بغير نوعه من جنسه فله أخذه ولا يلزمه وإن جاء

بجنس أخر لم يجز له قبوله وإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبا فله رده وإمساكه مع الأرش الشرط (الثالث ذكر قدره) أي قدر المسلم فيه (بكيل) معهود فيما يكال (أو وزن) معهود فيما يوزن لحديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه (أو ذرع يعلم) عند العامة لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به عند التلف فيفوت العلم بالمسلم فيه فإن شرطا مكيالا غير معلوم بعينه أو صنجة غير معلومة بعينها لم يصح وإن كان معلوما صح السلم دون التعيين (وإن أسلم في المكيل) كالبر والشيرج (وزنا أو في الموزون)

كالحديد (كيلا لم يصح) السلم لأنه قدره بغير ما هو مقدر به فلم يجز كما لو أسلم في المذروع وزنا ولا يصح في فواكه معدودة كرمان وسفرجل ولو وزنا الشرط (الرابع ذكر أجل معلوم) للحديث السابق ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه ويعتبر أن يكون الأجل (له وقع في الثمن) عادة كشهر

(فلا يصح) السلم إن أسلم (حالا) لما سبق (ولا) إن أسلم إلى أجل مجهول ك (إلى الحصاد والجذاذ) وقدوم الحاج لأنه يختلف فلم يكن معلوما (ولا) يصح السلم (إلى) أجل قريب ك (يوم) ونحوه لأنه لا وقع له في الثمن (إلا) أن يسلم (في شيء يأخذه منه كل يوم) أجزاء معلومة (كخبز ولحم ونحوهما) من كل ما يصح السلم فيه إذا الحاجة داعية إلى ذلك فإن قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن ولا يجعل الباقي فضلا على المقبوض لتماثل أجزائه بل يقسط عليهما بالتسوية الشرط (الخامس أن يوجد) المسلم فيه (غالبا في محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله لوجوب تسليمه إذا فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء لم يصح (و) يعتبر أيضا وجود المسلم فيه في (مكان الوفاء) غالبا فلا يصح أن أسلم في ثمرة بستان صغير معين أو قرية صغيرة أو في نتاج من فحل بني فلان أو غنمه أو مثل هذا الثوب لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه و (لا)

يعتبر وجود المسلم فيه (وقت العقد) لأنه ليس وقت وجوب التسليم (فإن) أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا ف (تعذر) المسلم فيه بأن لم تحمل الثمار تلك السنة (أو) تعذر (بعضه فله) أي لرب السلم (الصبر) إلى أن يوجد فيطالب به (أو فسخ) العقد في (الكل) إن تعذر الكل (أو) في (البعض) المتعذر (ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه) أي عوض الثمن التالف لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن ويجب رد عينه إن كان باقيا أو عوضه إن كان تالفا أي مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما هذا إن فسخ في الكل فإن فسخ في البعض فبقسطه الشرط (السادس أن يقبض الثمن تاما) لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف الحديث أي فليعط قال الشافعي لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه ويشترط أن يكون رأس مال السلم (معلوما قدره ووصفه) كالمسلم فيه فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة ويكون القبض (قبل التفرق) من المجلس وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر لأن السلم من شرطه التأجيل (وإن قبض البعض) من الثمن

في المجلس (ثم افترقا) قبل قبض الباقي (بطل فيما عداه) أي عدا المقبوض وصح في المقبوض ولو جعل دينا سلما لم يصح وأمانة أو عينا مغصوبة أو عارية يصح لأنه في معنى القبض (وإن أسلم) ثمنا واحدا (في جنس) كبير (إلى أجلين) كرجب وشعبان مثلا (أو عكسه) بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلا (صح) السلم (إن بين) قدر (كل جنس وثمنه) في المسألة الثانية بأن يقول أسلمتك دينارين أحدهما في أردب قمح صفته كذا وأجله كذا والثاني في أردبين شعيرا صفته كذا والأجل كذا (و) يصح أيضا إن بين (قسط كل أجل) في المسألة الأولى بأن يقول أسلمتك دينارين أحدهما في أردب قمح إلى رجب والآخر في أردب وربع مثلا إلى شعبان فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول

الشرط (السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح) السلم (في عين) كدار أو شجرة لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها (و) لا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكره بل (يجب الوفاء موضع العقد) لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه وله أخذه في غيره إن رضيا ولو قال خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجز (ويصح شرطه) أي الوفاء (في غيره) أي غير مكان العقد لأنه بيع فصح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان وإن شرطا الوفاء في موضع العقد كان تأكيدا (وإن عقد) السلم (ببر) ية (أو بحر شرطاه) أي مكان الوفاء لزوما

وإلا فسد السلم لتعذر الوفاء موضع العقد وليس بعض الأماكن أولى من بعض فاشترط تعيينه بالقول كالكيل ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه (ولا يصح بيع المسلم فيه) لمن هو عليه أو غيره (قبل قبضه) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه (ولا) تصح أيضا (هبته) لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمة (ولا الحوالة به) لأنها لا تصح إلا على دين مستقر والسلم عرضة للفسخ (ولا) الحوالة (عليه) أي على المسلم فيه أو رأس ماله بعد فسخ (ولا أخذ عوضه) لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدوما

والعوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر وتصح الإقالة في السلم (ولا يصح) أخذ (الرهن والكفيل به) أي بدين السلم رويت كراهيته عن علي وابن

عباس وابن عمر إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن حذرا من أن يصرفه إلى غيره ويصح بيع دين مستقر كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس وتصح هبة كل دين لمن هو عليه ولا يجوز لغيره وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق

باب القرض

+ بفتح القاف وحكي كسرها ومعناها لغة القطع واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع بة ويرد بدله وهو جائز بالإجماع (وهو مندوب) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة وهو مباح للمقترض وليس من المسألة المكروهة لفعله عليه الصلاة

و السلام (وما يصح بيعه) من نقد أو عوض (صح قرضه) مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا (إلا بني آدم) فلا يصح قرضهم لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها ويشترط معرفة قدر القرض ووصفه وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه ويصح بلفظه وبلفظ السلف وكل ما أدى معناهما وإن قال ملكتك ولا قرينة على رد بدل فهبة (ويملك) القرض (بقبضه) كالهبة

ويتم بالقبول وله الشراء به مقرضه (فلا يلزم رد عينه) للزومه بالقبض (بل يثبت بدله في ذمته) أي ذمة المقترض (حالا ولو أجله) المقرض لأنه عقد منع فيه من التفاضل فمنع الأجل فيه كالصرف قال الإمام القرض حال وينبغي أن يفي بوعده (فإن ردها المقترض) أي رد القرض بعينه (لزم) المقرض (قبوله) إن كان

مثليا لأنه رده على صفة حقه سواء لأنه تغير سعره أو لا حيث لم يتعيب وإن كان متقوما لم يلزم المقرض قبوله وله الطلب بالقيمة (وإن كانت) الدراهم التي وقع القرض عليها (مكسرة أو) كان القرض (فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها) أي بالدراهم المكسرة أو الفلوس (فله) أي للمقرض (القيمة وقت القرض) لأنه كالعيب فلا يلزمه قبولها وسواء كانت باقية أو استهلكها وتكون القيمة من غير جنس الدراهم وكذلك المغشوشة إذا حرمها السلطان (ويرد) المقترض (المثل) أي مثل ما اقترضه (في المثليات) لأن المثل أقرب شبها من القيمة فيجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسدت ويرد (القيمة في غيرها) من المتقومات وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه (فإن أعوز)

أي تعذر (المثل فالقيمة إذا) أي وقت إعوازه لأنها حينئذ تثبت في الذمة (ويحرم)

اشتراط (كل شرط جر نفعا) كأن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه لأنه عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه

(وإن بدأ به) أي بما فيه نفع كسكنى داره (بلا شرط) ولا مواطأة بعد الوفاء جاز لا قبله (أو أعطاه أجود) بلا شرط جاز لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء متفق عليه (أو) أعطاه (هدية بعد الوفاء جاز) لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيله إليه (وإن تبرع) المقترض (لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به) قبل القرض (لم تجز إلا أن ينوي) المقرض (مكافأته على ذلك) الشيء (أو احتسابه من دينه) فيجوز له قبوله لحديث أنس مرفوعا قال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه

قبل ذلك رواه ابن ماجه وفي سنده جهالة (وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته) الأثمان أي مثلها لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر (و) تجب (فيما لحمله مؤنة قيمته) ببلد القرض لأنه المكان الذي يجب فيه التسليم فيه ولا يلزمه المثل في البلد الآخر لأنه لا يلزمه حمله إليه (إن لم تكن) قيمته (ببلد القرض أنقص) صوابه أكثر فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر لزم مثل المثلي لعدم الضرر إذا ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر إلا فيما لا مؤنة لحمله مع أمن البلد والطريق

وإذا قال اقترض لي مائة ولك عشرة صح لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه ولو قال اضمني فيها ولك ذلك لم يجز

7 باب الرهن

+ هو لغة الثبوت والدوام يقال ماء راهن أي راكد ونعمة راهنة أي دائمة وشرعا توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها

وهو جائز بالإجماع ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما ويعتبر معرفة قدره وجنسه وصفته وكون راهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه و (يصح) الرهن (في كل عين يجوز بيعها) لأن القصد منه الاستيثاق بالدين ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذره من الراهن وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها (حتى المكاتب) لأنه لايجوز بيعه ويمكن من الكسب ما يؤديه من النجوم رهن معه وإن عجز ثبت الرهن فيه وفي كسبه وإن عتق بقي ما أداه رهنا ولا يصح شرط منعه من الصترف والمعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه وإلا صح

ويصح الرهن (مع الحق) بأن يقول بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك هذا فيقول اشتريته منك ورهنته لأن الحاجة داعية لجوازه إذا (و) يصح (بعده) أي بعد الحق بالإجماع ولا يجوز قبله لأنه وثيقة بحق فلم يجز قبل ثبوته ولأنه تابع للحق فلا يسبقه ويعتبر أن يكون (بدين ثابت) أو مآله إليه حتى على عين مضمونة كعارية ومقبوض بعقد فاسد

وتقع إجارة في ذمة لا على دين كتابة أو دية على عاقلة قبل الحلول ولا بعهده مبيع وثمن وأجرة معينين أو نفع نحو دار معينة (ويلزم) الرهن بالقبض (في حق الراهن فقط) لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن (ويصح رهن المشاع) لأنه يجوز بيعه في محل الحق ثم إن رضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز وإن اختلفا

جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة (ويجوز رهن المبيع) قبل قبضه (غير المكيل والموزون) والمذروع والمعدود (على ثمنه وغيره) عند بائعه وغيره لأنه يصح بيعه بخلاف المكيل ونحوه فإنه لا يصح بيعه قبل قبضه فكذلك رهنه (وما لا يجوز بيعه) كالوقف وأم الولد (لا يصح رهنه) لعدم حصول مقصود الرهن منه (إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع) فيصح رهنهما مع أنه لا يصح بيعهما بدونه لأن النهي عن البيع لعدم

الأمن من العاهة ولهذا أمر بوضع الجوائح وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن ويصح رهن الجارية دون ولدها وعكسه ويباعان ويختص المرتهن بما قابل الرهن من الثمن (ولا يلزم الرهن) في حق الراهن (إلا بالقبض)

كقبض المبيع لقوله تعالى ﴿ فرهان مقبوضة ﴾ ولا فرق بين المكيل وغيره وسواء كان القبض من المرتهن أو من اتفقا عليه والرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم فللراهن فسخه والتصرف فيه فإن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق بطل وبنحو إجارة أو تدبير لايبطل لأنه لا يمنع من البيع (واستدامته) أي القبض (شرط) في اللزوم للآية وكالابتداء (فإن أخرجه) المرتهن (إلى الراهن باختياره) ولو كان نيابة عنه (زال لزومه) لزوال استدامة القبض وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض ولو آجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق (فإن رده) أي رد الراهن الرهن (إليه) أي إلى المرتهن (عاد

لزومه إليه) لأنه أقبضه باختياره فلزم كالابتداء ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه ولو استعار شيئا ليرهنه جاز ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقا ومتى حل الحق ولم يقضه فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه ويرجع المعير بقيمته أو مثله وإن تلف ضمنه الراهن وهو المستعير ولو لم يفرط المرتهن (ولا ينفذ تصرف واحد منهما) أي من الراهن والمرتهن (فيه) أي في الرهن المقبوض (بغير إذن الآخر) لأنه يفوت على الآخر حقه فإن لم يتفقا على المنافع لم يجز الانتفاع وكانت معطلة وإن اتفقا على الإجارة أو الإعارة جاز ولا يمنع المرتهن الراهن من سقي شجر وتلقيح ومداواة وفصد وإنزاء فحل على مرهونة بل يمنع من قطع سلعة خطرة (إلا عتق الراهن) المرهون (فإنه يصح

مع الإثم) لأنه مبني على السراية والتغليب (وتؤخذ قيمته) حال الإعتاق من الراهن لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة وتكون (رهنا مكانها) لأنه بدل عنه وكذا لو قتله أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن أو أقر بالعتق وكذبه (ونماء الرهن)

المتصل والمنفصل كالسمن وتعلم الصنعة والولد والثمرة والصوف (وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به) أي بالرهن فيكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع (ومؤنته) أي الرهن (على الراهن) لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الشافعي والدار قطني وقال إسناده حسن صحيح (و) على الراهن أيضا (كفنه) ومؤنة تجهيزه بالمعروف لأن ذلك تابع لمؤنته (و) عليه أيضا (أجرة مخزنه) إذا كان مخزونا وأجرة حفظه (وهو أمانة في يد المرتهن) للخبر السابق ولو قبل عقد الرهن كبعد الوفاء (وإن تلف من غير تعد) ولا تفريط (منه) أي من المرتهن (فلا شيء عليه) قاله علي رضي الله عنه لأنه أمانة في يده كالوديعة فإن تعدى أو فرط ضمن (ولا يسقط بهلاكه) أي الرهن (شيء من دينه) لأنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف ولم يوجد ما يسقطه

فبقي بحاله وكما لو دفع إليه عبدا ليبيعه ويستوفي حقه من ثمنه فمات (وإن تلف بعضه) أي الرهن (فباقيه رهن بجميع الدين) لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن (ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين) لما سبق سواء كان مما تمكن قسمته أو لا ويقبل قول المرتهن في التلف وإذا ادعاه بحادث ظاهر كلف ببينه بالحادث وقبل قوله في التلف وعدم التفريط ونحوه (وتجوز الزيادة فيه) أي في الرهن بأن رهنه عبدا بمائة ثم رهنه عليها ثوبا لأنه زيادة استيثاق (دون) الزيادة في (دينه) فإذا رهنه عبدا بمائة لم يصح جعله دينا بخمسين مع المائة ولو كان يساوي ذلك لأن الرهن أشغل بالمائة الأولى والمشغول لا يشغل (وإن رهن) واحد (عند اثنين شيئا) على دين لهما (فوفى أحدهما) انفك في نصيبه لأن العقد

الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردا ثم إن طلب المقاسمة أجيب إليها إن كان الرهن مكيلا أو موزونا (أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه) لأن الرهن متعدد فإن رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف فهذه أربعة عقود ويصير كل ربع منه رهنا بمائتين وخمسين ومتى قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل فعما نواه فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء (ومتى حل الدين) لزم الراهن إذن الإيفاء كالدين الذي لا رهن به (و) إن (امتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل) الذي تحت يده الرهن (في بيعه باعه) لأنه مأذون له فيه فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن

وإن كان البائع العدل اعتبر إذن المرتهن أيضا (ووفاء الدين) لأنه المقصود بالبيع وإن فضل من ثمنه شيء فلمالكه وإن بقي شيء فعلى الراهن (وإلا) يأذن في البيع ولم يوف (أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن) لأن هذا شأن الحاكم فإن امتنع حبسه أو عذره حتى يفعل (فإن لم يفعل) أي أصر على الامتناع أو كان غائبا أو تغيب (باعه الحاكم ووفى دينه) لأنه حق تعين عليه فقام الحاكم مقامه فيه وليس للمرتهن بيعه إلا بإذن ربه أو الحاكم %

1 فصل في شروط الرهن

+ (ويكون) الرهن (عند من اتفقا عليه أمانة) فإذا اتفقا أن يكون تحت يد جائز التصرف صح وقام قبضه مقام قبض المرتهن ولا يجوز تحت يد صبي أو عبد بغير إذن سيده أو مكاتب بغير جعل إلا بإذن سيده وإن شرط جعله

بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن تتغير حاله وللوكيل رده عليهما لا على أحدهما (وإن أذنا له في البيع) أي بيع الرهن (لم يبع إلا بنقد البلد) لأن الحظ فيه لرواجه فإن تعدد باع بجنس الدين فإن عدم فبما ظناه أصلح فإن تساوت عينه حاكم وإن عينا نقدا تعين ولم تجز مخالفتهما فإن اختلفا لم يقبل قول واحد منهما ويرفع الأمر للحاكم ويأمر ببيعه بنقد البلد سواء كان من جنس الحق أو لم يكن وافق قول أحدهما أو لا (وإن) باع بإذنهما و (قبض الثمن فتلف في يده) من غير تفريط (فمن ضمان الراهن) لأن الثمن في يد العدل أمانة فهو كالوكيل (وإن ادعى)

العدل (دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة) للعدل بدفعه للمرتهن (ولم يكن) الدفع (بحضور الراهن ضمن) العدل لأنه فرط حيث لم يشهد ولأنه إنما أذن له في قضاء مبريء ولم يحصل فيرجع المرتهن على راهنه ثم هو على العدل وإن كان القضاء ببينة لم يضمن لعدم تفريطه سواء كانت البينة قائمة أو معدومة كما لو كان بحضرة الراهن لأنه لم يعد مفرطا (كوكيل) في قضاء الدين فحكمه حكم العدل فيما تقدم لأنه في معناه (وإن شرط أن لا يبيعه) المرتهن (إذا حل الدين) ففاسد لأنه شرط ينافي مقتضى العقد كشرطه

أن لا يستوفي الدين من ثمنه أو لا يباع ما خيف تلفه (أو) شرط (إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له) أي للمرتهن بدينه (لم يصح الشرط وحده) لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن) رواه الأثرم وفسره الإمام بذلك ويصح الرهن للخبر (ويقبل قول راهن في قدر الدين) بأن قال المرتهن هو رهن بألف وقال الراهن بل بمائة فقط (و) يقبل قوله أيضا في قدر (الرهن) فإذا قال المرتهن أرهنتني هذا العبد والأمة وقال الراهن بل العبد وحده فقوله لأنه منكر (و) يقبل قوله أيضا في (رده) بأن

قال المرتهن رددته إليك وأنكر الراهن فقوله لأن الأصل معه والمرتهن قبض العين لمنفعته فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر (و) يقبل قوله أيضا (في كونه عصيرا لا خمرا) في عقد شرط فيه بأن قال بعتك كذا بكذا على أن ترهنني هذا العصير وقبل على ذلك وأقبضه له ثم قال المرتهن كان خمرا فلي فسخ البيع وقال الراهن بل كان عصيرا فلا فسخ فقوله لأن الأصل السلامة (وإن أقر) الراهن (أنه) أي أن الرهن (أو) أقر (أنه) أي أن الرهن (ملك غيره) قبل على نفسه دون المرتهن فيلزمه رده للمقر له إذا انفط الرهن (جنى قبل) إقرار الراهن (على نفسه) لا على المرتهن إن كذبه لأنه متهم في حقه وقول الغير على غيره غير مقبول (وحكم بإقراره بعد فكه) أي فك الرهن بوفاء الدين أو الإبراء منه (إلا أن يصدقه المرتهن) فيبطل الرهن لوجود المقتضى السالم عن المعارض ويسلم له به %

فصل في الانتفاع بالمرهون

+ (وللمرتهن أن يركب) من الرهن (ما يركب و) أن (يحلب ما يحلب بقدر نفقته) متحريا للعدل (بلا إذن) راهن لقوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري وتسترضع الأمة بقدر نفقتها وما عدا ذلك من

الرهن لا ينتفع به إلا بإذن مالكه (وإن أنفق على) الحيوان (الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه) أي إمكان استئذانه (لم يرجع) على الراهن ولو نوى الرجوع لأنه متبرع أو مفرط حيث لم يستأذن المالك مع قدرته عليه (وإن تعذر) استئذانه وأنفق بنية الرجوع (رجع) على الراهن (ولو لم يستأذن الحاكم) لاحتياجه لحراسة حقه (وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها) فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها بالأقل مما أنفق أو أنفقه المثل (ولو خرب الرهن) إن كان دارا (فعمره) المرتهن (بلا إذن) الراهن (رجع بآلته فقط) لأنها ملكه لا بما يحفظ به مالية الدار وأجرة المعمرين لأن العمارة

ليست واجبة على الراهن فلم يكن لغيره أن ينوب عنه بخلاف نفقة الحيوان لحرمته في نفسه وإن جنى الرهن ووجب مال خير سيده بين فدائه وبيعه وتسليمه إلى ولي الجناية فيملكه فإن فداه فهو رهن بحاله وإن باعه أو سلمه

في الجناية بطل الرهن وإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن وإن جني عليه فالخصم سيده فإن أخذ الأرش كان رهنا وإن اقتص فعليه قيمة أقل العبدين الجاني والمجني عليه قيمة تكون رهنا مكانه

ج ٢ - ص ١٧٩

باب الضمان

+ مأخوذ من الضمن لأنه ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه ومعناه شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم وتحملت دينك أو ضمنته أو هو عندي ونحو ذلك

وبإشارة مفهومة من أخرس (ولا يصح) الضمان (إلا من جائز التصرف) لأنه إيجاب مال فلا يصح من صغير ولا سفيه ويصح من مفلس لأنه تصرف في ذمته ومن قن ومكاتب بإذن سيدهما ويؤخذ مما بيد مكاتب ومما يضمنه قن من سيده (ولرب الحق مطالبة من شاء منهما)

أي من المضمون والضامن (في الحياة والموت) لأن الحق ثابت في ذمتهما فملك مطالبة من شاء منهما لحديث الزعيم غارم رواه أبو داود والترمذي وحسنه (فإن برئت ذمة المضمون عنه) من الدين المضمون بإبراء أو قضاء أو حوالة ونحوها (برئت ذمة الضامن) لأنه تبع له (لا عكسه) فلا يبرأ المضمون ببراءة الضامن لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع وإذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهم بإبراء الآخر ويبرءون بإبراء المضمون عنه (ولا تعتبر معرفه الضامن) للمضمون عنه ولا) معرفته للمضمون (له) لأنه لا يعتبر رضاهما فكذا معرفتهما (بل) يعتبر (رضى الضامن) لأن الضمان تبرع بالتزام الحق فاعتبر له الرضى كالتبرع بالأعيان (ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم) لقوله تعالى

﴿ ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ﴾ وهو غير معلوم لأنه يختلف (و) يصح أيضا ما يؤول إلى الوجوب ك (العواري والمغصوب والمقبوض بسوم) إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فغير مضمون (و) يصح ضمان (عهدة مبيع) بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع أو رد بعيب أو الأرش إن خرج معيبا أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه وإن ظهر به عيب أو استحق فيصح لدعاء الحاجة إليه وألفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته أو دركه ونحوهما ويصح أيضا ضمان ما يجب بأن يضمن ما يلزمه من دين

أو ما يداينه زيد لعمرو ونحوه

@ 185 وللضامن إبطال قبل وجوبه لا (ضامن الأمانات كوديعة) ومال شركة وعين مؤجرة لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا ضامنه (بل) يصح ضمان (التعدي فيها) أي في الأمانات لأنها حينئذ تكون مضمونة على من هي بيده كالمغصوب وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع وإلا فلا وكذا كفيل وكل مؤد عن غيره دينا واجبا غير نحو زكاة

فصل في الكفالة

وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه وتنعقد بما ينعقد به ضمان

وإن ضمن معرفته أخذ به (وتصح الكفالة ب) بدن (كل) إنسان عنده (عين مضمونة) كعارية ليردها أو بدلها (و) تصح أيضا (ببدن من عليه دين) ولو جهله الكفيل لأن كلا منهما حق مالي فصحت الكفالة به كالضمان و (لا) تصح ببدن من عليه (حد) لله تعالى كالزنا أو لآدمي كالقذف لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا كفالة في حد (ولا) ببدن من عليه (قصاص)

لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني ولا بزوجة وشاهد ولا بمجهول أو إلى أجل مجهول وتصح إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا (ويعتبر رضى الكفيل)

لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه (لا) رضى (مكفول به) أو له كالضمان (فإن مات) المكفول برئ الكفيل لأن الحضور سقط عنه (أو تلفت العين بفعل الله تعالى) قبل المطالبة برئ الكفيل لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به فإن تلفت بفعل آدمي فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل (أو سلم) المكفول (نفسه برئ الكفيل) لأن الأصل أدى ما على الكفيل أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين وكذا يبرأ الكفيل إذا أسلم المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل أولا بلا ضرر في قبضه وليس ثم يد حائلة ظالمة وإن

تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ضمن ما عليه إن لم يشترط البراءة منه ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن سلم نفسه برئا

9 باب الحوالة

+ مشتقة من التحول لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى وتنعقد ب أحلتك واتبعتك بدينك على فلان ونحوه و (لا تصح) الحوالة (إلا على دين

مستقر) إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا وما ليس بمستقر عرضة للسقوط فلا تصح على مال كتابة أو سلم أو صداق قبل الدخول أو ثمن مدة خيار ونحوها وإن أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة والحوالة على ماله في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء (ولا يعتبر استقرار المحال فيه)

فإن أحال المكاتب سيده أو الزوج زوجته صح لأن له تسليمه بنفسه وحوالته تقوم مقام تسليمه (ويشترط) أيضا للحوالة (اتفاق الدينين) أي تماثلهما (جنسا) كدنانير بدنانير أو دراهم بدراهم فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه لم يصح (ووصفا) كصحاح بصحاح أو مضروبة بمثلها فإن اختلفا لم يصح (ووقتا) أي حلولا أو تأجيلا أجلا واحدا فلو كان أحدهما حالا والأخر مؤجلا أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم تصح (وقدرا) فلا يصح بخمسة على ستة لأنها إرفاق كالقرض فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها (ولا يؤثر الفاضل) في بطلان الحوالة فلو أحال بخمسة من عشرة على خمسة أو بخمسة على خمسة من عشرة صحت لاتفاق ما وقعت فيه الحوالة والفاضل باق بحاله لربه (وإذا صحت) الحوالة بأن اجتمعت شروطها نقل الحق إلى ذمة المحال عليه (وبريء المحيل) بمجرد الحوالة فلا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غيرها

وإن تراضى المحتال والمحال عليه على خير من الحق أو دونه في الصفة أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز (ويعتبر) لصحة الحوالة (رضاه) أي رضا المحيل لأن الحق عليه فلا يلزمه اداؤه من جهة الدين على المحال عليه ويعتبر أيضا علم المال وأن يكون مما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمان والحبوب ونحوها و (لا) يعتبر (رضا المحال عليه) لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه (ولا رضا المحتال) إن أحيل (على مليء) ويجبر على أتباعه لحديث أبي هريرة

برفعه مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل والمليء القادر بماله وقوله وبدنه فماله القدرة على الوفاء وقوله أن لا يكون مماطلا وبدنه إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم قاله الزركشي (وإن كان) المحال عليه (مفلسا ولم يكن) المحتال (رضي) الحوالة عليه (رجع به) أي بدينه عل المحيل لأن المفلس عيب ولم يرض به فاستحق الرجوع كالمبيع المعيب فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له إن لم يشترط الملاءة لتفريطه (ومن أحيل بثمن مبيع بأن أحال المشتري البائع به على من له عليه دين فبان البيع باطلا فلا حوالة (أو أحيل به) أي بالثمن (عليه) بأن أحال البائع على المشتري مدينه بالثمن (فبان البيع باطلا) بأن كان المبيع مستحقا أو حرا أو خمرا (فلا حوالة) لظهور أن لا ثمن على المشتري لبطلان البيع والحوالة فرع على لزوم الثمن ويبقى الحق على ما كان عليه أو لا

(وإذا فسخ البيع) بتقايل أو خيار عيب أو نحوه (لم تبطل) الحوال لأن عقد البيع لم يرتفع فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة وللمشتري الرجوع على البائع لأنه لما رد العوض استحق الرجوع بالعوض (ولهما أن يحيلا) أي للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية وإن اختلفا فقال أحلتك قال بل وكلتني أو بالعكس فقول مدعي الوكالة وإن اتفقا على أحلتك بديني وادعى أحدهما إرادة الوكالة

صدق وإن اتفقا على أحلتك بدينك فقول مدعي الحوالة وإذا طالب الدائن المدين فقال أحلت فلانا الغائب وأنكر رب المال قبل قوله مع يمينه ويعمل بالبينة

10 باب الصلح

+ هو لغة قطع المنازعة وشرعا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين والصلح في الأموال قسمان على إقرار وهو المشار إليه بقوله (إذا أقر له بدين أو عين فأسقط) عنه من الدين بعضه (أو وهبه) من العين (البعض وترك الباقي) أي لم يبرأ منه ولم يهبه (صح) لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه لأنه صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا عنه ومحل صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح فإن وقع بلفظه لم يصح لأنه صالح عن بعض ماله ببعض فهو هضم للحق

ومحله أيضا (إن لم يكن شرطاه) بأن يقول بشرط أن تعطيني كذا أو على أن تعطيني أو تعوضني كذا ويقبل على ذلك فلا يصح لأنه يقتضي المعاوضة فكأنه عاوض بعض حقه ببعض واسم يكن ضمير الشأن وفي بعض النسخ إن لم يكن شرطا أي بشرط (و) محله أيضا أن لا يمنعه حقه بدونه وإلا بطل لأنه

أكل لمال الغير بالباطل (و) محله أيضا أن لا يكون ممن (لا يصح تبرعه) كمكاتب وناظر وقف ووولي صغير ومجنون لأنه تبرع وهؤلاء لا يملكونه إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينة لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه (وإن وضع) رب دين (بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فيه) لأنه أسقط عن طيب نفسه ولا مانع من صحته ولم يصح التأجيل لأن الحال لا يتأجل وكذا لو صالحه عن مائة صحاح بخمسين مكسرة فهو إبراء من الخمسين ووعد في الآخرى ما لم يقع بلفظ الصلح فلا يصح كما تقدم (وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا) لم يصح في غير الكتابة لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز (أو بالعكس) بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا لم يصح إن كان بلفظ الصلح كما تقدم فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه صح الإسقاط دون التأجيل وتقدم (أو أقر له ببيت) ادعاه (فصالحه على سكناه) ولو مدة معينة كسنة (أو) على أن (يبني له فوقه غرفة) وصالحه على بعضه لم يصح الصلح لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته وإن فعل ذلك كان تبرعا متى شاء أخرجه وإن فعله على سبيل المصالحة معتقدا وجوبه عليه بالصلح رجع عليه بأجرة ما سكن وأخذ ما

كان بيده من الدار لأنه أخذه بعقد فاسد (أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية) أي بأنه مملوكه لم يصح (أو) صالح (امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح) الصلح لأن ذلك صلح يحل حراما لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز (وإن بذلاهما) أي دفع المدعى عليه العبودية والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضا (له) أي للمدعي (صلحا عن دعواه صح) لأنه يجوز أن يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض لأنه أكل لمال الغير بالباطل (وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل) أي فأقر بالدين (صح الإقرار) لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره و (لا) يصح (الصلح) لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق فلم يحل له أخذ العوض عليه فإن أخذ شيئا رده وإن صالحه عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بعين أو دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه صح فإن كان بنقد عن نقده فصرف وإن كان بعوض فبيع فاعتبر له ما اعتبر فيه ويصح بلفظ صلح

وما يؤدي معناه وإن كان بمنفعة كسكنى دار فإجارة وإن صالحت المعترفة بدين أو عين بتزويج نفسها صح ويكون صداقا وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض لأنه بيع دين بدين و إن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا وبجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين أو عين

بمعلوم فإن لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول

ج ٢ - ص ٢٠١

فصل

القسم الثاني صلح على إنكار وقد ذكره بقوله (ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله) أي يجهل ما ادعي به عليه (ثم صالح) عنه (بمال) حال أو مؤجل (صح) الصلح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم ومن ادعي عليه بوديعة أو تفريط فيها أو قرض فأنكر وصالح على مال فهو جائز ذكره في الشرح وغيره (وهو) أي صلح الانكار (لمدعي بيع لأنه) يعتقده عوضا عن ماله فلزمه حكم اعتقاده (يرد معيبه) أي معيب ما أخذه من العوض (ويفسخ

الصلح) كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا (ويؤخذ منه) العوض إن كان شقصا (بشفعة) لأنه بيع وإن صالح ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر (و) الصلح (للآخر) المنكر (إبراء) لأنه دفع المال افتداء ليمينه وإزالة للضرر عنه لا عوضا عن حق يعتقده (فلا رد) لما صالح عنه بعيب يجده فيه (ولا شفعة) فيه لاعتقاده أنه ليس بعوض (وإن كذب أحدهما) في دعواه أو إنكاره وعلم بكذب نفسه (لم يصح) الصلح (في حقه باطنا) لأنه عالم بالحق قادرا على إيصاله لمستحقه

غير معتقد أنه محق (وما أخذه حرام) عليه لأنه أكل للمال بالباطل وإن صالح

عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح ولم يرجع عليه ويصح الصلح عن قصاص وسكنى دار وعيب بقليل وكثير (ولا يصح) الصلح (بعوض عن حد سرقة وقذف) أو غيرهما لأنه ليس بمال ولا يؤول إليه (ولا) عن (حق شفعة) أو خيار لأنهما لم يشرعا لاستفادة مال وإنما شرع الخيار للنظر في الأحظ والشفعة لإزالة الضرر بالشركة (و) لا عن (ترك شهادة) بحق أو باطل (وتسقط الشفعة) إذا صالح عنها لرضاه بتركها ويرد العوض (و) كذا حكم (الحد) والخيار وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه

ماء معلوما صح لدعاء الحاجة إليه فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة وإلا فبيع ولا يشترط في الإجارة هنا بيان المدة للحاجة ويجوز شراء ممر في ملكه

وموضع في حائط يجعله بابا أو بقعة يحفرها بئرا أو علو بيت يبنى بنيانا موصوفا ويصح فعله صرحا أبدا أو إجارة مدة معلومة (وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره) الخاص به أو المشترك (أو) حصل غصن شجرته في (قراره) أي قرار غيره الخاص أو المشترك أي في أرضه وطالبه بإزالة ذلك (أزاله) وجوبا إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى (فإن أبى) مالك الغصن إزالته (لواه) مالك الهواء (إن أمكن وإلا) يمكن (فله قطعه لأنه أخلى ملكه الواجب إخلاؤه ولا يفتقر إلى حاكم ولا يجبر المالك على الإزالة لأنه ليس من فعله وإن أتلفه مالك الهواء مع إمكان ليه ضمنه وإن صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجز

وإن اتفقا على أن الثمرة بينهما ونحوه صح جائزا وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره (ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق) لأنه لم يتعين له مالك ولا ضرر فيه على المجتازين و (لا) يجوز (إخراج روشن) على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في الحائط (و) لا إخراج (ساباط) وهو المستوفي للطريق كله على جدارين (و) لا إخراج (دكة) بفتح الدال وهي الدكان والمصطبه

بكسر الميم (و) لا إخراج (ميزاب) ولو لم يضر بالمارة إلا أن يإذن إمام أو نائبه ولا ضرر لأنه نائب المسلمين فجرى مجرى إذنهم (ولا يفعل ذلك) أي لا يخرج روشنا ولا ساباطا ولا دكة ولا ميزابا (في ملك جار ودرب مشترك) غير نافذ (بلا إذن المستحق) أي الجار أو أهل الدرب لأن المنع لحق المستحق فإذا رضي

بإسقاطه جاز ويجوز نقل باب في درب غير نافد إلى أوله بلا ضرر لا إلى داخل إن لم يإذن من فوقه ويكون إعارة وحرم أن يحدث بملكه ما يضر

بجاره كحمام ورحى وتنور وله منعه كدق وسقي يتعدى وحرم أن يتصرف في جدار جار أو مشترك بفتح طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه (وليس له وضع خشبة على حائط جاره) أو حائط مشترك (إلا عند الضرورة)

فيجوز (إذا لم يمكنه التسقيف إلا به) ولا ضرر لحديث أبي هريرة يرفعه لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم متفق عليه (وكذلك) حائط (المسجد وغيره) كحائط نحو يتيم فيجوز لجاره وضع خشبة عليه إذا لم يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر لما تقدم (وإذا انهدم جدارهما) المشترك أو سقفها (أو خيف ضرره) بسقوطه (فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه) إن امتنع لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فإن أبى أخذ حاكم من ماله

وأنفق عليه وإن بناه شريك شركة بنية رجوع رجع (وكذا النهر والدولاب والقناة) المشتركة إذا احتاجت لعمارة ولا يمنع شريك من عمارة فإن فعل فالماء على الشركة وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها وله منها جزء معلوم

صح ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم بل يجبر عليه مالكه ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل فإن استويا اشتركا

11 باب الحجر

+ وهو في اللغة التضييق والمنع ومنه سمي الحرام والعقل حجرا وشرعا منع إنسان من تصرفه في ماله وهو ضربان حجر لحق الغير كعلى مفلس وحجر لحق نفسه كعلى نحو صغير (ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه

لم يطالب به وحرم حبسه) وملازمته لقوله تعالى ﴿ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ﴾ فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض كثمن وقرض أو لا وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه أو كان أقر بالملاءة حبس إن لم يقم بينة تخبر باطن حاله

وتسمع قبل حبس وبعده

وإلا حلف وخلي سبيله (ومن له قدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه) لعدم الحاجة إلى الحجر عليه (وأمر) أي وجب على الحاكم أمره (بوفائه) بطلب غريمه لحديث مطل الغني ظلم ولا يترخص من سافر قبله ولغريم من أراد سفرا

منعه من غير جهاد متعين حتى يوثق برهن يحرز أو كفيل مليء (فإن أبى) القادر وفاء الدين الحال (حبس بطلب ربه) ذلك لحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته رواه أحمد وأبو داود وغيرهما قال الإمام قال

وكيع عرضه شكواه وعقوبته حبسه فإن أبى عزره مرة بعد أخرى

(فإن أصر) على عدم قضاء الدين (ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه) لقيامه مقامه ودفعا لضرر رب الدين بالتأخير (ولا يطالب) مدين (ب) دين (مؤجل) لأنه لايلزمه أداؤه قبل حلوله ولا يحجر عليه من أجله (ومن ماله لا يفي بما عليه) من الدين (حالا وجب) على الحاكم (الحجر عليه بسؤال غرمائه) كلهم (أو بعضهم) لحديث كعب بن مالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله رواه الخلال بإسناده (ويستحب إظهاره) أي إظهار حجر المفلس وكذا السفيه ليعلم الناس بحاله فلا يعاملونه إلا على بصيرة (ولا ينفذ تصرفه) أي المحجور عليه لفلس (في ماله) الموجود والحادث بإرث أو غيره (بعد الحجر) بغير وصية أو تدبير (ولا إقراره عليه) أي

على ماله لأنه محجور عليه وأما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه فصحيح لأنه

رشيد غير محجور عليه لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه (ومن باعه أو أقرضه شيئا) قبل الحجر ووجده باقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من ثمنه فهو أحق به لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به متفق

عليه من حديث أبى هريرة وكذا لو أقرضه أو باعه شيئا (بعده) أي بعد الحجر عليه (رجع فيه) إذا وجده بعينه (إن جهل حجره) لأنه معذور بجهل حاله (وإلا) يجهل الحجر عليه (فلا) رجوع له في عينه لأنه دخل على بصيرة ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره (وإن تصرف) المفلس (في ذمته) بشراء أو ضمان أو نحوهما (أو أقر) المفلس (بدين أو) أقر ب (جناية توجب قودا أو مالا صح) تصرفه في ذمته وإقراره بذلك لأنه أهل للتصرف والحجر متعلق بماله لا بذمته (ويطالب به أي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه) وما أقر به (بعد فك الحجر عنه) لأنه حق عليه وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء فإذا استوفى فقد زال العارض (ويبيع الحاكم ماله)

أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين بثمن مثله أو أكثر (ويقسم ثمنه) فورا (بقدر ديون غرمائه) الحالة لأن هذا هو جل المقصود من الحجر عليه وفي تأخيره مطل وهو ظلم لهم (ولا يحل) دين (مؤجل بفلس) مدين لأن الأجل حق

للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه (ولا) يحل مؤجل أيضا (بموت) مدين (إن وثق ورثته برهن) يحرز (أو كفيل مليء) بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقة فإن لم يوثقوا حل لغلبة الضرر (وإن ظهر غريم) للمفلس (بعد القسمة) لماله لم تنقض

و (رجع على الغرماء بقسطه) لأنه لو كان حاضرا شاركهم فكذا إذا ظهر وإن بقي على المفلس بقية وله صنعة أجبر على التكسب لوفائها كوقف وأم ولد يستغنى

عنهما (ولا يفك حجره إلا حاكم) لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به وإن وفى ما عليه انفك الحجر بلا حاكم لزوال موجبه %

فصل في المحجور عليه لحظه

+ (ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم) إذا لمصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس والحجر عليهم عام في ذممهم وما لهم ولا يحتاج لحاكم فلا يصح تصرفهم قبل الإذن (ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا) أو وديعة ونحوها (رجع بعينه) إن بقي لأنه ماله (وإن) تلف في أيديهم أو (أتلفوه لم يضمنوا) لأنه سلطهم عليه برضاه

علم بالحجر أو لا لتفريطه (ويلزمهم أرش الجناية) إن جنوا لأنه لا تفريط من المجني عليه والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره (و) يلزمهم أيضا (ضمان مال من لم يدفعه إليهم) لأنه لا تفريط من المالك والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره (وإن تم لصغير خمس عشرة سنة) حكم ببلوغه لما روى ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني متفق عليه (أو نبت حول قبله شعر خشن) حكم ببلوغه لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة متفق عليه (أو أنزل) حكم ببلوغه لقوله تعالى ﴿ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ﴾

أو عقل مجنون ورشد أي من بلغ وعقل (أو رشد سفيه زال حجرهم) لزوال علته قال تعالى ﴿ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ﴾ بلا قضاء ﴿ فإن آنستم منهم رشدا ﴾

أي صلاحا في أموالهم فعلى هذا يدفع إليه ماله وإن كان مفسدا لدينه ويؤنس رشده (بأن يتصرف مرارا فلا يغبن) غبنا فاحشا (غالبا ولا يبذل ماله في حرام) كخمر وآلات لهو (أو في غير فائدة) كغناء ونفط لأن من صرف ماله في ذلك عد سفيها (ولا يدفع إليه) أي الصغير ماله (حتى يختبر) ليعلم رشده (قبل بلوغه بما يليق به) لقوله تعالى ﴿ وابتلوا اليتامى ﴾

الآية والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة (ووليهم) أي ولي السفيه الذي بلغ سفيها واستمر والصغير والمجنون (حال الحجر الأب) الرشيد العدل ولو ظاهرا لكمال شفقته (ثم وصيه) لأنه نائبه ولو بجعل وثم متبرع (ثم الحاكم) لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم كمن جن بعد بلوغ ورشد (ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ) لقوله تعالى ﴿ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ﴾ والسفيه والمجنون ومن فك عنه

الحجر فسفه أعيد عليه ولا ينظر في ماله إلا الحاكم في معناه (ويتجر) ولي المحجور عليه (له

مجانا) أي إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد ولا يعقد الولي لنفسه (وله دفع ماله) لمن يتجر فيه (مضاربة بجزء) معلوم (من الربح) للعامل لأن عائشة أبضعت مال محمد بن أبى

بكر رضي الله عنهم ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته وله البيع نساء والقرض برهن وإيداعه وشراء العقار وبناؤه لمصلحة وشراء الأضحية لموسر

وتركه في المكتب بأجرة ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة (ويأكل الولي الفقير من مال موليه) لقوله تعالى ﴿ ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ﴾ الأقل من كفايته أو أجرته أي أجرة عمله لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا فلم

يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه (مجانا) فلا يلزمه عوضه إذا أيسر لأنه عوض عن عمله فهو فيه كالأجير والمضارب (ويقبل قول الولي) بيمينه (والحاكم) بغير يمينه (بعد فك الحجر في النفقة) وقدرها مالم يخالف عادة وعرفا ولو قال

أنفقت عليك منذ سنتين فقال منذ سنة قدم قول الصبي لأن الأصل موافقته قال في المبدع (و) يقبل قول الولي أيضا (في وجود الضرورة والغبطة) إذا باع عقاره وادعاهما ثم أنكره (و) يقبل قول الولي أيضا في (التلف) وعدم التفريط لأنه أمين والأصل براءته (و) يقبل قوله أيضا في (دفع المال) إليه بعد رشده لأنه أمين وإن كان بجعل لم يقبل قوله في دفع المال لأنه قبضه لنفعه كالمرتهن ولولي مميز وسيده أن يأذن له في التجارة فينفك عنه الحجر في قدر ما أذن له فيه

(وما استدان العبد لزم سيده) أداؤه (إن أذن له) في استدانته ببيع أو قرض لأنه غر الناس بمعاملته (وإلا) يكن استدان بإذن سيده (ف) ما استدانه (في رقبته) يخير سيده بين بيعه وافدائه بالأقل من قيمته أو دينه ولو أعنته وإن كانت العين باقية ردت لربها (كاستيداعه) أي أخذه وديعة فيتلفها (وأرش جنايته وقيمة متلفه) فيتعلق ذلك كله برقبته ويخير سيده كما تقدم ولا يتبرع المأذون

له بدراهم ولا كسوة بل بإهداء مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة بلا إسراف ولغير المأذون له الصدقة من قوته بنحو رغيف إذا لم يضره وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك ما لم تضطرب العادة أو يكن بخيلا أو تشك في رضاه

12 باب الوكالة

الوكالة بفتح الواو وكسرها التفويض تقول وكلت أمري إلى الله أي فوضته إليه واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة (تصح) الوكالة (بكل قول يدل على الإذن) ك افعل كذا أو أذنت لك في فعله ونحوه وتصح

مؤقتة ومعلقة بشرط كوصية وإباحة أكل وولاية قضاء وإمارة (ويصح القبول على الفور والتراخي) بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة أو يبلغه أنه وكله بعد شهر فيقول قبلت (بكل قول أو فعل دال عليه) أي على القبول لأن قبول وكلائه صلى الله عليه وسلم كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إياهم قاله في المبدع ويعتبر تعيين الوكيل (ومن له التصرف في شيء) لنفسه (فله التوكيل) فيه (والتوكل فيه) أي جاز أن يستنيب غيره وأن ينوب عن غيره لانتفاء المفسدة والمراد فيما تدخله النيابة ويأتي ومن لايصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى

فلو وكله في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها لم يصح

ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها وأن يتوكل واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له وغني لفقير في قبول زكاة وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي (ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود) لأنه صلى الله عليه وسلم

وكل عروة بن الجعد في الشراء وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء ونحوها في معناه (والفسوخ) كالخلع والإقالة (والعتق والطلاق) لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى (والرجعه وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه) كإحياء الموات لأنها تملك مال بسبب لايتعين عليه فجاز كالابتياع (لاالظهار) لأنه قول منكر وزور (واللعان والأيمان) والنذور والقسامة والقسم بين الزوجات والشهادات والرضاع والالتقاط والاغتنام والغصب والجنايه فلا تدخلها النيابة (و) تصح الوكالة أيضا (في كل حق لله

تدخله النيابة من العبادات) كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها وكذا حج وعمرة على ما سبق وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها لأنها تتعلق ببدن من هي عليه لكن ركعتا الطواف تتبع الحج (و) تصح في (الحدود في إثباتها واستيفائها) لقوله صلى الله عليه وسلم

اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فأمر بها فرجمت متفق عليه ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته (وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه) إذا كان يتولاه مثله ولم يعجزه لأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه لكونه يتولى مثله (إلا أن يجعل إليه) بأن يأذن له في التوكيل أو يقول اصنع ماشئت ويصح توكيل عبد بإذن سيده (والوكالة عقد جائز)

لأنها من جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بذل نفع وكلاهما غير لازم فلكل واحد منهما فسخها (وتبطل بفسخ أحدهما وموته) وجنونه المطبق لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل فإذا انتفيا انتفت صحتها وإذا وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها أو في عتق العبد ثم كاتبه أو دبره بطلت (و) تبطل أيضا ب (عزل الوكيل) ولو قبل علمه لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضى صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق ولو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل إلا ببينة (و) تبطل أيضا (بحجر لسفه) لزوال أهلية التصرف لا بالحجر لفلس لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف لكن إن حجر على الموكل وكانت في أعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه فيها (ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه) لأن

العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه ولأنه تلحقه تهمة (و) لا من (ولده) ووالده وزوجته ومكاتبه وسائر من لاتقبل شهادته له لأنه متهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه وكذا حاكم وأمينه وناظر وقف ووصي ومضارب وشريك عنان ووجوه (ولا يبيع) الوكيل (بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد) لأن عقد الوكالة لم يقتضه فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما رواجا فإن تساويا خير

(وإن باع بدون ثمن المثل) إن لم يقدر له ثمن (أو) باع ب (دون ماقدره له) الموكل صح (أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل) صح وضمن الزائد وإن كان لم يقدر له

ثمنا (أو مما قدره له صح) الشراء لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره (وضمن النقص) في مسألة البيع (و) ضمن (الزيادة) في مسألة الشراء لأنه مفرط والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك ذكره الشيخ تقي الدين وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح لأنه زاده خيرا (وإن باع) الوكيل (بأزيد) مما قدره له الموكل صح (أو قال) الموكل (بع بكذا مؤجلا فباع) الوكيل (به حالا) صح (أو) قال الموكل (اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما) أي فيما إذا باع بالمؤجل حالا أو اشترى بالحال مؤجلا (صح) لأنه زاده خيرا فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها (وإلا فلا) أي وإن لم يبع أو يشتر بمثل ماقدره له بلا ضرر بأن قال بعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسعة حالة أو بعه بعشرة حالة فباعه بأحد عشرة مؤجلة وعلى الموكل ضرر بحفظ الثمن في الحال أو قال اشتره بعشرة حالة فاشتراه بأحد عشر أو بعشرة مؤجلة مع ضرر لم ينفذ تصرفه لمخالفته موكله وقدم في الفروع أن الضرر لايمنع الصحة وتبعه في المنتهى

و التنقيح في مسألة البيع وهو ظاهر المنتهى أيضا في مسألة الشراء وقد سبق لك أن بيع الوكيل بأنقص مما قدر له وشراءه بأكثر منه صحيح ويضمن

فصل

(وإن اشترى) الوكيل (مايعلم عيبه لزمه) أي لزم الشراء الوكيل فليس له رده لدخوله على بصيرة (وإن لم يرض) به (موكله) فإن رضيه كان له لنيته بالشراء وإن اشتراه بعين المال لم يصح (فإن جهل) عيبه (رده) لأنه قائم مقام الموكل وله أيضا رده لأنه ملكه فإن حضر الموكل قبل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده لأن الحق له بخلاف المضارب لأن له حقا فلا يسقط برضى غيره

فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل لم يلزم الوكيل ذلك وحقوق العقد كتسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك تتعلق بالموكل

(ووكيل البيع يسلمه) أي يسلم المبيع لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه لأنه من تمامه (ولا يقبض) الوكيل في البيع (الثمن) بغير إذن الموكل لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن (بغير قرينة) فإن دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائبا عن الموكل أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له كان إذنا في قبضه فإن تركه ضمنه لأنه يعد مفرطا هذا المذهب عند الشيخين وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى لايقبضه إلا بإذن فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء لأنه ليس بمفرط لكونه لا يملك قبضه (ويسلم وكيل المشتري الثمن) لأنه من تتمته وحقوقه كتسليم المبيع (فلو أخره) أي أخر تسليم الثمن (بلا عذر وتلف) الثمن (ضمنه) لتعديه بالتأخير وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن (وإن وكله في بيع فاسد) لم يصح ولم يملكه

لأن الله تعالى لم يأذن فيه ولأن الموكل لا يملكه (و) لو (باع) الوكيل إذا بيعا (صحيحا) لم يصح لأنه لم يوكل فيه (أو وكله في كل قليل وكثير) لم يصح لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر (أو) وكله في (شراء ماشاء أو عينا بما شاء ولم يعين) نوعا وثمنا (لم يصح) لأنه يكثر فيه الغرر وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه صح قال في المبدع وظاهر كلامهم في بع من مالي ماشئت له بيع ماله كله

(والوكيل في الخصومة لايقبض) لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض (والعكس بالعكس) فالوكيل في القبض له الخصومة لأنه لايتوصل إليه إلا بها فهو إذن فيها عرفا (و) إن

قال الموكل (اقبض حقي من زيد) ملكه من وكيله لأنه قائم مقامه و (لايقبض من ورثته) لأنه لم يؤمر بذلك ولا يقتضيه العرف (إلا أن يقول) الموكل للوكيل اقبض حقي (الذي قبله) أو عليه فله القبض من وارثه لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا وإن قال اقبضه اليوم لم يملكه غدا (ولا يضمن وكيل) في (الإيداع إذا) أودع و (لم يشهد) وأنكر المودع لعدم الفائدة في الإشهاد لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد ضمن إذا أنكر رب الدين وتقدم في الضمان %

فصل

+ (والوكيل أمين لايضمن ماتلف بيده بلا تفريط) لأنه نائب المالك في اليد والتصرف فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك ولو بجعل فإن فرط أو تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن (ويقبل قوله) أي الوكيل (في نفيه) أي نفي التفريط ونحوه (و) في (الهلاك مع يمينه) لأن الأصل براءة ذمته لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة

عليه ثم يقبل قوله فيه وإن وكله في شراء شيء واشتراه واختلفا في قدر ثمنه قبل قول الوكيل وإن اختلفا في رد العين أو ثمنها إلى الموكل فقول وكيل متطوع وإن كان بجعل فقول موكل وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز فهو أمانة في يده لايلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه

(ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو) بلا بينة (لم يلزمه) أي عمرا (دفعه له إن صدقه) لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق الرجوع عليه (ولا) يلزمه (اليمين إن كذبه) لأنه لايقضى عليه بالنكول فلا فائدة في لزوم تحليفه (فإن دفعه) عمرو (فأنكر زيد الوكالة حلف) لاحتمال صدق الوكيل

فيها (وضمنه عمرو) فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ماقبضه أو تعديه لا إن صدقه وتلف بيده بلا تفريط (وإن كان المدفوع) لمدعي الوكالة بغير بينه (وديعة أخذها) حيث وجدها لأنها عين حقه (فإن تلفت ضمن أيهما شاء) لأن الدافع ضمنها بالدفع والقابض قبض ما لا يستحقه فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض إن صدقة وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة والوصية وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه لزمه الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار على نفي العلم

باب الشركة

+ الشركة بوزن سرقة ونعمة وثمرة (وهي) نوعان شركة أملاك وهي (اجتماع في استحقاق) كثبوت الملك في عقار أو منفعة لاثنين فأكثر (أو) شركة عقود وهي اجتماع في (تصرف) من بيع ونحوه (وهي) أي شركة العقود وهي المقصودة هنا (أنواع) خمسة فأحدها (شركة عنان) سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير وهي (أن يشترك اثنان) أي شخصان فأكثر مسلمين أو أحدهما

ولا تكره مشاركة كتابي لايلي التصرف (بما ليهما المعلوم) كل منهما الحاضرين (ولو) كان مال كل (متفاوتا) بأن لم يتساو المالان قدرا أو جنسا أو صفة (ليعملا فيه ببدنيهما) أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح مالة فإن كان بدونه لم يصح وبقدره إبضاع وإن اشتركا في مختلط بينهما

شائعا صح إن علما قدر ما لكل منهما (فينفذ تصرف كل منهما 2 فيهما) أي في المالين (بحكم الملك في نصيبه و) بحكم (الوكالة في نصيب شريكه) ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف (ويشترط) لشركة العنان والمضاربة (أن يكون رأس المال من النقدين

المضروبين) لأنهما قيم الأموال وأثمان البياعات فلا تصح بعروض ولا فلوس ولو نافقة وتصح بالنقدين (ولو مغشوشين يسيرا) كحبة فضة في دينار ذكره في المغني و الشرح لأنه لايمكن التحرز منه فإن كان الغش كثيرا لم يصح لعدم انضباطه (و) يشترط أيضا (أن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما) كالثلث والربع لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة فإن قالا والربح بيننا فهو بينهما نصفين (فإن لم يذكرا الربح) لم

تصح لأنه المقصود من الشركة فلا يجوز الإخلال به (أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا) لم تصح لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب (أو) شرطا (دراهم معلومة) لم تصح لاحتمال أن لايربحها أو يربح غيرها (أو) شرطا (ربح أحد الثوبين) أو إحدى السفرتين أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه (لم تصح) لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة (وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة) فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل لما تقدم (والوضيعة) أي الخسران (على قدر المال) بالحساب سواء كانت لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك (ولا يشترط خلط المالين لأن القصد الربح وهو لايتوقف على الخلط (ولا) يشترط أيضا (كونهما من جنس واحد) فيجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم فإذا اقتسما رجع كل بماله

ثم اقتسما الفضل وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويقبض

ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويرد بالعيب ويفعل كل ماهو من مصلحة تجارتهما لا أن يكاتب رقيقا أو يزوجه أو يعتقه أو يحابي أو يقترض على الشركة إلا بإذن شريكه وعلى كل منهما أن يتولى ماجرت العادة

بتوليه من نشر ثوب وطيه أو إحرازه وقبض النقد ونحوه كغلق الدكان فإن استأجر له فالأجرة عليه %

فصل في المضاربة

+ النوع (الثانية المضاربة) من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة قال الله تعالى ﴿ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ﴾ وتسمى قراضا ومعاملة وهي دفع مال معلوم (لمتجر) أي لمن يتجر (به ببعض ربحه) أي بجزء معلوم مشاع منه كما تقدم فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر

سهم العامل فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجرة مثله وإن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما صح وكان لسيده وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معا ولو ولد أحدهما أو امرأته وشرطا عليه عملا مع العامل صح وكانا عاملين وإلا لم تصح المضاربة (فإن قال) رب المال للعامل اتجر به (والربح بيننا فنصفان) لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح فاقتضى التسوية (وإن قال) اتجر به (ولي) ثلاثة أرباعه أو ثلثه (أو) قال اتجر به و (لك) (ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح) لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه (والباقي للآخر) لأن الربح مستحق لهما فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ (وإن اختلفا لمن) الجزء (المشروط ف) هو (لعامل) قليلا كان أو كثيرا لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر وإنما تقدر حصته بالشرط بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله ويحلف مدعيه وإن اختلفا في قدر الجزء بعد

الربح فقول مالك بيمينه وكذا (مساقاة ومزارعة) إذا اختلفا في الجزء المشروط وقدره لما تقدم ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله وتصح مؤقتة ومعلقة (ولا يضارب) العامل (بمال

الآخر إن أضر الأول ولم يرض) لأنها تنعقد على الحظ والنماء فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه وإن لم يكن فيها ضرر على الأول أو إذن جاز (فإن فعل) بأن ضارب

الآخر مع ضرر الأول بغير إذنه (ردت حصته) من ربح الثانية (في الشركة) الأولى لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول ولا نفقة لعامل إلا بشرط (ولا يقسم) الربح (مع بقاء العقد) أي المضاربة (إلا باتفاقهما) لأن

الحق لايخرج عنهما والربح وقاية لرأس المال (وإن تلف رأس المال أو) تلف (بعضه) قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة كالتلف قبل القبض وإن تلف (بعد التصرف) جبر من الربح لأنه دار في التجارة وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح (أو خسر) في إحدى سلعتين أو سفرتين (جبر) ذلك (من الربح) أي وجب جبر الخسران من الربح ولم يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال لأنها مضاربة واحدة (قبل قسمته) ناضا (أو تنضيضه) مع محاسبته فإذا احتسبا وعلما ما لهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله تنزيلا

للتنضيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة وإن انفسخ العقد والمال عرض أو دين فطلب رب المال تنضيضه لزم العامل وتبطل بموت أحدهما فإن مات عامل أو مودع أو وصي ونحوه وجهل بقاء مابيدهم فهو دين في التركة لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة لأنه أمين والقول قول رب المال في عدم رده إليه %

+ (الثالث شركة الوجوه) سميت بذلك لأنهما يعاملان فيها بوجههما أي جاههما والجاه والوجه واحد وهي أن يشتركا على (أن يشتريا في ذمتيهما) من غير أن يكون لهما مال (بجاهيهما) فما ربحاه (ف) هو (بينهما) على ما شرطاه سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو جنسه أو وقته أو لا فلو قال ما اشتريت من شيء فبيننا صح (وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن) لأن مبناهما على الوكالة والكفالة (والملك بينهما على ماشرطاه) لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم (والوضيعة على قدر ملكيهما)

كشركة العنان لأنها في معناها (والربح على ماشرطاه) كالعنان وهما في تصرف كشريكي عنان (الرابع شركة الأبدان) وهي (أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما) أي

يشتركان في كسبهما من صنائعهما فما رزق الله فهو بينهما (فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله) ويطالبان به لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك وتصح مع اختلاف الصنائع كقصار مع خياط ولكل واحد منهما طلب الأجرة وللمستأجر دفعها إلى أحدهما ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن (وتصح) شركة الأبدان (في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات) كالثمار المأخوذة من الجبال والمعادن والتلصص على دار الحرب لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجىء أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين قال أحمد أشرك بينهم النبي صلى الله عليه

وسلم (وإن مرض أحدهما فالكسب) الذي عمله أحدهما (بينهما) احتج الإمام بحديث سعد وكذا لو ترك العمل لغير عذر (وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه) لأنهما دخلا على أن يعملا فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية للعقد بما يقتضيه وللآخر الفسخ وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما والأجرة بينهما صح وأن أجراهما بأعيانهما فلكل أجرة دابته ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها وما رزقه الله بينهما على ماشرطاه

(الخامس شركة المفاوضة) وهي (أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة) بيعا وشراء ومضاربة وتوكيلا وابتياعا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانا وضمان مايرى من الأعمال أو يشتركا في كل مايثبت لهما وعليهما فتصح (والربح على ماشرطاه والوضيعة بقدر المال) لما

سبق في العنان (فإن أدخلا فيها كسبا أو غرامة نادرين) كوجدان لقطة أو ركاز أو ميراث أو أرش جناية أو (مايلزم أحدهما من ضمان (غصب أو نحوه فسدت) لكثرة الغرر فيها لأنها تضمنت كفالة وغيرها مما لا يقتضيه العقد

14 باب المساقاة

+ السقي من السقي لأنه أهم أمرها بالحجاز وهي دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره (تصح) المساقاة (على شجر له ثمر يؤكل) من نخل وغيره لحديث ابن عمر عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر مايخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه وقال أبو جعفر عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع ولا تصح على ما لا ثمر له كالحوز أو له ثمر غير مأكول كالصنوبر والقرظ

(و) تصح المساقاة أيضا (على) شجر ذي (ثمرة موجودة) لم تكمل تنمى بالعمل كالمزارعة على زرع نابت لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر أولى (و) تصح أيضا (على شجر يغرسه) في أرض رب الشجر (ويعمل عليه حتى يثمر) احتج الإمام بحديث خيبر ولأن العوض والعمل معلومان فصحت كالمساقاة على شجر مغروس (بجزء من الثمرة) مشاع معلوم وهو متعلق بقوله تصح فلو شرطا في المساقاة الكل لأحدهما أو آصعا

معلومة أو ثمرة شجرة معينة لم تصح وتصح المناصبة والمغارسة وهي دفع أرض

وشجر لمن يغرسه كما تقدم بجزء معلوم مشاع من الشجر (وهو) أي عقد المساقاة والمغارسة والمزارعة (عقد جائز) من الطرفين قياسا على المضاربة لأنها عقد

على جزء من النماء في المال فلا يفتقر إلى ذكر مدة ولكل منهما فسخها متى شاء (فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة) أي أجرة مثله لأنه منعه

من إتمام عمله الذي يستحق به العوض (وإن فسخها هو) أي فسخ العامل المساقاة قبل ظهور الثمرة (فلا شيء له) لأنه رضي بإسقاط حقه وإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطا ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب

(ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار) بكسر الزاي وهو قطع الأغصان الرديئة من الكرم (وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه و) إصلاح (طرق الماء وحصاد ونحوه) كآلة حرث وبقرة وتفريق زبل وقطع حشيش مضر وشجر يابس وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم (وعلى رب المال مايصلحه) أي مايحفظ الأصل (كسد حائط وإجراء الأنهار) وحفر البئر (والدولاب ونحوه) كآلته التي تديره ودوابه وشراء مايلقح به وتحصيل ماء

وزبل والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما إلا أن يشترطه على العامل والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ويرد وغير ذلك %

ج ٢ - ص ٢٨٨

فصل في المزارعة

+ (وتصح المزارعة) لحديث خيبر السابق وهي دفع أرض وحب لمن بزرعه ويقوم عليه أو جب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه (بجزء) مشاع (معلوم النسبة) كالثلث أو الربع ونحوه (مما يخرج من الأرض لربها) أي لرب

الأرض (أو للعامل والباقي للآخر) أي أن يشترط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل وإن شرط للعامل فالباقي لرب الأرض لأنهما يستحقان ذلك فإذا عين نصيب أحدهما منه لزم أن يكون الباقي للآخر (ولايشترط) في المزارعة والمغارسة (كون البذر والغراس من رب الأرض) فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما ونص عليه في رواية مهنا وصححه في المغني و الشرح واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين (وعليه عمل الناس) لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين وظاهر المذهب اشتراطه نص عليه في رواية جماعة واختاره عامة الأصحاب وقدمه في التنقيح وتبعه المصنف في الإقناع وقطع به في المنتهى وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسما الباقي لم يصح وإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه

على الشجر صح وكذا لو أجره الأرض وساقاه على شجرها فيصح ما لم يتخذه حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وتصح مساقاة ومزارعة بلفظهما

ولفظ العاملة وما في معنى ذلك ولفظ إجارة لأنه مؤد للمعنى وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل

فيجب القسط المسمى

باب الإجارة

+ مشتقة من الأجر وهو العوض ومنه سمي الثواب أجرا وهي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما وبلفظ بيع إن لم يضف للعين

و (تصح) الإجارة (بثلاثة شروط) أحدها (معرفة المنفعه) لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع وتحصل المعرفة إما بالعرف (كسكنى دار) لأنها لا تكرى إلا لذلك فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا يسكنها دابة ولا يجعلها مخزنا لطعام ويدخل ماء بئر تبعا وله إسكان ضيف وزائر (و) ك (خدمة آدمي) فيخدم ماجرت به العادة من ليل ونهار وإن استأجر

حرة أو أمة صرف وجهه عن النظر (و) يصح استئجار آدمي لعمل معلوم ك (تعليم علم) وخياطة ثوب أو قصارته أو ليدل على طريق ونحوه لما في البخاري عن عائشة في حديث الهجرة واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا هو عبد الله بن أرقط وقيل ابن أريقط كان كافرا من بني الديل هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية وإما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته

الشرط الثاني (معرفة الأجرة) بما تحصل به معرفة الثمن لحديث أحمد عن أبى سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره فإن أجره الدار بعمارتها أو عوض معلوم وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة لم تصح ولو أجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسبا به من الأجرة صح

(وتصح) الإجارة (في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما) روي عن

أبى بكر وعمر وأبى موسى في الأجير وأما الظئر فلقوله تعالى ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾

ويشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاع ومعرفة

الطفل بالمشاهدة وموضع الرضاع ومعرفة الرضاع ومعرفة العوض (وإن دخل حماما أو سفينة) بلا عقد (أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا) ليعملاه (بلا عقد صح بأجرة العادة) لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه أو استعمل حمالا ونحوه فله أجرة مثله ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة الشرط الثالث (الإباحة في) نفع (العين) المقدور عليه المقصود كإجارة

دار يجعلها مسجدا وشجر لنشر ثياب أو قعوده بظله (فلا تصح) الإجارة (على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر) لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة تنافيها وسواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل ولاتصح إجارة طير ليوقظه للصلاة لأنه غير مقدور عليه ولاشمع وطعام ليتجمل به ويرده ولاثوب يوضع على نعش ميت ذكره في المغني

و الشرح ولا نحو تفاحة لشم (وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه) المعلوم (عليه) لإباحة ذلك (ولا تؤجر المرأة نفسها) بعد عقد النكاح عليها (بغير إذن زوجها) لتفويت حق الزوج %

فصل في شروط الإجارة

+ (ويشترط في العين المؤجرة) خمسة شروط أحدها (معرفتها برؤية أو صفة) إن انضبطت بالوصف ولهذا قال (في غير الدار ونحوها) مما لايصح فيه السلم فلو استأجر حماما فلا بد من رؤيته لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر ومعرفة مائه ومشاهدة الإيوان ومطرح الرماد ومصرف الماء وكره أحمد كراء الحمام لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه

(و) الشرط الثاني (أن يعقد على نفعها) المستوفي (دون أجزائها) لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها (فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله) ولو أكرى شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ماذهب وأجر الباقي فهو فاسد (ولا حيوان ليأخذ لبنه) أو صوفه أو شعره أو وبره (إلا

في الظئر) فيجوز وتقدم (ونقع البئر) أي ماؤها المستنقع فيها (وماء الأرض يدخلان تبعا)

كحبر ناسخ وخيوط خياط وكحل كحال ومرهم طبيب ونحوه (و) الشرط الثالث (القدرة على التسليم) كالبيع (فلا تصح إجارة) العبد (الآبق و) الجمل (الشارد) والطير في الهواء ولا المغصوب ممن لايقدر على

أخذه ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه وتصح لغيرها (و) الشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين

(و) الشرط الخامس (أن تكون المنفعة) مملوكة (للمؤجر أو مأذونا له فيها) فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه (وتجوز إجارة العين) المؤجرة بعد قبضها إذا أجرها المستأجر (لمن يقوم مقامه) في الانتفاع أو دونه لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه (لا بأكثر منه ضررا) لأنه لايملك أن يستوفيه فبنائبه أولى وليس

للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك والأجرة له (وتصح إجارة الوقف) لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز له إجارتها كالمستأجر (فإن مات المؤجر فانتقل) الوقف (إلى من بعده لم تنفسخ) لأنه أجر ملكه في زمن ولايته فلا تبطل

بموته كمالك المطلق (وللثاني حصته من الأجرة) من حين موت الأول فإن كان قبضها رجع في تركته بحصته لأنه تبين عدم استحقاقه لها فإن تعذر أخذها فظاهر كلامهم أنها تسقط قاله في المبدع وإن لم تقبض فمن مستأجر وقدم في التنقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق وكذا حكم مقطع أجر إقطاعه ثم أقطع لغيره وإن أجر الناظر العام أو من شرط له

وكان أجنبيا لم تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله وإن أجر الولي اليتيم أو ماله أو السيد العبد ثم بلغ الصبي ورشد وعتق العبد أو مات الولي أو عزل لم تنفسخ الإجارة إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه أو عتقه فيها فتنفسخ من حينها

(وإن أجر الدار ونحوها) كالأرض (مدة) معلومة (ولوطويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح) ولو ظن عدم العاقد فيها ولا فرق بين الوقف والملك لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما قاله الشيخ تقي الدين ولا يشترط أن تلي المدة العقد فلو آجره سنة خمس في سنة أربع صح ولو كانت العين مؤجرة أو مرهونة حال عقد إن قدر على تسليمها عند وجوبه (وإن استأجرها) أي العين (لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث) أرض معلومة

بالمشاهدة لاختلافها بالصلابة والرخاوة (أو دياس زرع) معين أو موصوف لأنها منفعة مباحة مقصودة (أو) استأجر (من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك) العمل (وضبطه بما لا يختلف) لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط فيه العلم كالمبيع (ولا تصح) الإجارة (على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة) أي مسلما كالحج والأذان وتعليم القرآن لأن من شرط هذه الأفعال كونها

قربة إلى الله تعالى فلم يجز أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر قوما يصلون خلفه

ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال وجعالة وأخذ بلا شرط ويكره للحر أكل أجرة على حجامة ويطعمه الرقيق والبهائم

(و) يجب (على المؤجر كل مايتمكن به) المستأجر (من النفع كزمام الجمل) وهو الذي يقوده به (ورحله وحزامه) بكسر الحاء المهملة (والشد عليه) أي على الرحل (وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير) لينزل المستأجر لصلاة فرض وقضاء حاجة إنسان وطهارة ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك (ومفاتيح الدار) على المؤجر لأن عليه التمكين من الانتفاع وبه يحصل وهي أمانة في يد المستأجر (و) على المؤجر أيضا (عمارتها) فلو سقط حائط أو خشبة فعليه إعادته (فأما تفريغ البالوعة والكنيف) وما في الدار من زبل أو قمامة ومصاريف حمام (فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة) من ذلك لأنه حصل بفعله

فكان عليه تنظيفه ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به إما بالفراسخ أو الزمان وإن استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح وإن اختلفا في البادىء منهما أقرع بينهما في الأصح قاله في المبدع %

فصل

+ (وهي) أي الإجارة (عقد لازم) من الطرفين لأنها نوع من البيع فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه (فإن أجره شيئا ومنعه) أي منع المؤجر

المستأجر الشيء المؤجر (كل المدة أو بعضها) بأن سلمه العين ثم حوله قبل أن تقضى المدة (فلا شيء له) من الأجرة لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا (وإن بدأ الآخر) أي المستأجر فتحول (قبل انقضائها) أي انقضاء مدة الإجارة (فعليه) جميع الأجرة لأنها عقد لازم فترتب مقتضاها وهو

ملك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع (و) تنفسخ الإجارة (بتلف العين المؤجرة) كدابة وعبد ماتا لأن المنفعة زالت بالكلية وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط (و) وتنفسخ الإجارة أيضا (بموت المرتضع) لتعذر استيفاء المعقود عليه لإن غيره لا يقوم

مقامه لاختلافهم في الرضاع (و) تنفسخ الإجارة أيضا بموت (الراكب إن لم يخلف بدلا) أي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة بأن لم يكن له وارث أو كان غائبا كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله فظاهر كلام أحمد أنها تنفسخ في الباقي لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين أشبه ما لو غصبت هذا كلامه في المقنع والذي في الإقناع و المنتهى وغيرهما أنها لاتبطل بموت راكب (و) تنفسخ أيضا (بانقلاع ضرس) اكترى لقلعه (أو برئه) لتعذر استيفاء المعقود عليه فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر (ونحوه) أي تنفسخ الإجارة بنحو ذلك كاستئجار طبيب ليداويه فبرئ و (لا) تنفسخ (بموت المتعاقدين أو أحدهما)

مع سلامة المعقود عليه للزومها (ولا) تنفسخ بعذر لأحدهما مثل (ضياع نفقة المستأجر) للحج (ونحوه) كاحتراق متاع من اكترى دكانا لبيعه فيه (وإن اكترى دارا فانهدمت أو) اكترى (أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي) من المدة (لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه مالو تلف) وإن أجره أرضا بلا ماء صح وكذا إن أطلق مع علمه بحالها وإن ظن وجوده بالأمطار وزيادة الأنهار صح كالعلم

وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة مامضى وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من ماله من يعمله ما لم تشترط مباشرته أو يختلف فيه القصد كالنسخ فيخير المستأجر بين الصبر والفسخ (وإن وجد) المستأجر (العين معيبة أو حدث بها) عنده (عيب) وهو

مايظهر به تفاوت الأجر (فله الفسخ) إن لم يزل بلا ضرر يلحقه (وعليه أجرة مامضى) لاستيفائه المنفعة فيه وله الإمضاء مجانا والخيار على التراخي ويجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الإجارة به وللمشتري الفسخ إن لم يعلم (ولا

يضمن أجير خاص) وهو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها وصلاة جمعة وعيد وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة ولا يضمن (ماجنت يده من خطأ) لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل وإن تعدى أو فرط ضمن

(ولا) يضمن أيضا (حجام وطبيب وبيطار) وختان (لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم) أي معرفتهم صنعتهم لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته ولا فرق بين خاصتهم ومشتركهم فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا لأنه لايحل لهم مباشرة القطع إذا وكذا لو كان حاذقا وجنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة أو بآلة كالة أو تجاوز بقطع السلعة موضعها ضمن لأنه إتلاف لايختلف ضمانه بالعمد والخطأ (ولا) يضمن أيضا (راع لم يتعد) لأنه مؤتمن على

الحفظ كالمودع فإن تعدى أو فرط ضمن (ويضمن) الأجير (المشترك) وهو

من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه كالحائك والقصار والصباغ والحمال فكل منهما ضامن (ما تلف بفعله) كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله

روي عن عمر وعلي وشريح والحسن رضي الله عنهم لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل بخلاف الخاص والمتولد من المضمون مضمون وسواء عمل في بيته أوبيت المستأجر أو كان المستأجر على المتاع أولا (ولا يضمن) المشترك (مأتلف من حرزه أو بغير فعله) لأن العين في يده أمانة كالمودع (ولا أجرة له) فيما عمل فيه لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه سواء كان في بيت المستأجر أو غيره بناء كان أو غيره

وإن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه لأنه لم يرهنه عنده ولا أذن له في إمساكه فلزمه الضمان كالغاصب وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن

(وتجب الأجرة بالعقد) كثمن وصداق وتكون حالة (إن لم تؤجل) بأجل

معلوم فلا تجب حتى يحل (وتستحق) أي يملك الطلب بها (بتسليم العمل الذي في الذمة) ولا يجب تسليمها قبله وإن وجبت بالعقد لأنها عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة وبتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع أو فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها

(ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل) لمدة بقائها في يده سكن أو لم يسكن لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها

16 باب السبق

+ وهو بتحريك الباء العوض الذي يسابق عليه وبسكونها المسابقة أي المجاراة بين حيوان وغيره (يصح) أي يجوز السباق (على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق) جمع مزراق وهو الرمح القصير وكذا المناجيق

ورمي الأجحار بمقاليع ونحو ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رواه أحمد وأبو داود وصارع ركانة فصرعه رواه أحمد أبو داود و سابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم (ولاتصح) أي لا تجوز المسابقة (بعوض إلا في إبل وخيل وسهام) لقوله عليه الصلاة

و السلام لاسبق إلا في نصل أو خف أو حافر رواه الخمسة عن أبى هريرة ولم يذكر ابن ماجه أو نصل وإسناده حسن قاله في المبدع (ولا بد) لصحة المسابقة (من تعيين المركوبين) لا الراكبين لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه و لا بد من اتخاذهما في النوع فلا تصح بين عربى وهجين (و) لابد في المناضلة من تعيين (الرماة) لأن القصد معرفة

حذقهم ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية ويعتبر فيها أيضا كون القوسين من نوع واحد فلا تصح بين قوس عربية وفارسية (و) لا بد أيضا من تحديد (المسافة) بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيه ويعتبر في المناضلة تحديد مدى رمي (بقدر معتاد) فلو جعلا مسافة بعيدة

تتعذر الإصابة في مثلها غالبا وهو ما زاد على ثلاثمائة ذراع لم تصح لأن الغرض يفوت بذلك ذكره في الشرح وغيره (وهي) أي المسابقة (جعالة لكل واحد) منهما (فسخها) لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه (وتصح المناصلة) أي المسابقة بالرمي من النصل وهو السهم التام (على معينين) سواء كان اثنين أو جماعتين لأن القصد معرفة الحذق كما تقدم (يحسنون الرمي) لأن من لا يحسنه وجوده كعدمه ويشترط لها أيضا تعيين عدد الرمي والإصابة

ومعرفة قدر الغرض كطوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من الأرض والسنة أن يكون لهما غرضان إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم

باب العارية

+ بتخفيف الياء وتشديدها من العري وهو التجرد سميت عارية لتجردها عن العوض (وهي إباحة نفع عين) يحل الانتفاع بها (تبقى بعد استيفائه) ليردها

على مالكها وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها ويشترط أهلية المعير

للتبرع شرعا وأهلية المستعير للتبرع له وهي مستحبة لقوله تعالى ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ﴾ وتباح إعارة كل ذي نفع مباح كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها (إلا البضع) لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين وكلاهما منتف (و) إلا (عبدا مسلما (لمحرم) لقوله تعالى ﴿ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ و لكافر) لأنه لا يجوز له استخدامه (و) إلا (صيدا

ونحوه) كمخيط إلا (أمة شابة لغير امرأة أو محرم) لأنه لا يؤمن عليها ومحل ذلك إن خشي المحرم وإلا كره فقط ولا بأس بشوهاء وكبيرة لا تشتهى ولا بإعارتها لامرأة أو ذي محرم لأنه مأمون عليها وللمعير الرجوع متى شاء مالم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه كسفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه

(ولا أجرة لمن أعار حائطا) ثم رجع (حتى يسقط) لأن بقاؤه بحكم العارية فوجب كونه بلا أجرة بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده جمعا بين الحقين (ولا يرد) الخشب (إن سقط) الحائط لهدم أو لغيره لأن الإذن تناول الأول فلا يتعداه لغيره (إلا بإذنه) أي إذن صاحب الحائط أو عند الضرورة إلى وضعه إذا لم يتضرر الحائط كما تقدم في الصلح (وتضمن العارية) المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له لقوله صلى الله عليه وسلم وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه الخمسة وصححه الحاكم وروي عن ابن عباس وأبى هريرة لكن المستعير من المستأجر أو لكتب علم ونحوها موقوفة

لا ضمان عليه إن لم يفرط وحيث ضمنها المستعير ف (بقيمتها يوم تلفت) إن لم تكن مثلية وإلا فبمثلها كما تضمن في الإتلاف (ولو شرط نفي ضمانها) لم يسقط لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط وإن تلفت هي أو أجزاؤها في الانتفاع بمعروف لم تضمن لأن

الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف وما أذن في إتلافه غير مضمون (وعليه) أي وعلى المستعير (مؤنة ردها) أي رد العارية لما تقدم من حديث

على اليد ما أخذت حتى تؤديه وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد (إلا المؤجرة) فلا يجب على المستأجر مؤنة

ردها لأنه لايلزمه الرد بل يرفع يده إذا انقضت المدة ومؤنة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله لأنه نائبه (ولا

بعيرها) ولا يؤجرها لأنه إباحة المنفعة فلم يجز أن يبيحها غيره كإباحة الطعام (فإن) أعارها و (تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها) إن كانت متقومة سواء كان عالما بالحال أو لا لأن التلف حصل بيده (و) استقر (على معيرها أجرتها) للمعير الأول إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال وإلا استقرت عليه أيضا (و) للمالك أن (يضمن أيهما شاء) من المعير لأنه سلط على إتلاف ماله

أو المستعير لأن التلف حصل تحت يده (وإن أركب) دابته (منقطعا) طلبا (للثواب لم يضمن) لأن يدربها لم تزل عليها كرديفه ووكيله ولو سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن إن لم يأذن له في الاستعمال فإن أذن له فيه فكعارية وإن كان بإجرة فإجارة فلو سلمها إليه ليعلفها ويقوم بمصالحها لم يضمن (وإذا قال) المالك (أجرتك) و (قال) من هي بيده (بل أعرتني أو بالعكس) بأن قال أعرتك قال بل أجرتني فقول المالك في الثانية وترد إليه في الأول إن اختلفا (عقب العقد) أي قبل مضي مدة لها أجرة (قبل قول مدعي الإعارة) مع يمينه لأن الأصل عدم عقد الإجارة وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية (و) إن كان الاختلاف (بعد مضي مدة) لها أجرة فالقول (قول المالك) مع يمينه لأن الأصل في مال الغير الضمان ويرجع المالك حينئذ (بأجرة المثل) لما مضي من المدة لأن الإجارة لم تثبت (وإن قال) الذي

في يده العين (أعرتني أو قال أجرتني قال) المالك (بل غصبتني) فقول مالك كما لو اختلفا في ردها (أو قال) المالك (أعرتك) و (قال) من هي بيده (بل أجرتني والبهيمة تالفة) فقول مالك لأنهما اختلفا في صفة القبض والأصل

فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان للأثر ويقبل قول الغارم في القيمة (أو اختلفا في رد فقول المالك) لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه فلم يقبل قوله في الرد وإن قال أودعتني فقال غصبتني أو قال أودعتك قال بل أعرتني صدق المالك بيمينه وعليه الأجرة بالانتفاع

18 باب الغصب

+ الغصب مصدر غصب يغصب بكسر الصاد (وهو) لغة أخذ الشيء ظلما واصطلاحا (الاستيلاء) عرفا (على حق غيره) مالا كان أو اختصاصا (قهرا بغير

حق) نخرج بقيد القهر المسروق والمنتهب والمختلس وبغير حق استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه والحاكم على مال المفلس

وهو محرم لقوله تعالى ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ من عقار بفتح العين الضيعة والنخل والأرض قاله أبو السعادات (ومنقول)

من أثاث وحيوان ولو أم ولد لكن لا تثبت اليد على بضع فيصح تزويجها

ولا يضمن نفعه ولو دخل دارا قهرا وأخرج ربها فغاصب وإن أخرجه قهرا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه وإن لم يرد الغصب فلا وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب ولو كان فيها قماشه ذكره في المبدع (وإن غصب كلبا يقتنى) ككلب صيد وماشية وزرع (أو) غصب (خمر ذمي) مستورة (ردهما) لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه وخمر الذمي يقر على شربها وهي مال عنده (ولا) يلزم أن (يرد جلد ميتة) غصب لو بعد الدبغ لأنه لا يطهر بدبغ وقال الحارثي يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات قال في تصحيح الفروع

هو الصواب (وإتلاف الثلاثة) أي الكلب والخمر المحرمة وجلد الميتة (هدر) سواء كان المتلف مسلما أو ذميا لأنه ليس لها عوض شرعي لأنه لا يجوز بيعها (وإن استولى على حر) كبير أو صغير (لم يضمنه) لأنه ليس بمال (وإن استعمله كرها) فعليه أجرته لأنه استوفى منافعه وهي متقومة (أو حبسه) مدة لمثلها أجرة (فعليه أجرته) لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه (ويلزم) غاصبا (رد المغصوب) إن كان باقيا وقدر على رده لقوله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا ومن أخذ عصا أخيه فليردها رواه أبو داود

و إن زاد لزمه رده (بزيادته) متصلة كانت أو منفصلة لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل (وإن غرم) على رد المغصوب (أضعافه) لكونه بني عليه أو بعد ونحوه (وإن بنى في الأرض) المغصوبة (أو غرس لزمه القلع) إذا طالبه المالك بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق

(و) لزمه (أرش نقصها) أي نقص الأرض (وتسويتها) لأنه ضرر حصل

بفعله (والأجرة) أي أجرة مثلها إلى وقت التسليم وإن بذل ربها قيمة الغراس

والبناء ليملكه لم يلزم الغاصب قبوله وله قلعها وإن زرعها وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب وعليه أجرتها وإن كان الزرع قائما فيها خير ربها بين تركه

إلى الحصاد بأجرة مثله وبين أخذه بنفقته وهي مثل بذره وعوض لواحقه (ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك) الجارح أو العبد أو الفرس

(صيد فلمالكه) أي مالك الجارح ونحوه لأنه بسبب ملكه فكان له وكذا لو غصب شبكة أو شركا أو فخا وصاد به ولا أجرة لذلك وكذا لو كسب العبد بخلاف ما لو غصب منجلا وقطع به شجرا أو حشيشا فهو للغاصب لأنه آلة فهو كالحبل يربط به (وإن ضرب المصنوع) المغصوب (ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشبة) بابا (ونحوه أو صار الحب زرعا و) صارت (البيضة فرخا و) صار (النوى غرسا) رده (وأرش نقصه) إن نقص (ولا شيء للغاصب) نظير عمله ولو زاد به المغصوب لأنه تبرع في ملك غيره وللمالك

إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى كحلي ودراهم ونحوها (ويلزمه) أي الغاصب (ضمان نقصه) أي المغصوب ولو بنبات لحية أمرد فيغرم ما نقص من قيمته وإن جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين ما نقص من قيمته

وأرش الجناية لأن سبب كل واحد منهما قد وجد فوجب أن يضمنه بأكثرهما (وإن خصى الرقيق رده مع قيمته) لأن الخصيتين يجب فيهما كمال القيمة كما يجب فيهما كمال الدية من الحر وكذا لو قطع منه ما فيه دية كيديه أو ذكره أو أنفه (وما نقص بسعر لم يضمن) لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها عين

ولا صفة فلم يلزمه شيء (ولا) يضمن نقصا حصل (بمرض) إذا (عاد) إلى حاله (ببرئه) من المرض لزوال موجب الضمان وكذا لو انقلع سنه ثم عاد فإن رد المغصوب معيبا وزال عيبه في يد مالكه وكان أخذ الأرش لم يلزمه رده لأنه استقر ضمانه برد المغصوب وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه كذلك (وإن عاد) النقص (بتعليم صنعة) كما لو غصب عبدا سمينا قيمته مائة فهزل فصار يساوي تسعين وتعلم صنعة فزادت قيمته بها عشرة (ضمن النقص) لأن الزيادة الثانية غير الأولى (وإن تعلم) صنعة زادت بها قيمته عند الغاصب (أو سمن) عنده (فزادت قيمته ثم نسي) الصنعة (أو هزل فنقصت) قيمته (ضمن الزيادة)

لأنها زيادة في نفس المغصوب فلزم الغاصب ضمانها كما لو طالبه بردها فلم يفعل و (كما لو عادت من غير جنس الأول) بأن غصب عبدا فسمن وصار يساوي مائة ثم هزل فصار يساوي تسعين فتعلم صنعة فصار يساوي مائة ضمن نقص الهزال لأن الزيادة الثانية غير الأولى (و) إن كانت الزيادة الثانية (من جنسها) أي من جنس الزيادة الأولى كما لو نسي صنعة ثم تعلمها ولو صنعة بدل صنعة (لا يضمن) لأن ما ذهب عاد فهو كما لو مرض ثم برئ (إلا أكثرها) يعني إذا نسي صنعة وتعلم أخرى وكانت الأولى أكثر ضمن الفضل بينهما لفواته وعدم عوده وإن جنى المغصوب فعلى غاصبه أرش جنايته

%

فصل

+ (وإن خلط) المغصوب بما يتميز كحنطة بشعير وتمر بزبيب لزم الغاصب تخليصه ورده وأجرة ذلك عليه و (بما لا يتميز كزيت أوحنطة بمثلها) لزمه مثله لأنه مثلي فيجب مثله مكيله وبدونه أو خير منه أو بغير

جنسه كزيت بشيرج فهما شريكان بقدر ملكيهما فيباع ويعطى كل واحد قدر حصته وإن نقص المغصوب عن قيمته منفردا ضمنه الغاصب (أو صبغ) الغاصب (الثوب أو لت سويقا) مغصوبا (بدهن) من زيت أو نحوه (أو عكسه) بأن غصب دهنا ولت به سويقا (ولم تنقص القيمة) أي قيمة المغصوب (ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما فيه) لأن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك فيباع ويوزع الثمن على القيمتين (وإن نقصت القيمة) في المغصوب (ضمنها)

الغاصب لتعديه (وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه) أي لصاحب الملك الذي زادت قيمته بها لأنها تبع للأصل (ولا يجبر من أبى قلع الصبغ) إذا طلبه صاحبه وإن وهب الصبغ لمالك الثوب لزمه قبوله (ولو قلع غرس المشتري أو

بناءه لاستحقاقه الأرض) أي لخروج الأرض مستحقة للغير (رجع) الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال (على بائعها بالغرامة) له لأنه غره وأوهمه أنها ملكه يبيعها له (وإن أطعمه) الغاصب (لعالم بغصبه فالضمان عليه) لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير وللمالك تضمين الغاصب لأنه حال بينه وبين ماله وقرار الضمان على الآكل (وعكسه بعكسه) فإن أطعمه لغير عالم فقرار

الضمان على الغاصب لأنه غر الآكل (وإن أطعمه) الغاصب (لمالكه أو وهبه) لمالكه (أو أودعه) لمالكه (أو أجره إياه لم يبرأ) الغاصب (إلا أن يعلم) المالك أنه ملكه فيبرأ الغاصب لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته أو خياطته (ويبرأ) الغاصب (بإعارته) المغصوب لمالكه من ضمان عينه علم أنه ملكه أو لم يعلم لأنه دخل على أنه مضمون عليه والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي الضمان فإن علم الثاني فقرار الضمان عليه وإلا فعلى الأول إلا ما دخل الثاني على أنه

مضمون عليه فيستقر عليه ضمانه (وما تلف) أو أتلف من مغصوب (أو تغيب) ولم يمكن رده كعبد أبق وفرس شرد (من مغصوب مثلي) وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة لا يصح السلم فيه (غرم مثله إذا) لأنه لما تعذر رد العين

لزمه رد ما يقوم مقامها والمثل أقرب إليه من القيمة وينبغي أن يستثني منه الماء في المفازة فإنه يضمن بقيمته في مكانه ذكره في المبدع (وإلا) يمكن رد مثل المثلي لإعوازه (فقيمته يوم تعذر) لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل

فاعتبرت القيمة إذا (ويضمن غير المثلي) إذا تلف أو أتلف (بقيمته يوم تلفه)

في بلده من نقده أو غالبه لقوله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد قوم عليه

ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم حاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه كزوجي خف تلف أحدهما رد الباقي وقيمة الباقي وقيمة التالف وأرش نقصه (وإن تخمر عصير) مغصوب (ف) على الغاصب (المثل) لأن ماليته زالت تحت يده كما لو أتلفه (فإن انقلب خلا دفعه) لمالكه لأنه عين ملكه (و) دفع (معه نقص قيمته) حين كان (عصيرا) إن نقص

لأنه نقص حصل تحت يده ويسترجع الغاصب ما أداه بدلا عنه وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بإجارته لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده استوفى المنافع أو تركها تذهب %

ج ٢ - ص ٣٧٨

فصل

+ (وتصرفات الغاصب الحكمية) أي التي لها حكم من صحة وفساد كالحج والطهارة ونحوهما والبيع والإجارة والنكاح ونحوها (باطلة) لعدم إذن

المالك وإن اتجر بالمغصوب

ج ٢ - ص ٣٨٠

فالربح لمالكه

(والقول في قيمة التالف) قول الغاصب لأنه غارم (أو قدره) أي قدر المغصوب (أو صفته) بأن قال غصبتني عبدا كاتبا وقال الغاصب لم يكن كاتبا ف (قوله) أي قول الغاصب لما تقدم (و) القول (في رده أو تعيبه) بأن قال الغاصب كانت فيه أصبع زائدة أو نحوها وأنكره مالكه ف (قول ربه) لأن الأصل عدم الرد والعيب وإن شهدت البينة أن المغصوب كان معيبا وقال الغاصب كان معيبا وقت غصبه وقال المالك تعيب عندك قدم قول الغاصب لأنه غارم (وإن جهل) الغاصب (ربه) أي رب المغصوب سلمه إلى الحاكم فبرئ من عهدته ويلزمه تسلمه أو

(تصدق به عنه مضمونا) أي بنية ضمانه إن جاء ربه فإذا تصدق به كان ثوابه لربه وسقط عنه إثم الغصب

وكذا حكم رهن ووديعة ونحوها إذا جهل ربها وليس لمن هي عنده

أخذ شيء منها ولو كان فقيرا (ومن أتلف) لغيره مالا (محترما) بغير إذن

ربه ضمنه لأنه فوته عليه (أو فتح قفصا) عن طائر فطار ضمنه (أو) فتح (بابا) فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه (أو حل وكاء) زق مائع أو جامد فأذابته الشمس

أو ألقته ريح فاندفق ضمنه (أو) حل (رباطا عن فرس (أو) حل (قيدا)

عن مقيد (فذهب ما فيه أو أتلف) ما فيه (شيئ ونحوه) أي نحو ما ذكر (ضمنه) لأنه تلف بسبب فعله (وإن ربط دابته بطريق ضيق فعثر به إنسان) أو أتلف شيئا (ضمن) لتعديه بالربط ومثله لو ترك في الطريق طينا أو خشبة

أو حجرا أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط (ك) ما يضمن مقتني (الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج) منزله لأنه متعد باقتنائه فإن دخل منزله بغير إذنه لم يضمنه لأنه متعد بالدخول وإن أتلف العقور شيئا بغير العقر كما لو ولغ أو بال في إناء إنسان فلا ضمان لأن هذا لا يختص بالعقور وحكم أسد

ونمر وذئب وهر تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة حكم كلب عقور وله قتل هر بأكل لحم ونحوه كالفواسق وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن

ما تلف بها وإن حفرها لنفع المسلمين بلا ضرر في سابلة لم يضمن ما تلف بها

لأنه محسن وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه لأن الميل حادث والسقوط بغير فعله (وما أتلفت البهيمة من الزرع) والشجر وغيرهما

(ليلا) ضمنه صاحبها (وعكسه النهار) لما روى مالك عن الزهري عن حزام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم (إلا أن ترسل) نهارا (بقرب ما تتلفه عادة) فيضمن مرسلها لتفريطه

وإذا طرد دابة من زرعه لم يضمن إلا أن يدخلها مزرعة غيره فإذا اتصلت المزارع صبر ليرجع على ربها ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع فتركها فهدر (وإن كانت) البهيمة (بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها) كيدها وفمها (لا) ما جنت (بمؤخرها) كرجلها لما روي عن سعيد مرفوعا الرجل جبار وفي رواية أبي هريرة رجل العجماء جبار ولو كان السبب من غيرهم كنخس وتنفير ضمن فاعله

فلو ركبها اثنان فالضمان على المتصرف منهما (وباقي جنايتها هدر) إذا لم يكن يد أحد عليها لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار أي هدر إلا الضارية والجوارح وشبهها (كقتل الصائل عليه) من آدمي أو غيره إن لم يندفع إلا بالقتل

فإذا قتله لم يضمنه لأن قتله بدفع جائز لما فيه من صيانة النفس (و) ك (كسر مزمار) أو غيره من آلات اللهو (وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة) لما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشقت

بحضرته وأمر أصحابه بذلك ولا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة ولا حليا محرما على رجال إذا لم يصلح للنساء

باب الشفعة

+ الشفعة بإسكان الفاء من الشفع وهو الزوج لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا (وهي استحقاق) الشريك (انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي) كالبيع والصلح والهبة بمعناه فيأخذ الشفيع نصيب البائع (بثمنه الذي استقر عليه العقد) لما روى أحمد والبخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (فإن انتقل) نصيب الشريك (بغير عوض)

كالإرث والهبة بغير ثواب والوصية (أو كان عوضه) غير مالي بأن جعل (صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة) لأنه مملوك بغير مال أشبه الإرث ولأن الخبر ورد في البيع وهذه ليست في معناه (ويحرم التحيل لإسقاطها) قال الإمام لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم واستدل الأصحاب بما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل (وتثبت) الشفعة (لشريك في أرض تجب قسمتها) فلا شفعة في منقول كسيف ونحوه

لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص ولا فيما لا تجب قسمته كحمام ودور صغيرة ونحوها لقوله صلى الله عليه وسلم لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة رواه أبو عبيدة في الغريب والمنقبة طريق ضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد (ويتبعها) أي الأرض (الغراس والبناء) فتثبت الشفعة فيهما تبعا للأرض إذا بيعا معها لا إن بيعا منفردين (لا الثمرة والزرع) إذا بيعا مع الأرض فلا يؤخذان بالشفعة لأن ذلك لا يدخل في البيع فلا يدخل في الشفعة

كقماش الدار (فلا شفعة لجار) لحديث جابر السابق (وهي) أي الشفعة

(على الفور وقت علمه فإن لم يطلبها إذن) أي وقت علم الشفيع بالبيع (بلا عذر بطلت) لقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة لمن واثبها وفي رواية الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجه فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون وكذا لو أخر لعذر بأن علم ليلا فأخره إلى الصباح أو لحاجة أكل أو شرب أو

طهارة أو إغلاق باب أو خروج من حمام أو ليأتي بالصلاة وسننها وإن علم وهو غائب أشهد على الطلب بها إن قدر

(وإن قال) الشفيع (للمشتري بعني) ما اشتريت (أو صالحني) سقطت لفوات الفور (أو كذب العدل) المخبر له بالبيع سقطت لتراخيه عن الأخذ بلا عذر فإن كذب فاسقا لم تسقط لأنه يعلم الحال على وجهه (أو طلب) الشفيع (أخذ البعض) أي بعض الحصة المبيعة (سقطت) شفعته لأن فيه إضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه والضرر لا يزال بمثله ولا تسقط الشفعة إن عمل الشفيع دلالا بينهما أو توكل لأحدهما أو أسقطها قبل البيع (والشفعة

ل) شريكين (اثنين بقدر حقيهما) لأنها حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الأملاك فدار بين ثلاثة ونصف وثلث وسدس فباع رب الثلث فالمسألة من ستة والثلث يقسم على أربعة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد (فإن عفا أحدهما) أي أحد الشفيعين (أخذ الآخر الكل أو ترك) الكل لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري ولو وهبها لشريكه أو غيره لم يصح وإن كان أحدهما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك فإن أخذ الكل ثم حضر الغائب قاسمه (وإن اشترى اثنان حق واحد) فللشفيع أخذ حق أحدهما لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين (أو عكسه) بأن اشترى واحد حق اثنين صفقة فللشفيع أخذ أحدهما لأن تعدد البائع كتعدد المشتري (أو اشترى واحد شقصين) بكسر الشين أي حصتين (من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما) لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض (وإن باع شقصا وسيفا) في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن لأنه تجب فيه

الشفعة إذا بيع منفردا فكذا إذا بيع مع غيره (أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن) لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي كما لو أتلفه آدمي فلو اشترى دارا بألف تساوي ألفين فباع بابها أو هدمها فبقيت بألف

أخذها الشفيع بخمسمائة (ولا شفعة بشركة وقف) لأنه لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب به لأن مستحقه غير تام الملك (ولا) شفعة أيضا ب (غير ملك) للرقبة (سابق) بأن كان شريكا في المنفعة كالموصي له بها أو ملك الشريكان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم الضرر (ولا) شفعة (لكافر على مسلم) لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه %

فصل

+ (وأن تصرف مشتريه) أي مشتري شقص ثبتت فيه الشفعة (بوقفه أو هبته

أو رهنه) أو صدقة به (لا بوصية سقطت الشفعة) لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه والموهوب له ونحوه لأنه ملكه بغير عوض ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به قبل قبول الموصى له بعد موت الموصي لعدم لزوم الوصية (و) إن تصرف المشتري فيه (ببيع فله) أي للشفيع (أخذه بأحد البيعين) لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما ولأنه شفيع في العقدين فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له لأن العوض لم يسلم له وإن أجره فللشفيع أخذه وتنفسخ به الإجارة هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب لأنه ملك المشتري وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه وأما تصرفه بعد الطلب فباطل لأنه ملك الشفيع إذا (وللمشتري الغلة) الحاصلة قبل الأخذ (و) له أيضا (النماء المنفصل) لأنه من ملكه والخراج بالضمان (و) له أيضا (الزرع والثمرة الظاهرة) أي المؤبرة لأنه ملكه ويبقى إلى الحصاد والجذاذ لأن ضرره لا يبقى ولا أجرة عليه وعلم منه أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة كالرد بالعيب (فإن بنى) المشتري (أو غرس) في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو رفع الأمر للحاكم

فقاسمه أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه ثم غرس أو بنى (فللشفيع تملكه بقيمته) دفعا للضرر فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء (و) للشفيع (قلعه ويغرم نقصه) أي ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الضرر به فإن أبى فلا شفعة (ولربه) أي رب الغراس أو البناء (أخذه) ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته (بلا ضرر) يلحق الأر ض بأخذه وكذا مع ضرر كما في المنتهى وغيره لأنه ملكه والضرر لا يزال بالضرر (وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت) الشفعة لأنه خيار للتمليك أشبه خيار القبول (و) إن مات (بعده) أي بعد الطلب ثبتت (لوارثه) لأن

الحق قد تقرر بالطلب ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده (ويأخذ) الشفيع الشقص (بكل الثمن) الذي استقر عليه العقد لحديث جابر فهو أحق به بالثمن رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم (فإن عجز عن) الثمن أو (بعضه سقطت شفعته) لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري والضرر لا يزال بالضرر وإن حضر رهنا أو كفيلا لم يلزم المشتري قبوله وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن وللمشتري حبسه على ثمنه قاله في الترغيب وغيره لأن الشفعة قهري والبيع عن رضى ويمهل إن تعذر في الحال ثلاثة أيام (و) الثمن (المؤجل يأخذ) الشفيع (المليء به) لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته (وضده) أي ضد المليء وهو المعسر يأخذه إذا كان الثمن مؤجلا (بكفيل مليء) دفعا للضرر وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال (ويقبل في الحلف) في قدر الثمن (مع عدم البينة) لواحد منهما (قول

المشتري) مع يمينه لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن والشفيع ليس بغارم لأنه لا شيء عليه وإنما يريد تملك الشقص بثمنه بخلاف الغاصب ونحوه (فإن قال) المشتري (اشتريته بألف أخذ الشفيع به) أي بالألف (ولو أثبت البائع) أن البيع (بأكثر) من الألف مؤاخذة للمشتري بإقراره فإن قال غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل لأنه رجوع عن إقراره ومن ادعى على إنسان شفعة في شقص فقال ليس لك ملك في شركتي فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة ولا يكفي مجرد وضع اليد (وإن أقر البائع بالبيع) في الشقص المشفوع (وأنكر المشتري) شراءه (وجبت) الشفعة لأن البائع أقر بحقين حق للشفيع وحق للمشتري فإن أسقط حقه بإنكاره ثبت حق الأخر فيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن ويكون درك الشفيع على البائع وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري (وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع) في غير الصورة الأخيرة فإذا ظهر الشقص مستحقا أو معيبا رجع الشفيع على المشتري

بالثمن وبأرش العيب ثم يرجع المشتري على البائع فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه ولا في أرض السواد ومصر والشام لأن عمر وقفها إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه لأنه مختلف فيه وحكم الحاكم ينفذ فيه

ج ٢ - ص ٤١٥

باب الوديعة

+ من ودع الشيء إذا تركه لأنها متروكه عند المودوع والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا والاستيداع توكل فيه كذلك ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة ويستحب قبولها لمن علم أنه ثقه قادر على حفظها ويكره لغيره إلا برضى ربها و (إذا تلفت) الوديعة (من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فلا ضمان عليه رواه ابن ماجه سواء ذهب معها شيء من ماله أو لا (ويلزمه) أي المودع (حفظها في حرز مثلها) عرفا كما يحفظ ماله لأنه تعالى أمر بأدائها ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ قال في الرعاية من استودع شيئا حفظه

في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمن (فإن عينه) أي الحرز (صاحبها فأحرزها بدونه ضمن) سواء ردها إليه أو لا لمخالفته له في حفظ ماله (و) إن أحرزها (بمثله أو أحرز) منه (فلا) ضمان عليه لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله فما فوقه من باب أولى (وإن قطع العلف عن الدابة) المودعة (بغير قول صاحبها ضمن) لأن العلف من كمال الحفظ بل هو الحفظ بعينه لأن العرف يقتضي علفها وسقيها فكأنه مأمور به عرفا وإن نهاه المالك عن علفها وسقيها لم يضمن إتلافها أشبه مالو أمره بقتلها لكن يأثم بترك علفها إذا لحرمة الحيوان (وإن عين جيبه) بأن قال احفظها في جيبك (فتركها في كمه أو يده ضمن) لأن الجيب أحرز وربما نسي فسقط مافي كمه أو يده (وعكسه بعكسه) فإذا قال اتركها في كمك أو يدك فتركها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز وإن قال اتركها في يدك فتركها في كمه أو بالعكس أو قال اتركها في بيتك فشدها

في ثيابه وأخرجها ضمن لأن البيت أحرز (وإن دفعها إلى من يحفظ ماله) عادة كزوجته وعبده (أو) ردها لمن يحفظ (مال ربها لم يضمن) لجريان العادة

به ويصدق في دعوى التلف والرد كالمودع (وعكسه الأجنبي والحاكم) بلا عذر فيضمن المودع بدفعها إليهما لأنه ليس له أن يودع من غير عذر (ولا يطالبان) أي الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط (إن جهلا) جزم به في الوجيز لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ فلا يجب على الثاني ضمان لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين وقال القاضي له ذلك فللمالك مطالبة من شاء منهما ويستقر الضمان على الثاني إن علم وإلا فعلى الأول وجزم بمعناه في المنتهى (وإن حدث خوف أو) حدث للمودع (سفر ردها على ربها) أو وكيله فيها لأن في ذلك تخليصا له من دركها فإن دفعها للحاكم إذن ضمن لأنه لا ولاية له على الحاضر (فإن غاب) ربها (حملها) المودع (معه) في السفر سواء كان لضرورة أو لا (إن كان أحرز) ولم ينهه عنه لأن القصد الحفظ وهو موجود هنا وله ما أنفق بنية الرجوع قاله القاضي

(وإلا) يكن السفر أحفظ لها أو كان نهي عنه دفعها إلى الحاكم لأن في السفر بها غررا لأنه عرضة للنهب وغيره والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته فإن أودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها لأنه لا ولاية له فإن تعذر حاكم (أودعها أهل ثقة) لفعله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله عنها لأنه موضع حاجة وكذا حكم من حضره الموت (ومن) تعدى في الوديعة بأن (أودع دابة فركبها لغير نفعها) أي علفها وسقيها (أو) أودع (ثوبا فلبسه) لغير خوف من عث أو نحوه (أو) أودع (دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها) إلى حرزها (أو رفع الختم) عن كيسها أو كانت مشدودة فأزال الشد ضمن أخرج منها شيئا أو لا لهتك الحرز (أو خلطها بغير متميز) كدراهم بدراهم وزيت بزيت في ماله أو غيره (فضاع الكل ضمن) الوديعة لتعديه وإن ضاع البعض ولم يدر أيهما ضاع ضمن أيضا وإن خلطها بتميز كدراهم بدنانير لم يضمن وإن أخذ درهما من غير محرزه ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع ومن أودعه صبي

وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه ومن دفع لصبي ونحوه وديعة يضمنها مطلقا ولعبده ضمنها بإتلافها في رقبته %

فصل

+ (ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها) ومن يحفظ ماله (أو غيره بإذنه) بأن قال دفعتها لفلان بإذنك فأنكر مالكها الإذن أو الدفع قبل قول المودع كما لو ادعى ردها على مالكها (و) يقبل قوله أيضا (في تلفها وعدم التفريط) بيمينه لأنه أمين لكن إن ادعى التلف بظاهر كلف به ببينة ثم قبل قوله في التلف وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره وإن أمره بالدفع إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن ولو لم يطلبها وكيله (فإن قال لم تودعني ثم ثبتت) الوديعة (ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة) لأنه مكذب للبينة وإن شهدت

بأحدهما ولمن تعين وقتا لم تسمع (بل) يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف (في) ما إذا أجاب ب (قوله مالك عندى شيء ونحوه) كما لو أجاب بقوله لا حق لك قبلي أو لا تستحق علي شيئا (أو) ادعى الرد أو التلف (بعده) أي بعد جحوده (بها) أي بالبينة لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها (وإن) مات المودع و (ادعى وارثه الرد منه) أي من وارث المودعين لربها (أو من مورثه) وهو المودع (لم يقبلا إلا ببينة) لأن صاحبها لم يأتمنه عليها بخلاف المودع (وإن

طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم) بلا ضرر (أخذه) أي أخذ نصيبه فيسلم إليه لأن قسمته ممكنه بغير ضرر ولا غبن (وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر) إذا غصبت العين منهم (مطالبه غاصب العين) لأنهم مأمورون بحفظها وذلك منه وإن صادره سلطان أو أخذها منه قهرا لم يضمنه قاله أبو الخطاب

21 باب إحياء الموات

+ بفتح الميم والواو (وهي) مشتقة من الموت وهو عدم الحياة واصطلاحا (الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم) بخلاف الطرق والأقنية ومسيل المياه والمحتطبات ونحوها وما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرهما فلا يملك شيئا من ذلك بالإحياء

(فمن أحياها) أي الأرض الموات (ملكها) لحديث جابر يرفعه من أحيا أرضا ميتة فهي له رواه أحمد والترمذي وصححه وعن عائشة مثله رواه مالك وأبو داود وقال ابن عبد البر هو سند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم (من مسلم وكافر) ذمي مكلف وغيره لعموم ما تقدم لكن على الذمي خراج ما أحيى من موات عنوة (بإذن الإمام) في الإحياء (وعدمه) لعموم الحديث ولأنها عين مباحة فلا يفتقر ملكها إلى إذن (في دار الإسلام وغيرها) فجميع البلاد سواء في ذلك (والعنوة) كأرض مصر والشام والعراق (كغيرها) مما أسلم أهله عليه أو صولحوا عليه إلا ما أحياه مسلم من أرض كفار صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج (ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته) لعموم ما تقدم وانتفاء المانع فإن تعلق بمصالحه كمقبرة وملقى

كناسة ونحوهما لم يملك وكذا موات الحرم وعرفات لايملك بالإحياء وإذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع فلها سبعة أذرع ولا تغير بعد وضعها ولا يملك معدن ظاهر كملح وكحل وجص بإحياء وليس للإمام إقطاعه وما نصب عنه الماء من الجزائر لم يحي بالبناء لأنه يرد الماء إلى الجانب الأخر فيضر بأهله وينتفع به بنحو زرع (ومن أحاط مواتا) بأن أدار حوله حائطا منيعا بما جرت العادة به فقد أحياه سواء أرادها للبناء أو غيره لقوله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له رواه أحمد وأبو داود عن جابر (أو حفر بئرا فوصل إلى الماء) فقد أحياه (أو أجراه) أي الماء (إليه) أي إلى الموات (من عين ونحوها أو حبسه) أي الماء (عنه) أي عن الموات إذا كان

لا يزرع معه (لزرع فقد أحياه) لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط ولا إحياء بحرث وزرع (ويملك) المحيي (حريم البئر العادية) بتشديد الياء أي القديمة منسوبة إلى عاد ولم يردها عادا بعينها (خمسين ذراعا من كل جانب) إذا كانت انطمت وذهب ماؤها فجدد حفرها وعمارتها أو انقطع ماؤها فاستخرجه (وحريم البداية) المحدثة (نصفها) خمسة وعشرون ذراعا لما روى أبو عبيد في الإموال عن سعيد بن المسيب قال السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعا والبدي خمسة وعشرون ذراعا وروى الخلال والدارقطني نحوه مرفوعا وحريم شجرة قدر مد أغصانها وحريم دار من موات حولها مطرح تراب وكناسة وثلج وماء ميزاب ولا حريم لدار محفوفة بملك ويتصرف في كل منهم بحسب العادة ومن يحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا ونحوها لم يملكه وهو أحق به

ووارثه من بعده وليس له بيعه (وللإمام إقطاع موات لمن يحييه) لأنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق (ولا يملكه) بالإقطاع بل هو

أحق من غيره فإذا أحياه ملكه وللإمام أيضا إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة (و له إقطاع الجلوس) للبيع والشراء (في الطريق الواسعة) ورحبة مسجد غير محوطة (مالم يضر بالناس) لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلا عما فيه مضرة (ويكون) المقطع له (أحق بجلوسها) ولا يزول حقه بنقل متاعه منها لأنه قد استحق بإقطاع الإمام وله التظليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر ويسمى هذا إقطاع إرفاق (ومن غير إقطاع) للطرق الواسعة والرحبة غير المحوطة الحق (لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال) جزم به في الوجيز لأنه سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فلم يمنع فإذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس وفي المنتهى وغيره فإن أطاله أزيل لأنه يصير كالمالك

(وإن سبق اثنان) فأكثر إليها وضاقت (اقتراعا) لأنهما استويا في السبق والقرعة مميزة ومن سبق إلى مباح من صيد أو حطب أو معدن ونحوه فهو أحق به وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما (ولمن في أعلى الماء المباح) كماء مطر (السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه) فيفعل كذلك وهلم جرا فإن لم يفضل عن الأول أو من بعده شيء فلا شيء للآخر لقوله صلى الله عليه وسلم اسق يازبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر متفق عليه وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نظرناالى قول النبي

صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فكان ذلك إلى الكعبين فإن كان الماء مملوكا قسم بين الملاك بقدر النفقة والعمل وتصرف كل واحد في حصته بما شاء (وللإمام دون غيره حمى مرعى) أي أن يمنع الناس من مرعى (لدواب المسلمين) التي يقوم بحفظها نكيل الجهاد والصدقة (مالم يضرهم) بالتضييق عليهم لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى البقيع لخيل المسلمين رواه أبو عبيد وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد نقضه وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعى موات أو حمى لأنه صلى الله عليه وسلم شرك الناس فيه ومن جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء فهو أحق بمكانه مادام فيه أو غاب لعذر وعاد قريبا ومن سبق إلى رباط أو نزل فقيه بمدرسة أو صوفي بخانقاه لم يبطل حقه بخروجه منه لحاجة

22 باب الجعالة

+ الجعالة بتثليث الجيم قاله ابن مالك قال ابن فارس الجعل والجعالة والجعيلة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله (وهي) اصطلاحا (أن يجعل) جائز التصرف (شيئا)

متمولا (معلوما لمن يعمل له عملا معلوما) كرد عبده من محل كذا أو بناء حائط كذا (أو) عملا (مجهولا من مدة معلومة) كشهر كذا (أو) مدة (مجهولة) فلا

يشترط العلم بالعمل ولا المدة ويجوز الجمع بينهما هنا بخلاف الإجارة ولا تعيين العامل للحاجة ويقوم العمل مقام القبول لأنه يدل عليه كالوكالة ودليلها قوله تعالى ﴿ ولمن جاء به حمل بعير ﴾ وحديث الديغ والعمل الذي يؤخذ الجعل

عليه (كرد عبد ولقطة) فإن كانت في يده فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح له أخذه (و) ك (خياطة وبناء حائط) وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال (فلمن فعله بعد علمه بقوله) أي بقول صاحب العمل من فعل كذا فله كذا (استحقه) لأن العقد استقر بتمام العمل (والجماعة) إذا عملوه (يقتسمونه) بالسوية لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا فيه (و) إن بلغه الجعل (في أثنائه) أي أثناء العمل (يأخذ قسط تمامه) لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون فيه فلم يستحق به عوضا وإن لم يبلغه إلا بعد العمل لم يستحق شيئا لذلك (و) الجعالة عقد جائز (لكل) منهما (فسخها) كالمضاربة (ف) متى كان

الفسخ (من العامل) قبل تمام العمل فإنه (لا يستحق شيئا) لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه (و) إن كان الفسخ (من الجاعل بعد الشروع) في العمل ف (للعامل أجرة مثل عمله) لأنه عمله بعوض لم يسلم له وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز لأنها عقد جائز (ومع الاختلاف في أصله) أي أصل الجعل (أو قدره يقبل قول الجاعل) لأنه منكر والأصل براءة ذمته (ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل) ولا إذن (لم يستحق عوضا) لأنه بذل منفعة بغير عوض فلم يستحقه ولئلا يلزم الإنسان مالم يلتزمه (إلا) في تخليص متاع غيره من هلكة فله أجرة المثل ترغيبا وإلا (دينارا أو اثنى عشر درهما عن رد الآبق) من المصر أو خارجه روي عن عمر وعلي وابن مسعود لقول ابن أبي مليكة وعمرو

بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم دينارا (ويرجع) راد الآبق (بنفقته أيضا) لأنه مأذون في الإنفاق شرعا لحرمة النفس ومحله إن لم ينو التبرع ولو هرب منه في الطريق وإن مات السيد رجع في تركته وعلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده وهو أمانة بيده ومن أعاده فصدقة العبد أخذه فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه ليحفظه لصاحبه وله بيعه لمصلحة ولا يملكه ملتقطه بالتعريف كضوال الإبل وإن باعه ففاسد

باب اللقطة

+ اللقطة بضم اللام وفتح القاف ويقال لقاطة بضم اللام ولقطة بفتح اللام والقاف (وهي مال أو مختص ضل عن ربه) قال بعضهم وهي مختصة بغير الحيوان ويسمى ضالة (و) يعتبر فيما يجب تعريفه أن (تتبعه همة أوساط الناس) بأن يهتموا في طلبه (فأما الرغيف والسوط) وهو الذي يضرب به وفي شرح المهذب هو فوق القضيب ودون العصا (ونحوهما) كشسع نعل (فيملك) بالالتقاط (بلا تعريف) ويباح الانتفاع به لما روى جابر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به رواه أبو داود وكذا التمرة والخرقة وما لا خطر له ولا يلزمه دفع بدله (وما امتنع من سبع

صغير) كذئب ويرد الماء (كثور وجمل ونحوهما) كالبغال والحمير والظباء والطيور والفهود ويقال لها الضوال والهوامي والهوامل (حرم أخذه) لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها متفق عليه وقال عمر من أخذ

الضالة فهو ضال أي مخطىء فإن أخذها ضمنها وكذا نحو حجر طاحون وخشب كبير (وله التقاط غير ذلك) أي غير ما تقدم من الضوال ونحوها (من حيوان) كغنم وفصلان وعجاجيل وأفلاء (وغيره) كأثمان ومتاع (إن أمن نفسه على ذلك) وقوي على تعريفها لحديث زيد بن خالد الجهني قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن

جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب متفق عليه مختصرا والأفضل تركها روي عن ابن عباس وابن عمر (وإلا) يأمن نفسه عليها (فهو كغاصب) فليس له أخذها لما فيه من تضييع مال غيره ويضمنها إن تلفت فرط أو لم يفرط ولا يملكها وإن عرفها ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها ويخير في الشاة ونحوها بين ذبحها وعليه القيمة أو بيعها ويحفظ ثمنها أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع وما يخشى فساده له بيعه وحفظ ثمنه أو أكله بقيمته أو

تجفيف ما يمكن تجفيفه (ويعرف الجميع) وجوبا لحديث زيد السابق نهارا (في مجامع الناس) كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات لأن المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها صاحبها (غير المساجد) فلا تعرف فيها (حولا) كاملا روي عن عمر وعلي وابن عباس عقب الالتقاط لأن صاحبها يطلبها إذا كل يوم ثم أسبوعا ثم عرفا وأجرة المنادي على الملتقط (ويملكه بعده) أي بعد التعريف (حكما) أي من غير اختيار كالميراث غنيا كان أو فقيرا لعموم ما سبق ولا يملكها بدون تعريف (لكن لا يتصرف فيها

قبل معرفة صفاتها) أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها ويستحب ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها (فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه) بلا بينة ولا يمين وإن لم يغلب على ظنه صدقه لحديث زيد وفيه فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطاها إياه وإلا فهي لك رواه مسلم ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا لا قبله إن لم يفرط (والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما) لقيامه مقامهما ويلزمه أخذها منهما فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها فإن لم تعرف فهي لهما وإن وجدها

عبد عدل فلسيده أخذها منه وتركها معه ليعرفها فإن لم يأمن سيده عليها سترها عنه وسلمها للحاكم ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان والمكاتب كالحر ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده (ومن ترك حيوانا) لا عبدا أو متاعا (بفلاة لانقطاعه أو عجز عنه ربه ملكه آخذه) بخلاف عبد ومتاع وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه آخذه وإن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه أجرة المثل (ومن أخذ نعله ونحوه) من متاعه (ووجد موضعه غيره فلقطه) ويأخذ حقه منه بعد تعريفه وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي له

باب اللقيط

+ بمعنى ملقوط (وهو) اصطلاحا (طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ) أي طرح في شارع أو غيره (أو ضل) (وأخذه فرض كفاية) لقوله تعالى ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ﴾ ويسن الإشهاد عليه (وهو حر) في جميع الأحكام لأن الحرية هي الأصل والرق عارض (وما وجد معه) من فراش تحته أو ثياب فوقه أو مال في جيبه (أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان أو غيره) مشدودا بثيابه (أو) مطروحا (قريبا منه ف) هو (له) عملا بالظاهر ولأن له يدا صحيحة كالبالغ (وينفق عليه منه) ملتقطه بالمعروف لولايته عليه (وإلا) يكن معه شيء (فمن بيت المال) لقول عمر رضي الله عنه اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته وفي لفظ وعلينا رضاعه ولا يجب على الملتقط فإن تعذر الإنفاق من بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين فإن تركوه أثموا (وهو مسلم) إذا وجد في دار الإسلام وإن كان فيها أهل ذمة تغليبا لأهل الإسلام

والدار و إن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه فكافر تبعا للدار (وحضانته لواجده

الأمين) لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه إنه رجل صالح (وينفق عليه) مما وجد معه من نقد أو غيره (بغير إذن حاكم) لأنه وليه وإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم أو بدويا ينتقل في المواضع أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر بيده (وميراثه وديته) كدية حر

(لبيت المال) إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط ولا ولاء عليه لحديث أنما الولاء لمن أعتق (ووليه في) القتل (العمد) العدوان (الإمام يخير بين القصاص والدية) لبيت المال لأنه ولي من لا ولي له وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يعفو وإن ادعى إنسان أنه مملوكه و لم يكن بيده

لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه (وإن أقر رجل أو امرأة) ولو (ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به) لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه وشرطه أن ينفرد بدعوته وأن يمكن كونه منه حرا كان أو عبدا وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها كعكسه (ولو بعد موت اللقيط) فيلحقه وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطيا للنسب (ولا يتبع) اللقيط (الكافر) المدعي أنه ولده (في دينه) إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة وكذا لا يتبع رقيقا في رقه (و إن اعترف) اللقيط (بالرق مع سبق مناف) للرق من بيع ونحوه أو عدم سبقه لم يقبل لأنه

يبطل حق الله من الحرية المحكوم بها سواء أقر ابتداء لإنسان أو جوابا بالدعوى عليه (أو قال) اللقيط بعد بلوغه (إنه كافر لم يقبل منه) لأنه محكوم بإسلامه ويستثاب فإن تاب وإلا قتل (وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة) مسلما أو كافرا حرا أو عبدا لأنها تظهر الحق وتبينه (وإلا) يكن لهم بينة أو تعارضت عرض معهم على القافة (فمن ألحقته القافة به) لحقه لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وإن ألحقته بإثنين فأكثر لحق بهم وإن ألحقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفره ولا رقه ولا يلحق بأكثر من أم والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة ويكفي واحد وشرطه أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة ويكفي مجرد خبرة

وكذا إن وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد وأتت بولد يمكن أن يكون منهما

9

كتاب الوقف

+ يقال وقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله بمعنى واحد وأوقفه لغة شاذة وهو مما اختص به المسلمون ومن القرب المندوب إليها (وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة) على بر أو قربة والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف (ويصح) الوقف (بالقول وبالفعل الدال عليه) عرفا (كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه) أو إذن فيه وأقام (أو) جعل أرضه (مقبرة وأذن) للناس (في الدفن فيها) أو سقاية وشرعها لهم لأن العرف جار بذلك وفيه دلالة على الوقف (وصريحه) أي صريح القول (وقفت وحبست وسبلت) فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا

من غير انضمام أمر زائد (وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت) لأنه لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي (فتشترط النية مع الكناية أو اقتران) الكناية ب (أحد الألفاظ الخمسة) الباقية من الصريح والكناية كتصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف (أو اقترانها ب (حكم الوقف) كقوله تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث

(ويشترط فيه) أربعة شروط الأول (المنفعة) أي أن تكون العين ينتفع

بها (دائما من عين) فلا يصح وقف شيء في الذمة كعبد ودار ولو وصفه كالهبة (ينتفع به مع بقاء عينه) كعقار وحيوان ونحوهما) من أثاث وسلاح ولا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد موصى له بها ولا عين لا يصح بيعها كحر وأم ولد ولا ما لا ينتفع به مع بقائه كطعام لأكل ويصح وقف المصحف والمال المشاع (و) الشرط الثاني (أن يكون على بر) إذا كان على جهة عامة لأن المقصود منه التقرب إلى الله تعالى وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود (كالمساجد والقناطر والمساكن) والسقايات وكتب العلم (والأقارب من مسلم وذمي) لأن القريب الذمي موضع القرابة بدليل جواز الصدقة عليه

ووقفت صفية رضي الله عنها على أخ لها يهودي فيصح الوقف على كافر معين (غير حربي) ومرتد لانتفاء الدوام لأنهما مقتولان عن قرب (و) غير (كنيسة) وبيعة وبيت نار وصومعة فلا يصح الوقف عليها لأنها بنيت للكفر والمسلم والذمي في ذلك سواء (و) غير (نسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة) وبدع مضلة فلا يصح الوقف على ذلك لأنه إعانة على معصية وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأي مع عمر شيئا استكتبه من التواره وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب ألم آت بها بيضاء نقية ولو كان أخي موسى حيا ماوسعه إلا اتباعي ولا يصح أيضا على قطاع الطريق أو المغاني أو فقراء أهل

الذمة أو التنوير على قبر أو تبخيره أو على من يقيم عنده أو يخدمه ولا وقف ستور لغير الكعبة (وكذا الوصية) فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه (و) كذا (الوقف على نفسه) قال الإمام لاأعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى أو في سبيله فإن وقفه عليه حتى يموت فلا يموت فلا أعرفه لأن الوقف إما تمليك للرقبة أو المنفعة ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه ويصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء فإن وقف على غيره واستثنى كل الغلة أو بعضها أو الأكل منه مدة حياته أو مدة معلومة صح الوقف والشرط لشرط عمر رضي الله عنه أكل الوالي منها وكان هو الوالي عليها وفعله جماعة من الصحابة والشرط الثالث ما أشار إليه بقوله (ويشترط في غير) الوقف على (المسجد ونحوه) كالرباط والقنطرة (أن يكون على معين يملك) ملكا ثابتا لأن الوقف تمليك فلا يصح على مجهول كرجل ومسجد ولا على أحد هذين ولا على عبد ومكاتب و (لا) على (ملك) وجني وميت (وحيوان وحمل وقبر) أصالة ولا

على من سيولد ويصح على ولده ومن يولد له ويدخل الحمل والمعدوم تبعا

الشرط الرابع أن يقف ناجزا فلا يصح مؤقتا ولا معلقا إلا بموت وإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط قاله في الشرح (لا قبوله) أي قبول الوقف فلا يشترط ولو كان على معين (ولا إخراجه عن يده) لأنه إزالة ملك يمنع البيع فلم يعتبر فيه ذلك كالعتق

وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال لهم وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر مآلا أو قال هذا وقف ولم يعين جهة صح وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليهم لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره فإن لم يكونوا فعلى المساكين %

فصل

+ (ويجب العمل بشرط الواقف) لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة (في جمع) بأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه (وتقديم) بأن يقف على أولاده

مثلا يقدم الأفقه أو الأدين أو المريض ونحوه (وضد ذلك) فضد الجمع الإفراد بأن يقف على ولده زيد ثم أولاده فضد التقديم التأخير بأن يقف على ولد فلان بعد بني فلان (واعتبار وصف أو عدمه) بأن يقول على أولاده الفقهاء

فيختص بهم أو يطلق فيعمهم وغيرهم (والترتيب) بأن يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولادهم (ونظر) بأن يقول الناظر فلان فإن مات ففلان لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه ذو الرأي

467 من أهلها (وغير ذلك) كشرط أن لا يؤجر أو قدر مدة الإجارة

أو أن لا ينزل فيه فاسق أو شرير أو متجوه ونحوه وإن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي (فإن أطلق) في الموقوف عليه (ولم يشترط)

وصفا (استوى الغني والذكر وضدهما) أي الفقير والأنثى لعدم ما يقتضي التخصيص (والنظر) فيما إذا لم يشترط النظر لأحد أو شرط لإنسان ومات فالنظر (للموقوف عليه) المعين لأنه ملكه وغلته له فإن كان واحدا استقل به

مطلقا وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم وإن كان صغيرا أو نحوه قام وليه مقامه فيه (وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم وله أن يستنيب فيه (وإن وقف على ولده) أو أولاده (أو ولد غيره ثم

على المساكين فهو لولده) الموجود حين الوقف (الذكور والإناث) والخناثي لأن اللفظ يشملهم (بالسوية) لأنه شرك بينهم وإطلاقها يقتضي التسوية كما لو أقر لهم بشيء ولا يدخل فيهم الولد المنفي باللعان لأنه لا يسمى ولده (ثم) بعد أولاده

ل (ولد بنيه) وإن سفلوا لأنه ولده ويستحقونه مرتبا وجدوا حين الوقف

أو لا (دون) ولد (بناته) فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الأولاد إلا بنص أو قرينة لعدم دخولهم في قوله تعالى ﴿ يوصيكم الله في أولادكم ﴾ كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه أو عقبه أو نسله فيدخل

والعطف ب ثم للترتيب فلا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض الأول إلا أن يقول من مات عن ولد فنصيبه لولده

والعطف بالواو للتشريك (ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم) لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة قال تعالى ﴿ أم له البنات ولكم البنون ﴾

إلا أن يكونوا قبيلة كبني هاشم وتميم وقضاعة (فيدخل فيه النساء) لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها (دون أولادهن من غيرهم) لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها (والقرابة) إذا وقف على قرابته أو قرابة زيد (وأهل بيته وقومه) ونسبائه (يشمل الذكر والأنثى من أولاده و) أولاد (أبيه و) أولاد (جده و) أولاد (جد أبيه) فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى ولم يعط قرابة أمه وهم بنو زهرة شيئا ويستوي فيه الذكر والأنثى والكبير والصغير والقريب والبعيد والغني والفقير لشمول اللفظ لهم ولا يدخل

فيهم من يخالف دينه وإن وقف على ذوي رحمه شمل كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأولاد لأن الرحم يشملهم والموالي يتناول المولى من فوق وأسفل (وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الأناث أو) تقتضي (حرمانهن عمل بها) أي بالقرينة لأن دلالتها كدلالة اللفظ (وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم) كأولاده أو أولاد زيد وليسوا قبيلة (وجب تعميمهم والتساوي) بينهم لأن اللفظ يقتضي ذلك وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه فصار مما لا يمكن استيعابه كوقف علي رضي الله عنه وجب تعميم من أمكن منهم والتساوي بينهم (وإلا) يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وتميم لم يجب تعميمهم لأنه غير ممكن و (جاز التفضيل) لبعضهم على بعض لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه (والاقتصار على أحدهم) لأن المقصود الواقف بر ذلك الجنس وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم وإن وقف مدرسة أو رباطا أو نحوهما على طائفة اختصت بهم وإن عين إماما أو نحوه تعين

والوصية في ذلك كالوقف %

فصل

+ (والوقف عقد لازم) بمجرد القول وإن لم يحكم به حاكم كالعتق لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم ف (لا يجوز فسخه) بإقالة ولا غيرها لأنه مؤبد (ولا يباع) ولا يناقل به

(إلا أن تتعطل منافعه) بالكلية كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها فيباع لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل

وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافة فكان كالإجماع ولو شرط الواقف أن لا يباع إذن ففاسد

(ويصرف ثمنه في مثله) لأنه أقرب إلى غرض الواقف فإن تعذر مثله ففي بعض مثله ويصير وقفا بمجرد الشراء وكذا فرس حبيس لا يصلح لغزو (ولو أنه) أي الوقف (مسجد) ولم ينتفع به في موضعه فيباع إذا خربت

محلته (وآلته) أي ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته (وما فضل عن حاجته) من حصره وزيته ونفقته ونحوها (جاز صرفه إلى مسجد آخر) لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له (والصدقة به على فقراء المسلمين) لأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدر بتعين إرصاده ونص فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصده لعله برجع وإن وقف على ثغر فاختل صرفه في ثغر مثله

وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما ولا يجوز غرس شجرة ولا حفر بئر بالمسجد وإذا غرس الناظر أو بنى في الوقف من مال الوقف أو من ماله ونواه للوقف فللوقف قال في الفروع ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف أنه بنيته

ج ٢ - ص ٤٨٤

باب الهبة والعطية

الهبة من هبوب الريح أي مروره يقال وهبت له شيئا وهبا بإسكان الهاء

وفتحها وهبة والاتهاب قبول الهبة والاستيهاب سؤال الهبة والعطية هنا الهبة في مرض الموت (وهي التبرع) من جائز التصرف (بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره) مفعول تمليك بما يعد هبة عرفا فخرج بالتبرع عقود المعاوضات كالبيع والإجارة وبالتمليك الإباحة كالعارية وبالمال نحو

الكلب وبالمعلوم المجهول وبالموجود المعدوم فلا تصح الهبة فيها وبالحياة الوصية (وإن شرط) العاقد (فيها عوضا معلوما ف) هي (بيع) لأنه تمليك بعوض معلوم ويثبت الخيار والشفعة فإن كان العوض مجهولا لم تصح وحكمها كالبيع الفاسد فيردها بزيادتها مطلقا وإن تلفت رد قيمتها والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه وإن اختلفا في شرط عوض فقول منكر بيمينه (ولا يصح) أن يهب (مجهولا) كالحمل في البطن واللبن في الضرع (إلا ما تعذر علمه) كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب أحدهما لرفيقه نصيبه منه فيصح للحاجة للصلح ولا يصح أيضا هبة ما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد وتنعقد) الهبة (بالإيجاب) والقبول بأن يقول وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك فيقول قبلت أو رضيت ونحوه (أو) ب (المعاطاة الدالة عليها)

أي على الهبة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها وكان أصحابه يفعلون ذلك ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشتهرا (وتلزم بالقبض بإذن واهب) لما روى مالك عن عائشة أن أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال يابنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى وروى ابن عيينة عن عمر نحوه ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف (إلا ما كان في يد متهب) وديعة أو غصبا ونحوهما لأن قبضه مستدام فأغنى عن الابتداء (ووارث الواهب) إذا مات قبل القبض (يقوم مقامه) في الإذن والرجوع لأنه عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار وتبطل بموت المتهب ويقبل

ويقبض للصغير ونحوه وليه وما اتهبه عبد غير مكاتب وقبله فهو لسيده ويصح

قبوله بلا إذن سيده (ومن أبرأ غريمه من دينه) ولو قبل وجوبه (بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة أو نحوها) كالإسقاط أو الترك أو التمليك أو العفو (برئت ذمته ولو) رده ولو (لم يقبل) لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول كالعتق ولو كان المبرأ منه مجهولا لكن لو جهله ربه وكتمه المدين

خوفا من أنه لو علمه لم يبرئه لم تصح البراءة ولو أبرأ أحد غريميه أو من أحد دينيه لم تصح لإبهام المحل (وتجوز هبة كل عين تباع) وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوما (و) هبة (كلب يقتنى) ونجاسة يباح نفعها كالوصية ولا تصح معلقة ولا مؤقتة إلا نحو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري أو ما بقيت فتصح وتكون لموهوب له ولورثته بعده وإن قال سكناه لك عمرك أو غلته أو خدمته لك أو منحتكه فعارية لأنها هبة المنافع ومن باع أو وهب فاسدا ثم تصرف في العين بعقد صحيح صح الثاني لأنه تصرف في ملكه %

فصل

+ (يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم) للذكر مثل حظ الأنثيين اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت قال عطاء ما كانوا يقتسمون إلا على كتاب الله تعالى وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد (فإن فضل

بعضهم) بأن أعطاه فوق إرثه أو حصته (سوى) وجوبا (برجوع) حيث أمكن (أو زيادة) المفضول ليساوي الفاضل أو إعطاء ليستووا لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه مختصرا وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملا وأداء إن علم وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه (فإن مات) الواهب (قبله) أي قبل الرجوع أو الزيادة (ثبتت) للمعطي فليس لبقية الورثة الرجوع إلا أن يكون بمرض الموت فيقف على إجازة الباقيين (ولا يجوز لواهب أن برجع في هبته اللازمة) لحديث ابن عباس مرفوعا العائد في

هبتة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه (إلا الأب) فله الرجوع

قصد التسوية أولا مسلما كان أو كافرا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه الخمسة وصححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس ولا يمنع الرجوع نقص العين أو تلف بعضها أو زيادة منفصلة ويمنعه زيادة متصله وبيعه وهبته ورهنه ما لم

ينفك (وله) أي لأب حر (أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه) لحديث عائشة مرفوعا إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم رواه سعيد والترمذي وحسنه وسواء كان الوالد محتاجا أو لا وسواء كان الولد كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى وليس له أن يتملك ما يضر

بالولد أو تعلقت به حاجته ولا ما يعطيه ولدا آخر ولا في مرض موت أحدهما المخوف (فإن تصرف) والده (في ماله) قبل تملكه وقبضه (ولو فيما وهبه له) أي لولده وأقبضه إياه (ببيع) أو هبة (أو عتق أو إبراء) غريم ولده من دينه لم يصح تصرفه لأن ملك الولد على مال نفسه تام فيصح تصرفه فيه ولو كان للغير أو مشتركا لم يجز (أو أراد أخذه) أي أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده (قبل

رجوعه) بهبته بالقول كرجعت فيها (أو) أراد أخذ مال ولده قبل (تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح) تصرفه لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك (بل بعده) أي بعد القبض المعتبر مع القول أو النية لصيرورته ملكا له بذلك وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر ولا حد ولا مهر عليه إن لم يكن الابن وطئها (وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه) كقيمة متلف أو أرش جناية لما روى

الخلال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه فقال أنت ومالك لأبيك (إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها) لضرورة حفظ النفس وله الطلب بعين مال له بيد أبيه فإن

مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب بدين ونحوه كمورثهم وإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته والصدقة وهي ما قصد به ثواب الآخرة والهدية وهي ما قصد به إكراما وتوددا ونحوه نوعان من الهبة حكمهما فيما تقدم ووعاء هدية كهي مع عرف %

ج ٢ - ص ٥٠١

فصل في تصرفات المريض بعطية أو نحوها

+ (من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع) أي وجع رأس يسير (فتصرفه لازم ك) تصرف (الصحيح ولو) صار مخوفا و (مات منه اعتبارا بحال العطية لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح) (وإن كان) المرض الذي اتصل به الموت (مخوفا كبرسام) وهو بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه (وذات الجنب) قرح بباطن الجنب (ووجع قلب) ورئه لاتسكن حركتها (ودوام قيام) وهو المبطون الذي أصابه الإسهال ولا يمكنه إمساكه (و) دوام (رعاف) لأنه يصفي الدم فتذهب القوة (وأول فالج) وهو داء معروف يرخي بعض البدن (وأخر سل) بكسر السين والحمى المطبقة (و) حمه

(الربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف) فعطاياه كوصية لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم رواه ابن ماجه (ومن وقع الطاعون ببلده) أو كان بين الصفين عند التحام حرب وكل من الطائفتين مكافئة للأخرى أو كان من المقهورة أو كان في لجة البحر عند هيجانة أو قدم أو حبس لقتل (ومن أخذها الطلق) حتى تنجو (لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث) ولو لأجنبي (إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه) كوصية

لما تقدم لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المريض (وإن عوفي) من ذلك (فكصحيح) في نفوذ عطاياه كلها لعدم المانع (ومن امتد مرضه بجذام أو سل) في ابتدائه (أو فالج) في انتهائه (ولم يقطعه بفراش ف) عطاياه (من كل ماله) لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم (والعكس) بأن لزم الفراش (بالعكس) فعطاياه كوصية لأنه مريض صاحب فراش يخشى منه التلف (ويعتبر الثلث عند موته) لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها وثبوت ولاية قبولها وردها فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية لأنها لازمة ونماء العطية من القبول إلى الموت تبع لها ومعاوضة المريض بثمن المثل من رأس المال والمحاباة كعطية (و) تفارق العطية الوصية في أربعة أشياء أحدها أنه (يسوي بين المتقدم والمتأخر في الوصية) لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة (ويبدأ بالأول فالأول في العطية) لوقوعها لازمة (و) الثاني أنه (لا يملك الرجوع فيها) أي في العطية بعد قبضها لأنها تقع لازمة في حق المعطي

وتنتقل إلى المعطى في الحياة ولو كثرت وإنما منع منالتبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها (و) الثالث أن العطية (يعتبر القبول لها عند وجودها) لأنها تمليك في الحال بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده (و) الرابع أن العطية (يثبت الملك) فيها (إذن) أي عند قبولها كالهبة لكن يكون مراعي لأنا لا نعلم هو مرض الموت أو لا ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيء من ماله فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره فإذا خرجت من الثلث تبينا أن الملك كان ثابتا من حينه وإلا فبقدره (والوصية بخلاف ذلك) فلا تملك قبل الموت لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه وإذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أو وصية أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته

عتقا من رأس المال وورثا لأنه حر حين موت مورثه لا مانع به ولا يكون عتقهم وصية ولو دبر ابن عمه عتق ولم يرث وإن قال أنت حر آخر حياتي عتق وورث